



DE LAS OBLIGACIONES

INTRODUCCIÓN

El estudio del derecho de las obligaciones juega un rol estructural en el derecho civil patrimonial. Además de la importancia propia de las materias que abordamos en este apunte, su adecuada comprensión es imprescindible para aprehender correctamente los contenidos del derecho de los contratos, de la responsabilidad extracontractual, e incluso del derecho de familia y sucesorio.

Recordemos que la principal clasificación de los derechos subjetivos es aquella que distingue entre los derechos reales y los derechos personales o créditos. Luego, dado que todo derecho personal o crédito implica una obligación correlativa, podemos decir que el derecho de las obligaciones comprende el estudio de los aspectos más relevantes y estructurales de las relaciones jurídicas obligacionales entre las personas. Así, si nos imaginamos el derecho civil como un árbol, el derecho de las obligaciones constituye parte esencial de su tronco.

En cuanto a los contenidos específicos abordados en este apunte, todos ellos se refieren al surgimiento, los efectos y la extinción de la relación jurídica obligacional: fuentes de las obligaciones, clasificación de las obligaciones, efectos de las obligaciones, y modos de extinguir las obligaciones.

Si bien el derecho de las obligaciones tiene una importancia estructural en su conjunto, nos parece necesario subrayar doblemente la importancia del estudio de las obligaciones con pluralidad de sujeto, de las modalidades, de los efectos de las obligaciones y de los principales modos de extinguir las obligaciones, como lo son el pago, la novación y la prescripción.

Una de las particularidades que suponen cierta complejidad para el estudio de estas materias dice relación con la gran cantidad de discusiones y desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales en cuanto a sus aspectos normativos más importantes. Frente a esta situación, y para efectos de posibilitar un estudio claro y sistemático, hemos optado por preservar la estructura de las doctrinas más clásicas, y consignar en el cuerpo del texto o en las notas al pie los aspectos de dichas explicaciones que son criticables o discutibles desde el punto de vista de las doctrinas más modernas. En aquellos temas cuya discusión implica un grado aún mayor de elaboración doctrinaria, como lo es en la discusión acerca de la autonomía de la pretensión indemnizatoria, disponemos de material adicional en forma de anexos o textos complementarios que nos pueden solicitar para complementar su estudio. Les instamos a solicitar dicho material en caso de que les surjan dudas o tengan ganas de profundizar.

Por último, en relación con este mismo punto, conviene enfatizar la importancia del estudio directo de las normas del Código Civil. En último término, toda discusión doctrinaria es una discusión acerca de cómo darle el mejor sentido a la normativa vigente, en función de los nuevos desafíos que las formas modernas de la contratación generan.

ÍNDICE

1. Conceptos generales	6
1.1 Introducción. Derechos reales y personales o créditos	6
1.2 Concepto de obligación	6
1.3 Elementos constitutivos de la obligación.....	6
1.3.1 Sujetos de la obligación	7
1.3.2 Objeto de la obligación	7
1.3.3 Características de la prestación	7
1.3.4 ¿Debe la prestación tener contenido patrimonial?	8
2. Fuentes de las obligaciones.....	9
2.1 Concepto	9
2.2 Clasificación	9
2.3 La voluntad unilateral como fuente de obligaciones	10
2.4 El enriquecimiento sin causa como fuente de obligaciones	11
3. Clasificación de las obligaciones.....	13
3.1 Diversas clasificaciones	13
3.2 Nuevas categorías de obligaciones	13
3.2.1 Obligaciones de medio y de resultado.....	13
3.2.2 Obligaciones reales o propter rem	16
3.2.3 Obligaciones causales y abstractas	17
3.3 Obligaciones civiles y naturales	18
3.3.1 Estudio de los casos del art. 1470 CC	20
3.4 Obligaciones positivas y negativas	23
3.5 Obligaciones de especie y obligaciones de género	23
3.6 Obligaciones de dar, hacer o no hacer	24
3.7 Obligaciones de dinero y de valor	25
3.8 Obligaciones de objeto singular y objeto plural	30
3.9 Obligaciones con unidad y pluralidad de sujetos	32
3.9.1 Obligaciones simplemente conjuntas	33
3.9.2 Obligaciones solidarias o insolidum	34
3.9.2.1 Solidaridad activa	36
3.9.2.2 Solidaridad pasiva	37
3.9.3 Obligaciones divisibles e indivisibles	42
3.9.3.1 Indivisibilidad activa	44
3.9.3.2 Indivisibilidad pasiva	44
3.9.3.3 Indivisibilidad de pago	45
3.10 Obligaciones principales y accesorias	47
3.11 Obligaciones puras y simples o sujetas a modalidad	48
3.11.1 De las obligaciones condicionales	49
3.11.1.1 Efectos de la condición suspensiva.....	57
3.11.1.2 Efectos de la condición resolutoria	58

3.11.1.2.1 Condición resolutoria ordinaria .	58
3.11.1.2.2 Condición resolutoria tácita.....	59
3.11.1.2.3 Pacto comisorio	64
3.11.1.3 La acción resolutoria y la resolución	67
3.11.1.4 Efectos de la resolución	68
3.11.1.5 Resolución/Nulidad/Resciliación	72
3.11.2 De las obligaciones modales.....	74
3.11.3 Obligaciones a plazo	76
4. Efectos de las obligaciones	81
4.1 Explicaciones previas	81
4.2 Efectos de las obligaciones.....	83
4.3 Cumplimiento forzado de la obligación	85
4.4 Indemnización de perjuicios	87
4.4.1 Incumplimiento del deudor.....	89
4.4.2 Perjuicio del acreedor	90
4.4.3 Relación de causalidad.....	90
4.4.4 Imputabilidad del deudor	90
4.4.5 Que no concorra una de las causales de exención de la responsabilidad	94
4.4.5.1 Fuerza mayor o caso fortuito.....	95
4.4.5.1.1 Teoría de los riesgos	96
4.4.5.2 Ausencia de culpa	97
4.4.5.3 Estado de necesidad	98
4.4.5.4 Hecho o culpa del acreedor	98
4.4.5.5 Teoría de la imprevisión	98
4.4.6 Mora del deudor	100
4.7 La evaluación de los perjuicios.....	103
4.7.1 Evaluación judicial de los perjuicios	103
4.7.1.1 Daño moral.....	103
4.7.1.2 Daño patrimonial	104
4.7.2 Evaluación legal de los perjuicios.....	105
4.7.3 Evaluación convencional (cláusula penal).....	106
4.8 Derechos auxiliares del acreedor.....	112
4.8.1 Las medidas conservativas	112
4.8.2 El derecho legal de retención	112
4.8.3 Acción oblicua o subrogatoria.....	113
4.8.4 Acción pauliana	115
4.8.5 Beneficio de separación de patrimonios	117
5 De los modos de extinguir las obligaciones	118
5.1 Concepto	118
5.2 Causales de extinción de las obligaciones	118
5.3 Clasificación de los modos de extinguir las obligaciones	118

5.4 La resciliación o mutuo disenso	119
5.5 La solución o pago efectivo	121
5.5.1 Modalidades del pago	129
5.5.1.1 Pago por consignación	129
5.5.1.2 Pago con subrogación	133
5.5.1.2.1 Subrogación legal	135
5.5.1.2.2 Subrogación convencional	137
5.5.1.3 Pago con cesión de bienes	138
5.5.1.4 Pago con beneficio de competencia	140
5.5.1.5 Dación en pago	141
5.6 La novación	143
5.7 La compensación	148
5.8 La remisión	151
5.9 La confusión	152
5.10 Imposibilidad de ejecución y pérdida de la cosa debida	153
5.11 La prescripción	156
5.11.1 Reglas comunes a toda prescripción	156
5.11.2 Requisitos de la prescripción extintiva	158
5.11.2.1 Acción prescriptible.....	158
5.11.2.2 Inactividad de las partes.....	159
5.11.2.3 Tiempo de prescripción.....	161
5.11.2.3.1 Prescripciones de largo tiempo	161
5.11.2.3.2 Prescripciones de corto tiempo	162
5.11.2.3.3 Prescripciones especiales.....	164
5.11.3 Otros aspectos relevantes de la prescripción.....	164
6. De la prelación de créditos.....	166
6.1 Generalidades.....	166
6.2 Los créditos que gozan de preferencias	168
6.2.1 Primera clase de créditos	168
6.2.2 Segunda clase de créditos.....	169
6.2.3 Tercera clase de créditos.....	170
6.2.4 Cuarta clase de créditos.....	171
6.2.5 Quinta clase de créditos.....	172
7. Anexos.....	174
Anexo I: Alcance de la asimilación de la culpa grave al dolo	174
Anexo II: Teoría unitaria del dolo	174
Anexo III: Respecto del incumplimiento esencial.....	174
Anexo IV: Efectos del pacto comisorio atípico	176
Anexo V: Acerca de las obligaciones de medio y resultado	177
Anexo VI: Abuso del derecho.....	178
Anexo VII: Teoría de los actos propios	181
Anexo VIII: Caso Zorín con Huachipato	183

Anexo IX: Sobre la diferencia entre estar obligado y ser responsable .. 185

OBLIGACIONES

CAPÍTULO 1. CONCEPTOS GENERALES.

1.1 INTRODUCCIÓN. DERECHOS REALES Y PERSONALES O CRÉDITOS.

Art. 577 inc. 1º CC. "Derecho *real* es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona."

Art. 578 CC. "Derechos *personales* o *créditos* son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas, que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas;..."

Las nociones de **derecho personal o crédito** y de **obligación** son **correlativas**. Se habla de derecho personal o de obligación según si se mire desde el punto de vista del acreedor o del deudor.¹

1.2 CONCEPTO DE OBLIGACIÓN.

Obligación: vínculo jurídico entre dos personas determinadas –deudor y acreedor-, en virtud del cual la primera se encuentra en la necesidad jurídica de dar, hacer o no hacer algo en favor de la segunda.

Desde el punto de vista del acreedor, es un crédito; desde el del deudor, es una deuda.

Relación jurídica: relación protegida por el derecho objetivo. Si el deudor no cumple, puede ser compelido a hacerlo.

La gran excepción a la coercibilidad de las obligaciones son las obligaciones naturales. Si bien estas constituyen un vínculo jurídico tutelado por el derecho objetivo, no son susceptibles de cumplimiento forzoso.

Art. 2465 CC. "Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, designados en el artículo 1618."

Por tanto, cuando se contrae una obligación, se responde de su cumplimiento con todo el patrimonio: "derecho de prenda general".

1.3 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA OBLIGACIÓN.

Se discute sobre lo que en esencia constituye la obligación:

¹ Para un análisis de las diferencias entre los derechos reales y los derechos personales, remitimos al estudiante al apunte de bienes, sección 1.2.

1. Base ética: Para algunos, consiste en el deber del deudor de observar un determinado comportamiento. En este sentido, toda obligación importa una restricción de libertad del deudor. Si no cumple, el crédito se hace efectivo sobre su patrimonio, pero esto ya no es parte de la obligación.

2. Base económica: Otros ponen énfasis en la responsabilidad del deudor. Lo que en esencia constituye la obligación es el hecho que el patrimonio del deudor quede afecto a su cumplimiento.

Concepto unitario de la obligación: comprende tanto el deber de prestación (deuda) como el sometimiento del patrimonio (responsabilidad).

Concepto no unitario: existencia autónoma de la deuda y la responsabilidad, que pueden yuxtaponerse.

Importancia práctica de la diferencia:

- 1) Permite entender la naturaleza de las obligaciones naturales, en que hay deuda, pero no responsabilidad.
- 2) Permite entender la naturaleza de la fianza, en que una persona asume una deuda ajena. Discutible, porque el fiador también es deudor, aunque no del mismo grado que el principal.

1.3.1. SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN: ACREEDOR Y DEUDOR.

Acreedor: titular del derecho personal en virtud del cual puede exigir una prestación del deudor.

Deudor: quien debe dar, hacer o no hacer algo en favor del acreedor.

En los contratos bilaterales, ambas partes tendrán el carácter de acreedoras y deudoras.

Los dos sujetos deben ser personas determinadas, o al menos determinables. Se discute en doctrina si es indispensable para el nacimiento del derecho que el sujeto exista con anterioridad.

Tanto el deudor como el acreedor pueden ser una o varias personas.

1.3.2. DEL OBJETO DE LA OBLIGACIÓN.

Objeto de la obligación: prestación a que se obliga el deudor. Es un determinado comportamiento, positivo o negativo.

De acuerdo al Art. 1438 CC, es lo que el deudor debe dar, hacer o no hacer.

1.3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN.

a) Debe ser física y jurídicamente posible: se debe poder realizar. La imposibilidad puede ser absoluta o relativa.

b) Debe ser lícita: no debe estar prohibida por la ley, ni ser contraria a las buenas costumbres o al orden público (Art. 1461 inc. final CC).

c) Debe ser determinada, o a lo menos determinable: que esté precisada, o que pueda definirse sin necesidad de otro acuerdo de las partes (Art. 1461 inc. 2º CC).

respecto de las obligaciones de dar).

1.3.4 PARA QUE EXISTA OBLIGACIÓN ¿DEBE LA PRESTACIÓN TENER CONTENIDO PATRIMONIAL (PECUNIARIO)?

Así se entendió en un principio. Pero luego se distinguió la prestación en sí del interés del acreedor. La primera debe tener un contenido patrimonial; si no es así, no se puede ejecutar en el patrimonio del deudor. El segundo puede ser patrimonial, moral, científico, etc.

El derecho de obligaciones es eminentemente patrimonial, pero los intereses económicos pueden aparecer vinculados a otros que no lo son, e incluso pueden presentarse intereses no propiamente económicos como objeto de la obligación. Ej. Derecho del trabajo, indemnización del daño moral, etc.

Si se niega la validez de una obligación por no tener contenido económico, se limita arbitrariamente la autonomía de la voluntad.

CAPÍTULO 2. FUENTES DE LAS OBLIGACIONES.

2.1. CONCEPTO.

Fuentes de las obligaciones: hechos jurídicos que dan nacimiento, que originan o generan las obligaciones (Abeliuk).

2.2. CLASIFICACIÓN.

De acuerdo al Art. 578 CC, las fuentes serían el hecho del deudor y la ley.

El hecho del deudor incluye:

- 1) El acuerdo de voluntades (contrato).
- 2) El hecho voluntario lícito no convencional (cuasicontrato).
- 3) La conducta negligente que causa daño a otro (cuasidelito civil).
- 4) El hecho doloso que causa daño a otro (delito civil).

Art. 578 CC. "Derechos personales o créditos son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas, que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales."

Art. 1437 CC. "Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos sujetos a patria potestad."

Art. 2284 CC. "Art. 2284 CC. Las obligaciones que se contraen sin convención, nacen o de la ley, o del hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella.

Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato.

Si el hecho es ilícito, y cometido con intención de dañar, constituye un delito.

Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito. En este título se trata solamente de los cuasicontratos

En resumen, las fuentes de las obligaciones para el CC son:

- 1) El contrato
- 2) El cuasicontrato
- 3) El delito
- 4) El cuasidelito
- 5) La ley.

Críticas a la clasificación anterior.

Según cierto sector de la doctrina, sólo la voluntad y la ley pueden generar obligaciones. En los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos, las obligaciones nacen porque así lo establece la ley. En respuesta, se ha dicho que se podría aplicar

la misma lógica a los contratos y, según esta lógica, solo la ley sería la fuente de las obligaciones.

Por otro lado, cierto sector de la doctrina más contemporánea ha criticado esta clasificación en el sentido de que habrían más fuentes que las cinco enunciadas más arriba. En particular, se ha discutido en torno a la procedencia de la voluntad unilateral y del enriquecimiento sin causa como fuente de las obligaciones.

2.3. LA VOLUNTAD UNILATERAL COMO FUENTE DE LA OBLIGACIÓN

Obligación nacida de la voluntad unilateral: la que contrae un sujeto mediante su mera manifestación de querer obligarse. Esta obligación es distinta a la oferta, porque vincula desde el primer momento al declarante sin necesidad de aceptación, insertándose desde entonces como un valor activo en el patrimonio del acreedor.

Ej.

- Art. 632 inc. 2º CC (promesa de recompensa al que denuncie el hallazgo de una especie al parecer perdida),
- Art. 99 CCom (oferente que se obliga a no disponer de la cosa sino pasado cierto tiempo o desechada la oferta).

Peñailillo la define como: "es la fuente por la cual la manifestación de voluntad de un sujeto genera una obligación para él, sin necesidad de la voluntad de un correlativo acreedor".

Se discute en doctrina la fuerza obligatoria de la voluntad unilateral, pero tiene cada día más aceptación.

Se ha de ser cuidadoso en no confundir la declaración unilateral de voluntad como fuente de obligaciones, con casos de actos jurídicos unilaterales. En estos últimos, la fuente de la obligatoriedad es directamente la ley, más allá de que en su gestación haya sido necesaria la voluntad del autor (por ejemplo, al reconocerse un hijo, surge una obligación alimentaria de carácter legal). La voluntad unilateral tampoco se ha de confundir con el contrato unilateral, ya que en este existe un acuerdo de voluntades que genera obligaciones para una de las partes, y en aquella existe sólo una parte.

¿En Chile, se acepta la voluntad unilateral como fuente de las obligaciones?

A) Posición tradicional: El CC no la acepta, salvo la situación excepcional del Art. 632 inc. 2º CC. Bello siguió a Pothier, que no la aceptaba.

B) La declaración unilateral de voluntad puede tener cabida en el Art. 1437 CC, pues es justamente un hecho voluntario de la persona que se obliga.

Además del art. 632 incº2 CC, otro ejemplo de voluntad unilateral como fuente de las obligaciones sería la situación del oferente que se compromete a esperar contestación o a no disponer del objeto del contrato propuesto, según el art. 99 del Código de Comercio.

La posición doctrinal más moderna es de una admisión aún restringida, pero paulatinamente cada vez más amplia, de hipótesis de declaración unilateral de voluntad como fuente de las obligaciones. La jurisprudencia se ha pronunciado solo de manera ocasional en torno a este problema, y cada vez se reconocen más hipótesis de

obligatoriedad. Por ejemplo, en fallo pronunciado en 2011, rol de ingreso 5489-2009, se reconoce la obligatoriedad a propósito de las cartas de patrocinio².

2.4. EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA COMO FUENTE DE LAS OBLIGACIONES³

El enriquecimiento sin causa es un principio general de Derecho. Pero, por otra parte, y sin perjuicio de la anterior calificación, cierta doctrina más contemporánea la considera una fuente autónoma de obligaciones, de modo que merece también una posición entre ellas. Y aunque se pueda estimar que entre nosotros está admitida implícitamente, de todas formas, sería conveniente que se consagrara también su implementación mediante norma expresa en el Libro IV del Código Civil. Además, es necesario mencionar que la acogida jurisprudencial de esta fuente de las obligaciones es dudosa. Ha sido rechazada por la Corte Suprema.

En cuanto principio, consiste en que el Derecho repudia el enriquecimiento a expensas de otro sin una causa que lo justifique. Y en cuanto a fuente de obligaciones consiste en una atribución patrimonial sin una justificación que la explique, de modo que, constatada dicha situación, se impone la obligación a restituir.

Su estructura como fuente

La obligación de restituir se traduce en la acción "in rem verso". La doctrina tradicional exige los siguientes requisitos: (1) Enriquecimiento de un sujeto, (2) empobrecimiento de otro, (3) correlatividad entre ambos y (4) ausencia de causa del enriquecimiento.

Cierta doctrina más contemporánea ha propuesto una alternativa, que, centrando la institución en el enriquecimiento, exige solamente enriquecimiento y ausencia de causa. En suma, según esta interpretación, la substancia de la institución es el enriquecimiento sin causa jurídicamente justificable. Y su funcionamiento en cuanto fuente de obligaciones se posibilita mediante la determinación del hecho generador y el vínculo desde él hacia dos sujetos: 1) el que hasta ahora está enriquecido y 2) el que debe quedar con esa riqueza (porque a él corresponde).

Además, esta acción solo resulta procedente a condición de que no exista otra acción para corregir la atribución de riqueza injustificada. Es decir, la acción in rem verso es de carácter subsidiario.

² Las cartas de patrocinio son "una declaración por medio de la cual una persona (el patrocinador) asegura a otra (el acreedor o destinatario) que las condiciones que se tienen en cuenta para concluir una determinada operación con un tercero (el patrocinado) permanecerán en el tiempo, formando en aquél la expectativa de que dicha operación será satisfactoriamente cumplida, incluso merced a la intervención del otorgante" Para quien desee profundizar sobre el particular, consultar *Las cartas de patrocinio y su recepción en el derecho chileno. Notas a propósito de una sentencia de la Corte Suprema*, del profesor Jaime Alcalde Silva.

³ Elaborado en base al artículo "El enriquecimiento sin causa. Principio de derecho y fuente de obligaciones" del profesor Daniel Peñailillo Arévalo.

Efectos en cuanto fuente de la obligación

En cuanto fuente de obligaciones, el efecto fundamental es que el enriquecido injustamente queda obligado a restituir la ventaja, provecho o beneficio obtenido. Ese es el objeto de la acción "in rem verso". El principio aquí ha de ser que, en cuanto sea posible, la restitución será en especie, y, en subsidio, en un valor equivalente.

Sin perjuicio de que normas específicas se inspiren en el postulado, debería establecerse una norma con aplicación general. A este efecto y según Daniel Peñailillo Arévalo, la norma sería aproximadamente: "Cada vez que alguien se enriquezca a expensas de otro sin causa justificada, es obligado a restituir el valor correspondiente".

¿Es admisible en el derecho chileno como fuente de obligaciones? Ya se ha dicho que no se dispone actualmente de regla expresa general que consagre el enriquecimiento sin causa como fuente de obligaciones. Con todo, junto al vigoroso fundamento de la equidad hay quienes sí le encuentran actualmente un asidero legal. Atendido al carácter eminentemente legislado de nuestro sistema jurídico, es importante ofrecer un enraizamiento legal. En este sentido, las normas que podrían servir de base serían los arts. 578 y 1437 CC. El primero, en cuanto reconoce como fuente al "hecho suyo" y que en este caso sería el hecho que provocó el enriquecimiento. Y el segundo, en cuanto consagra como fuente al "hecho voluntario" viene a constituir otro sustento.

La obligación y la acción

En ella el acreedor es el sujeto a quien corresponde la atribución patrimonial que impropriamente ha recibido el enriquecido y el deudor es el enriquecido.

Se trata genéricamente de una obligación de dar. Desde el punto de vista de su forma, no constará en título ejecutivo, el que tendrá que construirse mediante el juicio declarativo correspondiente, ejercitándose la acción de enriquecimiento.

La acción es la que se confiere al titular de la atribución que impropriamente ha recibido el enriquecido, para obtener que el enriquecido sin causa justificada le restituya el valor respectivo. Es una acción personal y patrimonial.

CAPÍTULO 3. CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES.

3.1. DIVERSAS CLASIFICACIONES.

1. Eficacia:
 - a. Civiles
 - b. Naturales
2. Objeto:
 - a. Forma:
 - i. Positivas
 - ii. Negativas
 - b. Determinación del objeto:
 - i. De especie o cuerpo cierto
 - ii. De género
 - c. Contenido de la prestación:
 - i. De dar
 - ii. De hacer
 - iii. De no hacer
 - d. De dinero y de valor
 - e. Número de cosas:
 - i. De objeto singular
 - ii. De objeto plural:
 1. De simple objeto múltiple
 2. Alternativas
 3. Facultativas
3. Sujeto:
 - a. De unidad de sujeto
 - b. De pluralidad de sujeto:
 - i. Simplemente conjuntas o mancomunadas
 - ii. Solidarias
 - iii. Indivisibles
4. Forma de existir:
 - a. Principales
 - b. Accesorias
5. Efectos:
 - a. Puras y simples
 - b. Sujetas a modalidad

3.2. NUEVAS CATEGORÍAS DE OBLIGACIONES.

3.2.1. OBLIGACIONES DE MEDIO Y DE RESULTADO⁴

Esta clasificación sólo es aplicable a las obligaciones de hacer.

1) Obligaciones de medio: son aquellas en que el deudor se compromete únicamente a hacer todo lo posible y necesario, poniendo para ello la suficiente diligencia, para alcanzar un resultado determinado. Ej. Obligación de un abogado o

⁴ Ver Anexo V

un médico.

2) Obligaciones de resultado: son aquellas en que el deudor para cumplir debe alcanzar el resultado propuesto. Ej. Obligación del contratista de construir una casa.

La diferencia entre estos dos tipos de obligaciones radica en el compromiso que adquiere el deudor al contratar. En las obligaciones de resultado éste se compromete a obtener la satisfacción primaria del acreedor, en cambio en las obligaciones de medio se compromete a desarrollar un actuar diligente tendiente a la satisfacción del interés del acreedor, entendiéndose cumplida si es que el deudor observa la diligencia debida, y no si es que se obtiene el resultado.

Si bien en ambas se busca un resultado, sólo en las obligaciones de resultado se identifica aquel con el cumplimiento de la obligación.

Se ha considerado a René Demogue como el autor de esta distinción, quien la realizó para defender su tesis de la teoría unitaria de la responsabilidad (concebir la responsabilidad contractual y extracontractual como una sola). Demogue planteó que no es correcto afirmar que siempre en responsabilidad contractual la culpa se presume, y que en responsabilidad extracontractual debe probarse. Señaló que en responsabilidad extracontractual existen casos de responsabilidad estricta, lo que haría innecesario probar a culpa. Y que en materia contractual debe distinguirse entre obligaciones de medio y de resultado, postulando dicho autor que, si el deudor de una obligación de medio prueba que actuó diligentemente, se exonera de responsabilidad, mientras que en las obligaciones de resultado, la única forma de exonerarse sería el caso fortuito, prescindiéndose de la culpa.

Se ha considerado que una justificación de la clasificación sería una de orden económico. Si es que todas las obligaciones fueran de resultado se elevaría el precio de las prestaciones.⁵ Y si es que todas las obligaciones fueran de medio, se desincentivaría la inversión y contratación ya que las personas no podrían exigir legalmente la obtención del resultado querido.

Un tema relevante consiste en determinar cómo saber si se está frente a una obligación de medio o una obligación de resultado. El primer criterio a utilizar es el de autonomía de la voluntad, son las partes quienes los determinan. El problema surge cuando éstas no lo han establecido en el contrato. Han existido diferentes criterios que han buscado dar respuesta a esta cuestión; el criterio de la situación de las partes (atiende a si se trata de profesiones liberales, que contraerían obligaciones de medio, o de oficio, que contraerían obligaciones de resultado); el criterio del carácter aleatorio del resultado (atiende a si la aleatoriedad es un factor para la obtención de la satisfacción del acreedor, si lo juega serían obligaciones de medio); el criterio del rol activo o pasivo del acreedor (en el primer caso serían obligaciones de medio y en el segundo de resultado); el criterio de la mayor o menor determinación de la obligación (si está mayor determinada sería una obligación de resultado, pero si el

⁵ Por ejemplo, si un doctor estuviera obligado a un resultado, debido a la probabilidad de no obtener el resultado quería estaría muy expuesto al incumplimiento y por lo tanto la responsabilidad, lo que lo llevaría a elevar considerablemente el valor de su prestación para precaver dicha situación.

nivel de determinación es menor, se acercaría a una obligación de medio); el criterio de la distribución de riesgos (si el riesgo es asumido por el acreedor sería una obligación de medio, en cambio si es asumida por el deudor se trataría de una obligación de resultado); el criterio de la equidad (atiende a la equidad en el caso concreto).

Debe tenerse claro que ninguno de estos criterios es absoluto y todos están sujetos a críticas. Además, es posible que un determinado contrato implique obligaciones de ambas clases (por ejemplo, un abogado se obliga a prestar ciertos servicios con diligencia, pero está sujeto a una obligación de resultado en cuanto a la observancia de los plazos en el proceso.)

¿Está contenida la distinción entre obligaciones de medios y de resultados en nuestro Código Civil?

En primer lugar, es necesario mencionar que esta clasificación legal no está acogida expresamente en nuestro Código Civil. Hay una razón histórica muy concreta para explicar su ausencia: el origen de la distinción ocurrió en un momento posterior a la entrada en vigencia de nuestro Código Civil.

Luego, en relación con su recepción jurisprudencial, ésta ha sido acogida sistemáticamente por la Corte Suprema en los últimos años. El principal campo de acogida de dicha distinción ha sido a propósito de casos de responsabilidad civil médica.

Por último, si bien no existe consagración legal de la clasificación de las obligaciones en de medio y de resultado, existen diversos argumentos dados por la doctrina para que dicha distinción se acogida: A) Buena fe contractual, art. 1546: como los contratos deben ejecutarse de buena fe, conforme a la naturaleza, hay que dejar en claro que la naturaleza de ambas obligaciones es diverso. El acreedor de una obligación de medios no puede pretender que se le satisfaga el interés primario. B) art. 1698: en las obligaciones de medios debe probarse la culpa, ya que el incumplimiento es igual a negligencia. En las de resultado se presume culpable. C) art. 1547 inciso 3º: puede sostenerse que la prueba de la diligencia sólo corresponde a la de medios y que el caso fortuito se aplica a ambas. D) El art. 2158, a propósito del mandato, obliga a pagar al mandatario, aún cuando el mandante no haya satisfecho su interés primario. E) art. 2158 y su aplicación a prestaciones profesionales: El art. 2118 hace aplicable las normas del mandato, incluyendo el 2158, a las prestaciones profesionales.

Importancia de la introducción de ésta clasificación en el derecho de obligaciones:

1) Respecto de la determinación del contenido de la obligación.

Las obligaciones de medio serían una excepción a la regla general de que el acreedor ha contratado persiguiendo la satisfacción de su interés primario. Saber de qué tipo de obligación se trata permite determinar el contenido de la misma.

2) Respecto del cumplimiento de la obligación.

Por tratarse de uno u otro tipo de obligación, se entenderán cumplidas de diferentes maneras. Si son de resultado, como ya se mencionó se entenderán cumplidas mediante la satisfacción del interés primario del acreedor, en cambio en las obligaciones de medio se entienden cumplidas en la medida que el deudor desplegó un actuar diligente tendiente a conseguir el fin propuesto, pero no será el criterio si se obtuvo o no dicho fin. Consecuencias de lo anterior, la prueba para determinar cumplimiento o incumplimiento recaerá sobre objetos distintos, en el primer caso recaerá sobre si se satisfizo o no al acreedor, y en el segundo caso recaerá sobre si el deudor tuvo o no un actuar diligente.

3) Respecto de la prueba de la culpa.

No se produce ningún problema con la presunción de culpa en materia de obligaciones de resultado (art. 1547 CC). La aplicación de la presunción de culpa resulta discutible en el caso de las obligaciones de medio. Quienes sostienen que la presunción no puede aplicarse, argumentan en base al hecho de que, en las obligaciones de medio, el incumplimiento equivale a la negligencia. La presunción de culpa respecto al incumplimiento se aplica como consecuencia de haberse constatado el incumplimiento. En consecuencia, dado que la conducta culposa es precisamente el elemento constitutivo del incumplimiento, no es posible constatar el incumplimiento como condición previa para aplicar la presunción de culpa. Quienes sostienen que la presunción sí puede aplicarse, lo hacen por medio de la distinción entre la culpa como criterio para determinar el incumplimiento en la obligación de medios y la culpa como criterio para determinar la imputabilidad de dicho incumplimiento. Desde esta última posición, sí sería aplicable la presunción, pues culpa como factor de incumplimiento y como factor de imputabilidad operan en niveles distintos.

4) Respecto de las causales de exoneración de responsabilidad.

Se han planteado en doctrina dos causales de exoneración: el caso fortuito y la prueba de la diligencia. El primero aplica tanto respecto de las obligaciones de medio como de las obligaciones de resultado. La prueba de la diligencia como causal de exoneración, en cambio, presenta discusión. Parte de la doctrina piensa que dicha causal de exoneración opera respecto de ambos tipos de obligaciones. A partir de la distinción entre la culpa como factor de incumplimiento y la culpa como criterio de imputabilidad, se postula la existencia de un campo intermedio entre el incumplimiento culpable y el incumplimiento fortuito, donde la prueba de la diligencia sí podría operar como causal de exoneración. La doctrina contraria piensa no es posible exonerarse mediante la prueba de la diligencia, ya que de ser así, perdería relevancia el caso fortuito, todas las obligaciones pasarían a ser de medios y, además, porque el artículo 1547 del Código Civil debe interpretarse de manera que la prueba de la culpa exonera en las obligaciones de medio, y la prueba del caso fortuito en las obligaciones de resultado.

3.2.2. OBLIGACIONES REALES, PROPTER REM O AMBULATORIAS

Las obligaciones propter rem, son aquellas que recaen sobre el dueño o poseedor (Peñailillo habla de derecho real, no solo dominio) de una cosa sólo por el hecho de serlo. Se caracterizan porque en vez de vincular el objeto de la obligación a un sujeto

determinado, como es el caso normal de los derechos personales, recaen sobre cualquiera persona que sea titular del dominio sobre una cosa. Tienen entonces ciertas particularidades:

- El deudor se determina atendiendo a la persona que es propietaria o poseedora de la cosa (de ahí el nombre, son obligaciones "en razón o por causa" de la cosa).
- La obligación se traspaşa al sucesor en particular en forma automática: si cambia el titular del dominio, cambia el sujeto pasivo de la obligación.
- El deudor tiene la facultad de liberarse de la prestación mediante la renuncia o abandono del derecho real relacionado.

Casos de obligaciones propter rem:

- 1) Obligación del dueño del árbol que se extiende o penetra el suelo ajeno. Está recogida en el art. 942: "si un árbol extiende sus ramas sobre suelo ajeno o penetra en el él con sus raíces, podrá el dueño del suelo exigir que se corte la parte excedente de las ramas, y cortar él mismo las raíces";
- 2) Obligación de pagar los gastos comunes. La ley Nº19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, señala en su art. 4º: "La obligación del propietario de una unidad por los gastos comunes seguirá siempre al dominio de su unidad, aun respecto de los devengados antes de su adquisición". Lo particular de este caso es que no se permite el abandono, pues la ley señala que la obligación se tiene sin perjuicio del derecho del propietario de exigir su pago a su antecesor en el dominio y de la acción por saneamiento de la evicción;
- 3) Tercero adquirente de inmueble hipotecado. Se trata de una persona que, sin estar personalmente obligado al pago de una deuda, debe soportar la ejecución efectuada por el acreedor hipotecario. Véanse los arts. 758 y ss. del Código de Procedimiento Civil; y,
- 4) Derechos personales oponibles a terceros. El ejemplo más claro es el art. 1962.
- 5) Art. 614 Código Civil, obligación de los dueños de las tierras contiguas a las playas en favor de los pescadores, a los que deben dejar una franja de 8 metros.
- 6) Art. 858 Código Civil. Obligación de contribuir a prorrata de sus derechos en las expensas de construcción, conservación y reparación del cerramiento.

3.2.3. OBLIGACIONES CAUSALES Y ABSTRACTAS O FORMALES

1. Obligación Causada: es aquella en la cual la causa tiene influencia en su eficacia.
2. Obligación Abstracta: es aquella para cuya eficacia se prescinde de la causa. Debe tenerla, pero es eficaz con prescindencia de su existencia y licitud.

Por tanto es incorrecto, como suele expresarse, que las obligaciones abstractas

carecen de causa, cuando en rigor lo que acontece es que en el acto causado la causa integra el negocio, forma parte de él, por lo que su validez queda subordinada a ella (como a los demás elementos). En los abstractos, por el contrario, la causa no está incorporada al negocio, por lo que debe de buscarse fuera de éste. Este otro acto en que existe la causa, al relacionarse con el acto abstracto da origen a lo que se ha denominado "convenio causal" o "relación fundamental"; relación que resulta de esencial importancia por dos aspectos: i) revela que en todo acto existe una causa (sin perjuicio de haber sido desplazada por la abstracción); y ii) permite ante una falta o ilicitud de la causa, que se restablezca el equilibrio patrimonial en virtud de la institución del "enriquecimiento sin causa", o más propiamente dicho "enriquecimiento injustificado".

La abstracción ha sido creada para satisfacer una necesidad social, a saber, la de dotar a la comunidad de instrumentos seguros y confiables para los que resulten tener la posición de acreedores y, por lo mismo, estén más proclives a aceptarlos, de forma de facilitar el intercambio permitiendo una mayor agilidad del tráfico jurídico y consecuentemente de la asignación de los recursos. La ventaja de la abstracción es que se gana en seguridad, toda vez que al desplazarse la causa, el acreedor pueda evitarse la eventual discusión que pueda darse en relación a la validez del acto por carecer de causa o ser ésta ilícita.

Así es que consecuentemente, ha sido en el ámbito mercantil donde mayormente se han desarrollado y aplicado éstos conceptos, dando lugar a la aparición de los títulos de crédito (letras de cambio, pagarés, cheques, y recientemente, la cuarta cuota cesible de las facturas, entre muchos otros).

Es importante aclarar que no tiene cabida en nuestro derecho la creación de actos abstractos, los que son meras excepciones establecidas especialmente en la **ley (de forma expresa o que se desprenda de su naturaleza, como en el caso de la fianza)**, en atención a que parece ser que la causa en los actos voluntarios es de orden público.

3.3. OBLIGACIONES CIVILES Y NATURALES

1. Concepto, definiciones.

Art. 1470 incs. 1º a 3º CC. "Las obligaciones son *civiles* o meramente *naturales*. Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Naturales las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que, cumplidas, autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas."

De esta manera, podríamos decir que las obligaciones civiles se caracterizan por dar acción para exigir su cumplimiento y excepción para retener el pago una vez realizado, mientras que las obligaciones naturales no dan acción, pero sí excepción.⁶

⁶ Algunos sectores de la doctrina son críticos de la definición de obligación natural que da el legislador. Sostienen que no sería correcto afirmar que las obligaciones naturales no dan derecho para exigir su cumplimiento. Argumentan que el derecho para exigir el cumplimiento, esto es, la acción, se tiene igualmente. El punto es que, ejercitada la acción, el deudor podría invocar el carácter natural de la obligación cuyo cumplimiento se solicita, acreditar la causal, y pedir que se

2. Naturaleza de la obligación natural.

Hay diversas opiniones:

1. Es una obligación no jurídica, sino moral o de conciencia, o social, que sólo produce un efecto jurídico: no se puede repetir lo pagado.
2. Sólo se convierte en jurídica con el pago.
3. Jurídicamente no es una obligación (vínculo jurídico entre deudor y acreedor), sino un hecho que justifica la atribución patrimonial que se hizo al acreedor, es sólo una justa causa para el pago. Por eso no procede repetición.
4. Para nuestros autores, son verdaderas obligaciones, pues constituyen un vínculo jurídico entre personas determinadas que produce efectos jurídicos (retener lo pagado). No son simples deberes morales.

Las obligaciones naturales en el derecho chileno.

Art. 1470 inc. 4º CC. "Tales son:

- 1º Las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos;
- 2º Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción;
- 3º Las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles; como la de pagar un legado, impuesto por un testamento que no se ha otorgado en la forma debida;
- 4º Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba."

3. Las obligaciones naturales ¿son taxativas en Chile?

El Art. 1470 CC es taxativo.

1. La frase "tales son" importa taxatividad.
2. El pensamiento del autor del CC es claro.
3. El Art. 2296 CC, al referirse a las obligaciones naturales, se remite al Art. 1470 CC, demostrando que no hay otras.

No es taxativo. (Mayoría)

1. El Art. 1470 CC las define, por lo que cualquier situación que encuadre en la definición es una obligación natural.
2. La frase "tales son" significa ejemplificación.

La mayoría de la doctrina se inclina por la segunda tesis, pero no hay unanimidad sobre cuáles serían los otros casos de obligaciones naturales. Se mencionan:

1. La multa en los esponsales (Art. 99 CC). Pero la mayor parte de la doctrina no está de acuerdo, porque el Art. 98 CC dice que los esponsales no producen

rechace por esta razón. En ese sentido, más que no dar acción, las obligaciones naturales darían una acción enervable

obligación alguna ante la ley civil.

2. Lo dado por un objeto o causa ilícita a sabiendas (Art. 1468 CC). En este caso, parece tratarse más de una sanción que de una obligación natural.

3. Situación del deudor que paga más allá de lo que debe por gozar del beneficio de inventario (Art. 1247 CC) o del beneficio de competencia (Art. 1625 CC). La doctrina estima que en estos casos hay una renuncia al beneficio, pues si paga más allá, está pagando una obligación civil.

4. Pago de intereses no estipulados (Art. 2208 CC y Art. 15 Ley 18.010 sobre Operaciones de Crédito de Dinero). Tampoco hay obligación natural; lo que ocurre es que la gratuidad no se presume, por lo tanto se está pagando una obligación civil.

5. Pago de una deuda de juego o apuesta en que predomina la inteligencia (Art. 2260 CC). En este caso habría una verdadera obligación natural.

3.3.1. OBLIGACIONES NATURALES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 1470 CC.

1. OBLIGACIONES NATURALES PROVENIENTES DE OBLIGACIONES CIVILES NULAS O RESCINDIBLES.

(1) Las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento, son sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos. (Art. 1470 N°1)

Se refiere a los incapaces relativos, jamás a los absolutos, cuyos actos no producen ni aun obligaciones naturales (Art. 1447 inc. 2º CC).

No hay duda de que los menores adultos quedan comprendidos. Pero se discute si los disipadores también.

- Algunos piensan que no, pues están interdictos justamente por no tener suficiente juicio y discernimiento.
- La opinión contraria sostiene que el disipador no es un enajenado mental, sino sólo un administrador imprudente, que tiene suficiente juicio y discernimiento.

Como ya no existen más incapaces relativos, el efecto de eliminar al disipador es que la disposición, que señala a los menores adultos como ejemplo, pasa a ser taxativa.

Si la obligación es anulable por otro motivo, es obligación civil nula, no natural.

¿Desde cuándo la obligación es natural?

1. Desde que se declara la nulidad, pues antes la obligación es válida y produce todos sus efectos. Se funda en los Arts. 1684 y 1687 CC. Además, existen casos en que el acto, siendo anulable por incapacidad relativa, permanecerá válido porque la nulidad no podrá ser alegada cuando el incapaz ha actuado con dolo.

2. Desde que el acto se celebró por los incapaces relativos.

- i. El Art. 1470 N° 1 CC dice "las contraídas", es decir, la obligación se contrajo

- como natural.
- ii. El Art. 2375 N° 1 CC niega la acción de reembolso cuando la obligación del deudor principal es puramente natural y no se ha validado por ratificación o lapso de tiempo, siendo sólo posible validar obligaciones antes de que se declare la nulidad.
- iii. El Art. 1470 N° 1 CC no habla de obligaciones nulas.

Importancia de la discusión: si se sigue la primera opinión, todo deudor que pague antes de la declaración de nulidad, paga una obligación civil, aunque los vicios que la hicieron anulable hayan desaparecido.

(2) Las que proviene de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, como la de pagar un legado, impuesto por un testamento que no se ha otorgado en la forma debida. (Art. 1470 N° 3)

¿A qué clase de actos se refiere?

- i. Se aplica tanto a los actos unilaterales como a los bilaterales.
- ii. Se aplica sólo a los unilaterales:
 - Normalmente la expresión "actos" se emplea para referirse a los actos unilaterales.
 - El ejemplo dado es un acto unilateral.
 - La norma fue tomada de Pothier que así lo entendió (razón histórica).
 - Sería injusto aplicarlo a los actos bilaterales. Ej. Se vende un bien raíz por instrumento privado, el comprador no podría obtener la tradición (porque el CBR no va a inscribir) ni tampoco la restitución del precio.

¿Desde cuándo existe obligación natural en este caso? La situación es igual al caso anterior, pero en vez de decir "las contraídas", dice "las que proceden". Además, no juega el argumento del Art. 2375 CC, porque tratándose de nulidad absoluta, no cabe ratificación.

2. OBLIGACIONES NATURALES PROVENIENTES DE OBLIGACIONES CIVILES DEGENERADAS.

(1) Obligaciones civiles extinguidas por prescripción (art. 1470 N° 2).

El Art. 1567 N° 10 CC contempla a la prescripción como un modo de extinguir las obligaciones, lo que no es efectivo, porque de acuerdo al Art. 1470 N° 2 CC, prescrita la obligación civil, se transforma en natural. En consecuencia, lo que se extingue por prescripción no es la obligación, sino la acción para exigir su cumplimiento.

¿Desde qué momento la obligación es natural?

- i. Desde que transcurre el tiempo para alegar la prescripción.
- ii. Desde que se declara la prescripción:
 - a) Antes de que se declare la prescripción existe una obligación civil.
 - b) Si se acepta la otra tesis, se confunden la renuncia de la prescripción y el cumplimiento de la obligación natural.

La mayoría de la doctrina nacional apoya la segunda tesis, pero la jurisprudencia se inclina por la primera.

(2) Obligaciones civiles que no han sido reconocidas en juicio por falta de pruebas (art. 1470 N° 4).

Para encontrarnos en esta situación deben cumplirse 3 requisitos:

1. Que haya habido un pleito demandándose el pago de la obligación.
2. Que el deudor haya ganado el pleito.
3. Que la absolución se deba a que el acreedor no pudo probar la existencia de la obligación. Si se debe a otro motivo, no hay obligación natural, y se produce la cosa juzgada.

5. Efectos de la obligación natural.

1) Pagadas, dan excepción para retener lo que se ha dado o pagado en virtud de ellas (Art. 1470 inc. 3º CC).

El pago debe reunir los siguientes requisitos:

1. Exigencias generales de todo pago.
2. Debe ser hecho voluntariamente por el deudor (Art. 1470 inc. final CC).

No hay unanimidad respecto de lo que esto significa:

- Que el deudor sepa que paga una obligación natural.
- Que el deudor pague en forma espontánea, sin coacción. Ésta doctrina ha sido seguida por la jurisprudencia.

3. Quien paga debe tener la libre administración de sus bienes (Art. 1470 inc. final CC). Esto debe entenderse como "libre disposición de sus bienes", pues todo pago supone transferir la propiedad del objeto pagado.

2) Pueden ser novadas: Art. 1630 CC. "Para que sea válida la novación es necesario que tanto la obligación primitiva como el contrato de novación sean válidos, a lo menos naturalmente."

2) Pueden ser caucionadas por terceros (Art. 1472 CC). La razón de que puedan ser caucionadas sólo por terceros es que al ser natural la obligación principal, el acreedor no tiene acción tampoco para demandar el cumplimiento de la caución, pues lo accesorio sigue la suerte de lo principal.

3) No producen la excepción de cosa juzgada: Art. 1471 CC. "La sentencia judicial que rechaza la acción intentada contra el naturalmente obligado, no extingue la obligación natural."

4) No pueden compensarse legalmente, pues no son actualmente exigibles (Art. 1656 N° 3 CC).

3.4. OBLIGACIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS.

Concepto.

Positiva: aquella en que el deudor se obliga a una determinada acción (dar o hacer).

Negativa: aquella en que el deudor debe abstenerse de realizar algo que, de no mediar la obligación, podría efectuar (no hacer).

Importancia de la distinción: en caso de incumplimiento:

- Las obligaciones negativas se rigen por el Art. 1555 CC.
- Además, la indemnización de perjuicios se debe, en las obligaciones positivas, desde que el deudor se constituye en mora; en las negativas, desde la contravención (Art. 1557 CC).

3.5. OBLIGACIONES DE ESPECIE O CUERPO CIERTO Y OBLIGACIONES DE GÉNERO.

1. Concepto.

Se aplica a las obligaciones de dar o entregar.

De especie o cuerpo cierto: aquellas en que la cosa debida está perfectamente especificada e individualizada. Se debe un individuo determinado de un género determinado.

De género: aquellas en que se debe un individuo de una clase o género determinado (Art. 1508 CC). Para que valga en cuanto objeto, la cantidad del género debe estar determinado o ser, al menos, determinable.

2. Importancia de la distinción.

1) Cómo se cumple.

Si la obligación:

- Es de especie, sólo se cumple pagando con la especie debida y no con otra, aun cuando sea de mayor valor (Art. 1569 inc. 2º CC).
- Si es de género, el deudor queda libre entregando cualquier individuo del género, que sea de una calidad a lo menos mediana (Art. 1509 CC).

2) Obligación adicional de cuidar la cosa.

- Si es de especie, el deudor tiene una obligación adicional: cuidar de la cosa (Art. 1548 CC).
- Si es de género, no existe esa obligación porque el género no perece (Art. 1510 CC).

3) La teoría de los riesgos opera exclusivamente en las obligaciones de especie.

4) Extinción de la obligación.

- La obligación de especie se extingue por la pérdida de la cosa debida (Art. 1567 N° 7 CC). Pero esto ocurre sólo si la pérdida es fortuita, pues si es culpable, la obligación subsiste, pero varía de objeto: precio de la cosa e indemnización de perjuicios (Art. 1672 inc. 1º CC).
- La obligación de género no se extingue por pérdida de la cosa debida (género no perece).

3.6. OBLIGACIONES DE DAR, HACER O NO HACER.

Esta clasificación la hace la ley.

Se desprende de los Arts. 1438 y 1460 CC.

1. Obligaciones de dar.

Son aquellas en que el deudor se obliga a transferir el dominio o a constituir un derecho real sobre la cosa en favor del acreedor.

Obligación de entregar: Art. 1548 CC. "La obligación de dar contiene la de entregar la cosa;...",

- dar y entregar no son sinónimos
- en la de entregar no hay obligación del deudor de transferir el dominio o constituir un derecho real.
- La obligación es simplemente de poner materialmente la cosa en manos del acreedor.

Naturaleza de la obligación de entregar.

En doctrina, es una obligación de hacer. Pero en Chile se le aplican las reglas de las obligaciones de dar:

- 1) Art. 1548 CC recién citado.
- 2) Los Arts. 1438 y 1460 CC sólo señalan las de dar, hacer y no hacer, englobando claramente a la de entregar en las primeras, pues no tiene nada en común con las demás.
- 3) De acuerdo a los Arts. 580 y 581 CC, las acciones son muebles o inmuebles según lo sea la cosa que se debe. Si la obligación de entregar es de hacer, la acción sería mueble, lo que resulta extraño en el caso de que la cosa debida sea inmueble, por Ej. en el caso de la acción de restitución en el arrendamiento.
- 4) De acuerdo a la historia fidedigna del CPC se deja constancia de que las reglas de procedimiento ejecutivo para obtener el cumplimiento de las obligaciones de dar se aplican también a las de entregar.

2. Obligaciones de hacer.

Son aquellas en que el deudor se obliga a realizar un hecho, que no sea la entrega de la cosa pues en ese caso se aplican las reglas de las obligaciones de dar.

- En algunos casos deberá ser cumplida personalmente por el deudor (cuando la obligación se contrae en consideración a su persona), caso en el que se habla de obligación de hacer no fungible.
- Si es indiferente la persona del deudor, puede cumplirla un tercero.

3. Obligaciones de no hacer.

Son aquellas en que el deudor debe abstenerse de efectuar un hecho que, de no existir la obligación, podría realizar. Ej. Prohibición contractual de no abrir un

negocio en cierto sector.

Algunos afirman que hay que diferenciar:

1) Obligaciones en que el deudor se obliga a abstenerse de desarrollar determinados actos, reflejada en la prohibición de hacer algo.

2) Obligaciones en que el deudor debe dejar hacer alguna cosa, es decir, tolerar una determinada actuación del acreedor, absteniéndose de perturbarla.

Pero hay quienes sostienen que esa distinción no es posible: el deudor se obliga, en definitiva, a la misma conducta omisiva, a un comportamiento negativo, con independencia de la existencia de otras actividades con las que ese comportamiento se relacione. Incluso se sostiene que una misma prestación puede ser definida positiva o negativamente, por lo que conviene atender a si la prestación consiste en una alteración del estado de cosas, o en el mantenimiento inalterable del mismo.

Importancia de la distinción entre obligaciones de dar, hacer y no hacer.

1) Acción mueble o inmueble. Para determinar la naturaleza mueble o inmueble de la acción destinada a exigir el cumplimiento:

- si es de hacer o no hacer, será siempre mueble;
- si es de dar, depende de la cosa.
-

2) Procedimiento ejecutivo. El procedimiento ejecutivo para obtener el cumplimiento forzado es distinto.

3) Modo de extinguir la obligación.

- El modo de extinguir pérdida de la cosa debida sólo se aplica a las de dar.
- El equivalente para las obligaciones de hacer es la imposibilidad absoluta para la ejecución actual de la obra debida (Art. 534 CPC).

4) Incumplimiento de la obligación en contratos bilaterales (posibilidad de demandar directamente la indemnización)

- La mayoría de la doctrina estima que en los contratos bilaterales, si se incumple la obligación de dar, el contratante diligente no puede demandar directamente la indemnización, pues es accesoria a las acciones de cumplimiento o resolución (Art. 1489 CC).
- Si la obligación es de hacer, se puede demandar directamente la
- indemnización (Art. 1553 N° 3 CC).

3.7 OBLIGACIONES DE DINERO Y DE VALOR.

1. Concepto.

Obligaciones de dinero: aquellas en que el objeto debido es una suma de dinero.

Obligaciones de valor o reparatorias: son aquellas en que lo adeudado no es dinero, sino una prestación diferente que se expresa en una determinada suma de dinero, en atención a ser éste una común medida de valores. Se dice que hay una de estas obligaciones cada vez que la prestación consiste en la devolución de una cosa o en el reembolso de un valor.

2. Características de las obligaciones de dinero.

- i. Son obligaciones de dar.
- ii. Son obligaciones de género (Art. 1508 CC).
- iii. Son obligaciones muebles (Art. 580 CC).
- iv. Son obligaciones divisibles (Art. 1524 CC).

3. El dinero, sus funciones económicas.

1. Instrumento de cambio: como tal, el dinero no cuenta por lo que es en sí, sino en razón de las posibilidades de adquisición que confiere.
2. Medida común de valores: es el metro que se ocupa para apreciar el valor de los demás bienes.
3. Medio de pago. Esta puede considerarse dentro de la primera.

4. Concepto y características del dinero.

Dinero: cosa mueble, fungible y divisible –metal o papel- que el comercio utiliza como medio de cambio e instrumento de pago y que constituye el medio de determinar el valor de los demás bienes. Incluye los instrumentos representativos de dinero.

En cuanto a su objeto, es un bien genérico, mueble, fungible, consumible y divisible, características que se traspasan a la obligación de dinero.

5. Función que cumple el dinero en las obligaciones.

- Como precio. Ej. Art. 1793 CC.
- Como renta o fruto civil.
- Como capital. Ej. Art. 2055 CC respecto del contrato de sociedad.
- Como retribución en ciertos contratos. Ej. Art. 2185 CC respecto del mandato.
- Como bien de reemplazo de la prestación de una obligación que no puede cumplirse en especie. Ej. Art. 1672 CC respecto de la pérdida de la especie por culpa del deudor.

6. Efectos de la mora de las obligaciones de dinero.

El CC da normas especiales para evaluar los perjuicios en el caso de incumplimiento (Art. 1559 CC).

7. Diferencia entre deudas de dinero y deudas de valor.

En la deuda de dinero, el deudor está obligado a entregar o restituir una suma de dinero. Ej. Obligación del mutuario de devolver la suma que recibió en préstamo.

En la de valor, se debe algo que no es dinero, pero que para su pago se avalúa en dinero. Ej. Obligación de indemnizar perjuicios.

8. Cumplimiento de una obligación de valor.

Para proceder a su pago será previo transformar esa obligación en una de dinero, mediante la liquidación de la deuda.

9. Cumplimiento de las obligaciones de dinero.

Hay dos formas de cumplir:

1. Entregando la suma numérica debida (criterio nominalista).
2. Pagando una suma de dinero que represente un determinado valor (criterio valorista).

Seguir uno u otro criterio lleva a resultados distintos, pues la inflación crea diferencias.

10. Nominalismo, valorismo. Criterio seguido en Chile.

De acuerdo al antiguo Art. 2199 CC, se seguía el criterio nominalista, y la jurisprudencia siempre estuvo con esa tesis.

Esta disposición fue derogada, pero seguimos con el sistema nominalista, pese a que se han dictado normas que para ciertas deudas han establecido la reajustabilidad. Ej.

- Art. 1734 CC: Todas las recompensas se pagarán en dinero, de manera que la suma pagada tenga, en lo posible, el mismo valor adquisitivo que la suma invertida al originarse la recompensa.

El partidor aplicará esta norma de acuerdo a la equidad natural.

- Art. 63 CdelT, etc.

Sin embargo, antes de que el legislador hiciera rectificaciones destinadas a ir incorporando sistemas de reajustabilidad legal, las partes se defendían de la desvalorización monetaria incluyendo una variedad de cláusulas de reajustabilidad.

11. Situación actual. El principio nominalista sigue siendo la regla general en materia de obligaciones, aplicándose algún sistema de reajuste cuando la ley, la convención o la resolución judicial así lo establecen.

Una de las primeras materias en que la jurisprudencia acogió la tesis valorista es en responsabilidad extracontractual, pues debe indemnizarse "todo daño" (Art. 2329 CC).

12. Obligaciones de dinero: obligaciones de crédito de dinero.

Dentro del género obligaciones de dinero existe un tipo especialmente regulado en Chile en la Ley 18.010: las obligaciones que provienen de una operación de crédito de dinero.

Los elementos que caracterizan a la operación de crédito de dinero son 3 (Art. 1º Ley 18.010):

- a) Que una parte entregue o se obligue a entregar una cantidad de dinero.
- b) Que la otra restituya dinero.
- c) Que el pago se haga en un momento distinto.

Respecto del primer elemento, constituye también operación de crédito de dinero el descuento de documentos representativos de dinero. Se asimilan al dinero los documentos representativos de obligaciones de dinero pagaderos a la vista, a un plazo contado desde la vista, o a un plazo determinado.

13. La reajustabilidad de una obligación dineraria.

Pueden las partes acordar cláusulas de reajustabilidad, adoptando al efecto las que juzguen adecuadas (UF, IPC, etc.)

14. La reajustabilidad en las operaciones de crédito de dinero.

La Ley 18.010 ha dejado entregado este aspecto a lo que acuerden las partes contratantes, pudiendo pactar la fórmula que estimen conveniente. Pero si en estas deudas interviene un banco, institución financiera o cooperativa de ahorro y crédito, el sistema de reajuste debe autorizarlo el Banco Central.

15. El deudor de una operación de crédito de dinero puede anticipar su pago (prepago).

Así lo establece el Art. 10 Ley 18.010, lo que es una excepción a la regla establecida para el mutuo en el Art. 2204 CC: el prepago sólo se permite cuando no se han convenido intereses.

La facultad de prepagar es irrenunciable.

16. Saldos de precios de compraventa.

Pese a que no debería regirse por las reglas de las operaciones de crédito de dinero, por excepción se le aplican ciertas disposiciones de la Ley 18.010 (Art. 26 Ley 18.010):

- Art. 2º Ley 18.010, referido a lo que se entiende por interés.
- Art. 8º Ley 18.010, referido al pacto de intereses que exceden el máximo convencional.
- Art. 10 Ley 18.010, referido a la facultad de prepagar.

17. Liquidación de una deuda reajutable, cobrada judicialmente.

El crédito se liquida a la fecha del pago, por el valor que tenga el capital reajustado según el índice pactado o la UF, según corresponda (Art. 25 Ley 18.010).

18. Liquidación de una deuda convenida en moneda extranjera.

Se pagan con su equivalente en moneda chilena, según el tipo de cambio vendedor del día de pago. Si la obligación está vencida, se aplica el tipo de cambio del día del vencimiento si es mayor al del día del pago (Art. 20 Ley 18.010).

Si se pactó el pago en moneda extranjera, debe cumplirse con la moneda estipulada.

19. Intereses.

Son un accesorio que normalmente acompaña a una obligación de dinero.

Se pueden pactar en dinero o cosas fungibles (Art. 2205 CC), pero en las operaciones reguladas por la Ley 18.010 sólo pueden pactarse en dinero (Art. 11 inc. 1º Ley 18.010).

Los intereses son la renta que produce un capital. Son frutos civiles (Art. 647 CC), y como tales, se devengan día a día (Art. 790 CC). Pueden encontrarse pendientes o percibidos.

Las simples obligaciones de dinero sólo generan intereses cuando las partes lo convienen o la ley lo establece. Pero si son pagados sin estar estipulados, no pueden repetirse (Art. 2209 CC).

En las operaciones de crédito de dinero, la regla se invierte: no se presume la gratuidad, y salvo disposición de ley o pacto en contrario, devengan interés corriente (Art. 12 Ley 18.010).

20. Clases de intereses.

1. Estipulados por las partes o fijados por ley.
2. Legales, corrientes y convencionales.
3. Interés por el uso del dinero e interés penal.

21. Intereses legales, corrientes y convencionales.

El interés legal y el corriente se confunden (Art. 19 Ley 18.010).

- **Interés legal.** Se debe aplicar el interés corriente en todos los casos en que las leyes refieran al interés legal o al máximo bancario (Art. 19 Ley 18.010).
- **Interés corriente.** Es el interés promedio cobrado por los bancos y las sociedades financieras establecidos en Chile en las operaciones que realicen en el país (Art. 6º Ley 18.010). Lo determina la Superintendencia de Bancos.
- **Interés convencional. Sus límites.** Es el interés que las partes acuerdan. Tanto para las operaciones de crédito de dinero, como para las obligaciones de dinero, el máximo interés permitido recibe el nombre de "interés máximo convencional". El artículo 6º inciso final de la Ley 18.010, modificado el año 2013, establece que "no podrá estipularse un interés que exceda el producto del capital respectivo y la cifra mayor entre: 1) 1,5 veces la tasa de interés corriente que rija al momento de la convención, según determine la Superintendencia para cada tipo de operación de crédito de dinero, y 2) la tasa de interés corriente que rija al momento de la convención incrementada en 2 puntos porcentuales anuales, ya sea que se pacte tasa fija o variable. Este límite de interés se denomina interés máximo convencional."

22. Sanción si se pacta un interés superior al máximo permitido. Se rebaja al interés corriente (Art. 2206 CC y Art. 8º Ley 18.010).

23. Intereses pactados por la mora que exceden al máximo permitido estipular. Quedan sujetos a los mismos límites, debiendo reducirse al corriente que rija al momento de la convención, y restituirse debidamente reajustados los excesos percibidos. Esto implica modificar el Art. 1544 CC, que ordena rebajar la cláusula penal en el mutuo al máximo de interés permitido estipular.

24. Anatocismo. Es la capitalización de intereses. El Art. 2210 CC lo prohibía en el mutuo, pero el Art. 28 Ley 18.010 lo derogó, por lo que se infiere que ya no está

prohibido. En el caso de las operaciones de crédito de dinero está especialmente autorizado (Art. 9º Ley 18.010).

La norma del Art. 1559 regla 3ª CC, relativa a la valuación legal, no prohíbe el anatocismo, sino que señala que no opera de pleno derecho, pero las partes pueden pactarlo.

Art. 1559 CC. "Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:

3.a Los intereses atrasados no producen interés."

3.8 OBLIGACIONES DE OBJETO SINGULAR Y OBLIGACIONES CON OBJETO PLURAL O COMPUESTAS.

1. Obligaciones de objeto singular:

Aquellas en que se debe una sola cosa, un hecho o una abstención.

- Incluyen aquella en que lo debido es una universalidad jurídica o de hecho.
- En ellas, el acreedor puede exigir la única cosa debida (Art. 1569 inc. 1º CC), y el deudor cumplirá pagándola en su integridad (Art. 1591 CC).
- Si la obligación es de dar una especie, y la cosa se pierde:
 - o Si se pierde fortuitamente, la obligación se extingue por el modo pérdida de la cosa debida (Arts. 1567 Nº 7 y 1670 CC).
 - o Si se pierde con culpa del deudor, debe pagar el precio más indemnización (Art. 1672 CC).
 - o Y si la obligación incide en un contrato bilateral y la cosa se pierde fortuitamente, opera la teoría de los riesgos (Art. 1550 CC).

2. Obligaciones compuestas o de objeto múltiple.

Son aquellas en que se deben varias cosas, pueden ser:

a) Obligaciones de simple objeto múltiple o acumulativas.

- Se caracterizan por la conjunción copulativa "y".
- El deudor debe la totalidad de las cosas y cumple pagándolas todas (el pago debe ser completo, Art. 1591 CC). Por ejemplo, se debe un auto **y** una bicicleta.
- Se les aplican las reglas de las obligaciones de objeto singular.
- Dentro de las obligaciones compuestas, las de simple objeto múltiple son la regla general. Las otras dos importan modalidades.
-

b) Obligaciones alternativas o disyuntivas.

Art. 1499 CC. "Obligación *alternativa* es aquella por la cual se deben varias cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas, exonera de la ejecución de las otras."

- Se caracterizan por la conjunción disyuntiva "o".
 - i. Hay varias cosas debidas, pero se cumple pagando totalmente una sola,

- elegida por quien tiene la alternativa (Art. 1500 inc. 1º CC).
- ii. La acción para demandar el cumplimiento es mueble o inmueble según lo sea la cosa con que se pague y la alternativa en que se cobre.
- iii. El acreedor sólo puede demandar la cosa en la alternativa en que se la deban, salvo que la elección sea suya (Art. 1501 CC)
- iv. Si los deudores o acreedores son varios, deben hacer la elección de consuno (Art. 1526 N° 6 CC).

Elección de las obligaciones alternativas⁷

-

Por regla general es del deudor (Art. 1500 inc. 2º CC). Importancia de saber de quién es:

1. Si es del deudor:
 - a) El acreedor no puede exigir determinadamente una de las cosas (Art. 1501 CC).
 - b) El deudor no tiene un deber de conservar todas las cosas: puede enajenar o destruir cualquiera de ellas cosas, mientras subsista al menos una (Art. 1502 inc. 1º CC).
2. Si es del acreedor:
 - a) Puede demandar cualquiera de las cosas.
 - b) Si entre ellas hay especies, el deudor tiene la obligación de cuidarlas, ya que el acreedor puede exigir cualquiera de ellas (Art. 1548 CC).

Pérdida de las cosas debidas alternativamente.

Pérdida total (todas las cosas):

- Pérdida fortuita: se extingue la obligación (Art. 1504 inc. 1º CC).
- Pérdida culpable: el deudor debe pagar el precio de una de ellas, más indemnización. La determinación de cuál cosa depende de quién tenga la elección (Art. 1504 inc. 2º CC).

Pérdida parcial:

- Pérdida fortuita: subsiste la obligación alternativa en las otras cosas, y su queda una sola, el deudor debe esa (Art. 1503 CC).
- Pérdida culpable:

A) Si la elección es del deudor, puede elegir cualquiera de las cosas que resten.

B) Si la elección es del acreedor, puede optar entre elegir una de las que subsisten, o demandar el precio de la destruida más indemnización de perjuicios.

Si la cosa se deteriora, se aplica el Art. 1590 CC.

c) Obligaciones facultativas.

Art. 1505 CC. "Obligación *facultativa* es la que tiene por objeto una cosa determinada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa."

⁷ La posibilidad de elegir permite contratar cuando la voluntad no se ha decidido entre diversas alternativas.

Elementos de una obligación facultativa.

- i. La cosa debida es una sola. Si el deudor no cumple, sólo se puede demandar ésa (Art. 1506 CC), y la acción será mueble o inmueble según lo sea la cosa debida.
- ii. El deudor queda facultado para pagar con lo debido o con una cosa distinta, que se designa.
- iii. Esta facultad le debe ser otorgada al deudor al momento de contratar.
 - Si se acuerda al momento del pago, hay una dación en pago;
 - Si se acuerda después de celebrado el contrato y antes del pago, hay novación por cambio de objeto.

Pérdida de la cosa debida en el caso de la obligación facultativa.

- Si se destruye fortuitamente antes de haberse constituido el deudor en mora, no puede el acreedor demandar cosa alguna (Art. 1506 parte final CC).
- Si se destruye culpablemente, la obligación subsiste, pero varía de objeto: precio de la cosa más indemnización.
- La pérdida de la cosa facultativamente debida carece de trascendencia para el acreedor.

Las obligaciones facultativas no se presumen.

Art. 1507 CC. "En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se tendrá por alternativa."

Algunas diferencias entre obligaciones alternativas y facultativas.

1. Cosas debidas.

- En las alternativas, las cosas debidas son varias;
- En las facultativas, una sola.

2. Elección.

- En las alternativas, la elección puede ser de cualquiera de los dos;
- En la facultativa, sólo del deudor.

3. Cosa que puede demandar el acreedor.

- En las alternativas, cuando la elección es del acreedor, puede elegir cualquiera;
- en las facultativas el acreedor sólo puede demandar la cosa debida.

4. Hay diferencias en cuanto a los efectos de la pérdida de la cosa.

3.9 OBLIGACIONES CON UNIDAD Y PLURALIDAD DE SUJETOS.

1. Obligación con unidad de sujeto: aquella en que existe un acreedor y un deudor.

2. Obligación con pluralidad de sujetos: aquella en que:

- Hay un acreedor y varios deudores (pluralidad pasiva),
- Varios acreedores y un deudor (pluralidad activa),

- Varios acreedores y varios deudores (pluralidad mixta). El Art. 1438 CC autoriza expresamente la pluralidad.

La pluralidad puede ser:

- 1) Originaria: la obligación nace con pluralidad de sujeto.
- 2) Derivativa: la obligación nace con unidad de sujeto y se transforma en plural.

Las obligaciones con pluralidad de sujetos, al ser relacionadas con la pluralidad de prestación, pueden tener 3 modalidades:

- a) Simplemente conjuntas o mancomunadas.
- b) Solidarias.
- c) Indivisibles.

3.9.1. OBLIGACIONES SIMPLEMENTE CONJUNTAS O MANCOMUNADAS

1. Concepto.

Son aquellas en que,

- (1) existiendo pluralidad de acreedores o de deudores,
- (2) y recayendo sobre una cosa divisible,
- (3) cada acreedor sólo puede exigir su cuota a cada deudor, que sólo está obligado a la suya.

2. Características de las obligaciones simplemente conjuntas.

1. Constituyen la regla general (Art. 1511 y 1526 CC).
2. Independencia absoluta entre los distintos vínculos; se trata de obligaciones distintas.
3. Deben recaer sobre un objeto divisible, para que puedan cumplirse por partes.
4. La regla general es que la división se haga por partes iguales, a menos que la ley o el hombre establezcan otra proporcionalidad. (Art. 2307 inc. 2º CC respecto de la comunidad; Art. 2367 inc. 1º CC respecto de la fianza). Un caso en que se establece una proporción distinta es el del Art. 1354 CC, relativo a los herederos que dividen las deudas hereditarias a prorrata de sus cuotas.

3. Efectos de las obligaciones simplemente conjuntas.

1. Cuota. Cada acreedor puede cobrar su cuota; cada deudor está sólo obligado a la suya.
2. Extinción de la obligación. La extinción de la obligación respecto de un deudor no extingue la obligación respecto de otros.
3. Cuota del deudor insolvente. La cuota del deudor insolvente no grava a los demás.
4. Interrupción de la prescripción. La interrupción de la prescripción que opera a

favor de un acreedor no favorece a los demás, y la interrupción que afecta a un deudor no perjudica a los demás (Art. 2519 CC).

5. Nulidad. La nulidad declarada respecto de un deudor o de un acreedor no afecta a los demás, porque es de efectos relativos (Art. 1690 CC).

6. Mora. La mora de un deudor o coloca en mora a los otros.

7. Incumplimiento de un deudor. Si uno de los deudores incumple su obligación y se genera responsabilidad contractual, ésta sólo afecta al incumplidor (Arts. 1526 N° 3 y 1540 CC).

8. Excepciones. Cada deudor demandado puede oponer a la demanda las excepciones reales, y únicamente las excepciones personales suyas.

9. Prórroga de la competencia. La prórroga de la competencia que opera a favor de un deudor no afecta a los demás.

10. Resolución de contrato bilateral. Cuando en un contrato bilateral hay varios acreedores, el contratante diligente puede pedir por sí solo, sin necesidad de ponerse de acuerdo con los demás, la resolución del contrato bilateral de objeto único. Esto es discutible, pues se sostiene que si hay varios acreedores, la obligación se transforma en alternativa, y tienen que ponerse de acuerdo para elegir entre el cumplimiento o la resolución (Art. 1526 N° 6 CC).

3.9.2 OBLIGACIONES SOLIDARIAS O INSOLIDUM

1. Concepto.

Son aquellas en que:

- (1) habiendo pluralidad de acreedores o de deudores, o pluralidad de ambos,
- (2) y recayendo la obligación en un objeto divisible,
- (3) cada acreedor puede exigir la totalidad de la obligación a cualquiera de los codeudores y cada deudor está obligado a la totalidad de la deuda, de modo que cumplida así la obligación, ella se extingue. (Art. 1511 inc. 2º CC).

2. La solidaridad es excepcional y no se presume.

Así aparece del Art. 1511 incs. 2º y final CC. Consecuencias:

1. Para que haya solidaridad tiene que haber una fuente de la solidaridad: convención, testamento o ley. No cabe que se declare por sentencia judicial.
2. La solidaridad es de derecho estricto y de interpretación restringida.
3. Quien alegue la solidaridad debe probarla.

3. Clases de solidaridad. La solidaridad admite distintas clasificaciones.

1) Activa, pasiva o mixta, según haya pluralidad de acreedores, deudores o ambos.

La realmente importante es la pasiva, pues es una garantía muy eficaz.

2) Según su fuente, puede ser **legal o voluntaria**. Ej. Solidaridad legal: Art. 2317 CC, respecto de la responsabilidad extracontractual.

3) Perfecta e Imperfecta.

- Perfecta: es la que produce todos los efectos propios de la solidaridad.
- Imperfecta: produce sólo algunos. En Chile no se aplica.

4. Elementos de la solidaridad.

1. Pluralidad de acreedores o de deudores.
2. La cosa debe ser divisible.
3. La cosa debida debe ser la misma (Art. 1512 CC).
4. Fuente de la solidaridad: la convención, el testamento o la ley. La sentencia judicial no es fuente de la solidaridad.

5. Unidad de prestación y pluralidad de vínculos.

La cosa debida por los deudores es la misma, pero cada uno de ellos puede deberla de diferente manera; los vínculos pueden ser distintos (Art. 1512 CC). Consecuencias:

1. Modalidades. Algunos de los vínculos pueden estar sujetos a modalidades.
2. Causa. La causa de las obligaciones puede ser diversa.
3. Plazos. Los plazos de prescripción pueden ser diversos, según la naturaleza del vínculo.
4. Nulidad. Puede ser válida la obligación respecto de uno, y nula respecto de otro.
5. Título Ejecutivo. Respecto de uno de los deudores puede existir título ejecutivo, y no respecto de los otros.
6. Crédito privilegiado. El acreedor que tiene un crédito que goza de privilegio respecto de un deudor no puede invocarlo respecto a los bienes de un codeudor solidario.

6. Naturaleza jurídica de la solidaridad.

1. **Teoría romana:** cada acreedor es mirado como propietario exclusivo de la totalidad del crédito.
2. **Teoría francesa o del mandato tácito y recíproco:** cada acreedor es dueño sólo de su cuota en el crédito, y respecto de las otras actúa como mandatario de los demás acreedores.

Importancia de seguir una u otra teoría: de acuerdo a la primera, cada acreedor puede no sólo cobrar la deuda, sino también perdonarla, lo que no ocurre en la segunda, pues no se puede suponer un mandato para condonar la deuda.

7. Teoría seguida en Chile.

Se sigue la tesis romana (Sólo respecto de la solidaridad activa)

- Art. 1513 inc. 2º CC (que permite a uno de los acreedores condonar la

deuda).

- Dos notas de Bello así lo muestran.

Pero esto es efectivo sólo respecto de la solidaridad activa, pues respecto de la pasiva se siguió la teoría francesa, aunque produce dudas el Art. 1521 CC relativo a la destrucción culpable de la cosa. La jurisprudencia se ha inclinado por esta opción. Importancia de que se siga la teoría francesa en materia de solidaridad pasiva:

- Si se demanda a un deudor y el acreedor pierde el juicio, no podría demandar a otro, pues habría identidad legal de personas (representante y representado).
- Además, ocurrida la prórroga de la competencia respecto de un deudor, operaría respecto de todos, porque éste actuaría por sí y como mandatario de los otros aceptando la prórroga.

3.9.2.1 SOLIDARIDAD ACTIVA

1. Concepto.

- (1) Existen varios acreedores de una obligación
- (2) con objeto divisible,
- (3) y cualquiera de ellos puede exigir su pago total,
- (4) de manera que, cumplida de esa forma, se extingue la obligación.
- Importante: El deudor puede pagar a cualquiera, salvo que uno de ellos lo haya demandado. Esto ocurre con cualquier modo de extinguir la obligación, no sólo con el pago (Art. 1513 CC).

2. No hay solidaridad activa legal.

Su fuente sólo puede ser el testamento o el acuerdo de las partes. No es excepción a esto el Art. 290 CCom, pues se refiere realmente a un caso de solidaridad pasiva.

3. La solidaridad activa tiene graves inconvenientes y pocas ventajas.

El grave inconveniente es que un acreedor cobre y luego caiga e insolvencia, con lo que los demás acreedores no pueden recuperar su parte.

Además, en atención a que se sigue la teoría Romana en cuanto a su naturaleza jurídica, otro riesgo de la solidaridad activa es que uno de los deudores condone la deuda.

Las ventajas son pocas: facilitar el cobro de un crédito y facilitar al deudor el pago.

4. Efectos de la solidaridad activa.

Hay que distinguir entre las relaciones externas, entre el acreedor y el deudor y las internas, entre los acreedores.

1) Relaciones externas.

1. Qué puede demandar cada acreedor. Cada acreedor puede demandar el total de la obligación (Art. 1511 inc. 2º CC).

2. A quién puede pagar el deudor. El deudor puede hacer el pago al acreedor que elija, a menos que ya estuviere demandado, pues en tal caso sólo puede pagar al demandante (Art. 1513 inc. 1º CC). Pagando de esta manera, se extingue la obligación respecto de todos los acreedores.

3. MEO. Los otros modos de extinguir las obligaciones que operen entre el deudor y un acreedor extinguen la obligación respecto de todos, a menos que el deudor ya estuviera demandado por uno de ellos (Art. 1513 inc. 2º CC).

4. Interrupción de la prescripción. La interrupción de la prescripción que aprovecha a un acreedor beneficia a los otros (Art. 2519 CC). Respecto de la suspensión, rige la regla general de que no aprovecha a los otros, pues la ley no dice nada. Pero da lo mismo, porque basta que uno de los acreedores tenga el beneficio para que el asunto se resuelva cobrando él el crédito.

5. Mora. La constitución en mora que hace un acreedor constituye en mora al deudor respecto de todos los acreedores.

6. Medidas precautorias. Las medidas precautorias en favor de un acreedor favorecen a los otros.

2) Relaciones internas.

El acreedor que cobró el total deberá reembolsar a los demás su respectiva cuota, a menos que haya algunos no interesados, caso en que nada les corresponde. Cada uno de los otros acreedores no podrá reclamar sino la proporción que le corresponde, a prorrata de su cuota, pues la solidaridad sólo existe entre los acreedores solidarios y el deudor.

Si la obligación se declaró nula respecto de uno de los acreedores, cualquiera de los otros puede demandar el total, deducida la cuota correspondiente a esa parte de la obligación. Pero si antes de la declaración de nulidad, el deudor había pagado el total, no puede después pedir restitución.

3.9.2.2 SOLIDARIDAD PASIVA

1. Concepto

- (1) Existiendo varios deudores,
- (2) y recayendo la obligación en un objeto divisible,
- (3) el acreedor puede demandar la totalidad del crédito a cualquiera de ellos, extinguiéndose la obligación respecto de todos.

2. Características de la solidaridad pasiva.

1) Es una **garantía para el acreedor**, pues:

- Puede dirigir la acción contra el deudor más solvente.
- Como garantía, es mejor que la fianza, pues no hay beneficio de excusión ni de división.
- Si una persona se obliga como fiador y codeudor solidario, significa que es un codeudor solidario sin interés en la obligación, lo que le va a beneficiar al momento de resolver las relaciones internas. La doctrina y la jurisprudencia sostienen que, frente al acreedor, esta persona es un deudor solidario y deben regirse por las reglas de la solidaridad.

- Esto no es lo mismo que ser fiador solidario, caso en que habiendo varios fiadores, éstos se han obligado solidariamente entre sí. Cada uno responde por el total, pero como fiador, es decir, subsidiariamente, con beneficio de excusión.

2) Tiene mucha **aplicación en derecho mercantil**. Ej. Firmantes de la letra de cambio.

3) Presenta todos los caracteres que hemos visto para la solidaridad. **Sus fuentes pueden ser la convención, el testamento o la ley.**

4) Respecto de ella, **se sigue la teoría francesa del mandato tácito y recíproco.**

3. Efectos de la solidaridad pasiva.

Hay que distinguir entre las relaciones externas (obligación a la deuda) y las internas (contribución a la deuda).

1) Relaciones externas. Obligación a las deudas.

1. Contra quien puede dirigirse el acreedor y por cuánto. El acreedor puede dirigirse en contra de todos los deudores conjuntamente, o en contra de cualquiera de ellos por el total de la deuda, sin que éste le pueda oponer el beneficio de división (Art. 1511 y 1514 CC). El acreedor debe ser cuidadoso, pues si acciona contra un codeudor solo por su cuota, se entiende renunciada la solidaridad.

a) Si el juicio se sigue en contra de un deudor, no se pueden embargar bienes a otro.

b) El hecho de demandar a un codeudor no significa que no se pueda demandar a otro en juicio aparte (Arts. 1514 y 1515 CC). Pero no deja de resultar violento admitir la posibilidad de que un acreedor pueda demandar en forma paralela la totalidad de la obligación a cada uno de los codeudores. Sin embargo, si se sigue la teoría del mandato tácito y recíproco, la sentencia dictada en contra de un codeudor produce cosa juzgada respecto de los otros ya que habría identidad legal de persona, y al ser la cosa juzgada una excepción real, compete a todos los deudores.

2. Extinción de la obligación. Si el deudor demandado paga el total de la obligación o la extingue por cualquier modo, tal extinción opera respecto de todos los codeudores solidarios (Arts. 1519, 1520 y 1668 CC).

3. Demanda a un deudor. Si el acreedor demanda a un deudor y no obtiene el pago total, podrá dirigirse en contra de cualquiera de los otros, por el saldo (Art. 1515 CC).

4. Título ejecutivo. El título ejecutivo contra el deudor principal lo es también en contra del fiador y codeudor solidario. Esto se discute por los siguientes argumentos:

- Los títulos ejecutivos deben bastarse a sí mismos.
- El Art. 1512 es claro en cuanto a que, si bien la cosa debida es la misma, puede deberse de diversos modos.

Por tanto, el hecho de que exista título ejecutivo en contra de un deudor, no significa que también lo haya en contra de los demás.

5. Sentencia. La sentencia dictada en contra de un codeudor produce la cosa juzgada respecto de los otros:

- Hay identidad legal de personas, basándose en el mandato tácito.
- La cosa juzgada es una excepción real, y compete a todos los deudores.

6. Interrupción de la prescripción. La interrupción de la prescripción que se opera en contra de uno de los deudores solidarios perjudica a los otros (Art. 2519 CC).

- Pero en virtud del principio de la pluralidad de vínculos, puede la prescripción empezar a correr en momentos distintos.
- No existe el problema de la suspensión, porque es un beneficio en favor del acreedor, y hay uno solo.

7. Mora. Producida la mora respecto de un deudor, quedan también constituidos en mora los otros.

8. Pérdida de la especie debida. La pérdida de la especie debida por culpa de uno de los codeudores genera responsabilidad para todos respecto del pago del precio, pero no respecto de la indemnización de perjuicios, que sólo debe pagar el culpable (Art. 1521 CC). Se discute que ocurre si son dos o más los culpables:

- a) Cada deudor responde de los perjuicios sólo por su cuota, salvo que haya dolo o culpa grave, caso en que hay responsabilidad solidaria.
- b) Responden solidariamente:
 1. Siendo culpables todos, es más útil que la acción sea solidaria.
 2. Art. 1526 N° 3 CC. "Aquel de los codeudores por cuyo hecho o culpa se ha hecho imposible el cumplimiento de la obligación, es exclusiva y solidariamente responsable de todo perjuicio al acreedor."

9. Prórroga de la competencia. La prórroga de la competencia respecto de un deudor afecta a todos, basándose en el mandato tácito.

10. Cesión del crédito. Si el acreedor cede su crédito a un tercero, no es necesario que se notifique la cesión a todos o que todos tengan que aceptarla (Art. 1902 CC). Basta que se notifique a cualquiera de los deudores, basándose en el mandato tácito.

❖ **Excepciones que puede oponer el deudor demandado.**

Dado que la solidaridad supone una pluralidad de vínculos, las excepciones que puede oponer cada codeudor solidario pueden ser distintas. La regla general está contenida en el artículo 1520 incº1 CC:

Art. 1520 CC. El deudor solidario demandado puede oponer a la demanda todas las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación, y además todas las personales suyas.

Además, es importante tener en cuenta que el deudor no tiene el beneficio de división.

(Art. 1514 CC).

Así, para determinar en concreto qué excepciones puede oponer un codeudor reconvenido judicialmente, es necesario distinguir entre las excepciones reales, personales y mixtas.

- Excepciones reales: Son aquellas que emanan de la naturaleza de la obligación y, por tanto, pueden ser opuestas por cualquiera de los codeudores. Se caracterizan por ser inherentes a la obligación principal (art. 2354 CC, a propósito de la fianza) y, por consiguiente, por no tener como requisito ningún atributo particular de la persona que las invoca. Ejemplos: algunos modos de extinguir las obligaciones como el pago, la prescripción o la pérdida fortuita de la cosa que se debe; vicios de que adolece la fuente de la obligación y que den lugar a la nulidad absoluta; la cosa juzgada; la excepción de contrato no cumplido.
- Excepciones personales: Son aquellas que emanan de hechos jurídicos que dicen relación con determinados deudores y, por consiguiente, solo pueden ser opuestas por ellos. Ejemplos: causales de nulidad relativa.
- Excepciones mixtas: Son aquellas que, si bien son personales en tanto emanan de un hecho jurídico particular relativo a un codeudor determinado, pueden ser opuestas por los demás codeudores. Ejemplos: compensación y remisión parcial de la deuda.

Respecto a la compensación, es necesario precisar que, en principio, la compensación es una excepción personal, pues ésta solo puede ser opuesta por el codeudor solidario que es, a su vez, acreedor del demandante. Pero una vez opuesta por éste, en caso de ser demandados nuevamente, los demás codeudores podrían oponer esa compensación como excepción. En otras palabras, la compensación opera primero como excepción personal, y una vez extinguida la compensación por esa vía opera como excepción real.

Respecto a la remisión parcial de la deuda, esta solo puede ejercerla el codeudor condonado. Sin embargo, de acuerdo con el art. 1518 CC, los demás codeudores pueden oponer dicha excepción para que se les rebaje la cuota correspondiente.

❖ **Entablado un juicio en contra de uno de los codeudores solidarios, ¿podría otro intervenir en este juicio?**

Si aceptamos que la sentencia va a producir cosa juzgada respecto de todos, entonces cada uno tiene un legítimo interés en el resultado del juicio, pudiendo intervenir como tercero coadyuvante (Art. 23 CPC).

2) Relaciones internas. Contribución a las deudas.

Para pasar de la etapa de obligación a la deuda, a la etapa de contribución a la deuda, es necesario que alguno de los deudores haya extinguido la deuda mediante el pago u otro medio equivalente, (art. 1522 CC). Lo relevante es que exista un sacrificio pecuniario por parte de quien extinguió la obligación, de otro modo no podrá dirigirse en contra de los demás deudores.

Respecto de las relaciones entre los codeudores, es necesario distinguir si todos tienen interés en la deuda, o si sólo algunos tienen interés en ella, y en este último caso, será necesario subdistinguir si quien pagó era uno de los interesados o no, ya que de cada uno de estas hipótesis se derivan diferentes consecuencias jurídicas.

El criterio para la distinción entre codeudores interesados y no interesados está establecido en el artículo 1522, inciso segundo: "si el negocio para el cual ha sido contraída la obligación solidaria, concernía solamente a alguno o algunos de los deudores solidarios (...)". De esta forma, vemos que el criterio seguido por el legislador apunta a una dimensión económica, a saber, a quién concernía el negocio para el cual la obligación fue contraída. Así, por ejemplo, si tres personas compran una casa que servirá de residencia para dos de ellas, y se obligan solidariamente al pago, solo las dos que residirán en dicha casa son interesados en esa obligación.

(1) Si todos los deudores tienen interés en la obligación:

- El deudor que paga se subroga en el crédito, con todos sus privilegios y seguridades, (Art. 1610 n° 3 CC)
- y puede dirigirse en contra de los demás deudores, pero sólo por su cuota, incluida la del deudor insolvente.
- No se subroga en la solidaridad (Art. 1522 inc. 1° CC). Sólo podrá cobrar la cuota estipulada a los demás codeudores. Si nada se ha dicho, la cuota se determina por el interés que cabe a cada uno en la deuda, que se presume igual, a menos que se pruebe lo contrario.
- El deudor que paga tiene además de la **acción subrogatoria**, una **acción personal de reembolso**, que emana del mandato tácito, y que le puede convenir más porque le permite cobrar intereses corrientes (Art. 2158 N° 4 CC).

(2) Si sólo algunos deudores tienen interés en la obligación, es necesario volver a distinguir:

- **Si pagó un codeudor interesado:**
 - Se subroga en la acción del acreedor y puede dirigirse en contra de cada uno de los deudores interesados por su cuota.
 - No puede dirigirse contra los no interesados, porque sólo son fiadores (Art. 1522 inc. 2° CC).
- **Si pagó un codeudor no interesado:** el Art. 1522 inc. 2° CC lo considera como fiador, por lo que se subroga en la acción del acreedor, e incluso en la solidaridad (Art. 2372 CC).

4. Extinción de la solidaridad pasiva.

Puede extinguirse:

1) Conjuntamente con la obligación solidaria, o

2) Extinguirse por vía principal, es decir, sólo la solidaridad:

a) Muerte del deudor solidario. Los herederos suceden en la obligación,

pero no en la solidaridad: todos los herederos están obligados al pago total de la deuda, pero cada heredero será solamente responsable de aquella cuota de la deuda que corresponda a su porción hereditaria (Art. 1523 CC).

Sin embargo, no se extingue la solidaridad si así se ha convenido, lo que está permitido (Arts. 1526 N° 4 y 549 CC).

b) Renuncia de la solidaridad. El acreedor puede renunciar a la solidaridad, pues está establecida en su solo beneficio (Art. 12 CC).

- La renuncia es el acto en cuya virtud el acreedor prescinde de su derecho a cobrar el total de la obligación, sea respecto de todos los deudores (renuncia absoluta o total), sea respecto de algunos (renuncia relativa o parcial).
- En cuanto a su forma, la renuncia puede ser (Art. 1516 CC):
 - a) Expresa: se hace en términos formales y explícitos.
 - b) Tácita: se renuncia tácitamente a favor de un deudor cuando se le exige o reconoce el pago de su parte o cuota, expresándolo así en la demanda o en la carta de pago, sin reserva especial de solidaridad, o sin reserva general de sus derechos.

Efectos de la renuncia:

1. Si es parcial, el deudor liberado de la solidaridad sólo está obligado a pagar su cuota o parte en la deuda, continuando los demás obligados solidariamente al pago en la parte del crédito que no haya sido cubierta por el deudor a cuyo beneficio se renunció la solidaridad (Art. 1516 inc. 3º CC).
2. Si es total: se convierte la obligación en simplemente conjunta. Se renuncia totalmente cuando se consiente en dividir la deuda (Art. 1516 inc. final CC).

Se puede renunciar la solidaridad, cualquiera sea su fuente.

Respecto de la renuncia en una pensión periódica, se limita a los pagos devengados; no hay renuncia futura tácita (Art. 1517 CC).

3.9.3 OBLIGACIONES DIVISIBLES E INDIVISIBLES

1. Concepto.

Obligación indivisible: es aquella en que el objeto de la prestación debe cumplirse por el todo y no por partes, sea por la naturaleza misma del objeto, sea por el modo que han tenido las partes para considerarlo.

2. La indivisibilidad de una obligación puede darse en obligaciones con sujetos únicos o plurales, porque no mira a los sujetos, sino al objeto de la prestación.

Art. 1524 inc. 1º CC. "La obligación es *divisible* o *indivisible* según tenga o no por objeto una cosa susceptible de división, sea física, sea intelectual o de cuota."

En las obligaciones en que hay sujetos únicos, no tiene importancia la indivisibilidad, porque el deudor debe pagar la totalidad. Importa cuando hay pluralidad de sujetos, pues revierte la regla general de que cada acreedor tiene derecho a exigir su cuota, y cada deudor sólo está obligado por la suya.

3. Indivisibilidad física e indivisibilidad intelectual o de cuota.

1. Divisibilidad física o material: una cosa es físicamente divisible cuando, sin destruirse, puede fraccionarse en partes homogéneas entre sí y con respecto al todo primitivo, no sufriendo menoscabo considerable el valor del conjunto de aquellas en relación con el valor de éste.

2. Divisibilidad intelectual o de cuota: una cosa es intelectualmente divisible cuando puede fraccionarse en partes ideales, abstractas, imaginarias, aunque no lo pueda ser materialmente. Todas las cosas admiten esta división, salvo que la ley lo impida. Ej. Propiedad fiduciaria (Art. 1317 CC).

4. Fuente de la indivisibilidad.

1. Indivisibilidad natural: la cosa debida, por su propia naturaleza, no puede dividirse.

- i. Indivisibilidad absoluta o necesaria: el objeto de la obligación, la prestación, por su propia naturaleza, no se puede cumplir por partes. Ej. Servidumbre de tránsito.
- ii. Indivisibilidad relativa: proviene del fin que las partes se propusieron al momento de contratar la obligación. Ej. Varias personas se obligan a construir una casa.

2. Indivisibilidad convencional o de pago: la indivisibilidad proviene del acuerdo expreso de los contratantes en orden a que no se pueda cumplir por partes.

Ventajas sobre la solidaridad: en la solidaridad, si fallece uno de los deudores, la deuda se divide entre sus herederos, en cambio, si se conviene que la deuda no puede cumplirse por partes ni aun por los herederos del deudor, la deuda es indivisible.

5. La indivisibilidad en las obligaciones de dar, entregar, hacer y no hacer.

1. La obligación de dar es divisible cuando la prestación consiste en una determinada cantidad de cosas fungibles.. Excepcionalmente, algunos derechos son indivisibles, por expresa disposición legal.

2. La obligación de entregar es divisible si la cosa admite división física; es indivisible si se debe entregar una especie.

3. La obligación de hacer es divisible o indivisible según pueda o no cumplirse

por partes el hecho debido.

4. La obligación de no hacer es divisible o indivisible según lo sea la cosa que no debe hacerse.

Algunos estiman que la clasificación no se aplica a las obligaciones de no hacer, o que se aplica de manera muy limitada, pues en caso de contravención, el acreedor sólo puede demandar indemnización de perjuicios. Pero la mayoría estima que sí se aplica.

3.9.3.1 INDIVISIBILIDAD ACTIVA

Efectos de la indivisibilidad activa.

1. Qué puede exigir cada acreedor. Cada acreedor puede exigir el total, por la naturaleza de la prestación (Art. 1527 CC). Por eso es que la indivisibilidad se transmite a los herederos del acreedor (Art. 1528 parte final CC).

2. Extinción de la obligación. El pago efectuado por el deudor a cualquier acreedor extingue la obligación respecto de todos.

3. Facultad restringida de los acreedores. Ninguno de los coacreedores puede, sin el consentimiento de los demás, remitir la deuda o recibir el precio de la cosa (Art. 1532 CC).

4. Interrupción de la prescripción. La interrupción de la prescripción operada por uno de los acreedores aprovecha a los demás, principio que se desprende del Art. 886 CC, relativo a las servidumbres. En cuanto a la suspensión, sólo favorece al acreedor que tiene el beneficio, pero es discutible.

5. Deber del acreedor que recibe el pago. El acreedor que recibe el pago de la obligación indivisible debe dar a los otros la parte que le corresponde.

3.9.3.2 INDIVISIBILIDAD PASIVA

Efectos de la indivisibilidad pasiva.

Hay que distinguir las relaciones externas de las internas.

1) Relaciones externas. Obligación a la deuda.

1. Obligación de los deudores. Cada uno de los deudores es obligado a cumplirla en el todo, aunque no se haya convenido solidaridad (Art. 1527 CC).

2. Interrupción de la prescripción. La prescripción interrumpida respecto de uno de los deudores, lo es igualmente respecto de los otros (Art. 1529 CC).

3. Extinción de la obligación. El cumplimiento de la obligación por cualquiera de los deudores la extingue para todos (Art. 1531 CC).

4. Plazo para que los deudores se entiendan. Demandado uno de los deudores, puede pedir un plazo para entenderse con los demás deudores, a fin de cumplir entre todos. Esta es una excepción dilatoria que no cabe si la obligación es de tal naturaleza que él solo pueda cumplirla (Art. 1530 CC).

2. Relaciones internas. Contribución a las deudas.

El que pagó tiene derecho a que los demás le paguen la indemnización correspondiente (Art. 1530 CC).

3.9.3.3 INDIVISIBILIDAD DE PAGO

Las obligaciones indivisibles en cuanto al pago son

- (1) aquellas cuyo objeto es perfectamente divisible, física o intelectualmente,
- (2) pero que no deben ejecutarse por parcialidades
- (3) en virtud de la voluntad de las partes o de la ley que presume esa voluntad.

La obligación debe ser cumplida por cada deudor por el total. Se trata de excepciones a la divisibilidad de las obligaciones (Art. 1526 CC).

Casos del Artículo 1526.

- Todos estos casos corresponden a indivisibilidades de pago pasivas.
- La disposición es taxativa.

1. Art. 1526 N° 1. La acción hipotecaria o prendaria

Es consecuencia de que la prenda y la hipoteca son indivisibles:

- En cuanto al objeto, porque gravan toda la cosa.
- En cuanto al crédito garantizado, porque mientras no se satisface íntegramente, no puede pedirse el alzamiento de parte de la hipoteca o la devolución de parte de la prenda.
- En cuanto al legitimado pasivo, que es quien posea en todo o en parte la cosa empeñada o hipotecada.

La indivisibilidad está referida exclusivamente a la acción prendaria o hipotecaria, no a la personal, que es divisible, salvo que las partes hayan acordado también su indivisibilidad.

Se demanda a quien está poseyendo la cosa por el total de la deuda.

2. Art. 1526 N° 2. Deuda de una especie o cuerpo cierto

El deudor que posee la especie debe entregarla. Se refiere a la entrega material, no a la jurídica, que es divisible.

3. Art. 1526 N° 3. Indemnización de perjuicios por incumplimiento de un codeudor

El deudor por cuya culpa se hace imposible el cumplimiento de la obligación, es exclusiva y solidariamente responsable de todo perjuicio al acreedor.

“Solidariamente” no está entendido en sentido técnico, sino para significar que responde solo por la totalidad de los perjuicios.

4. Art. 1526 N° 4. Pago total de una deuda impuesta a un heredero; e indivisibilidad estipulada por el causante.

La norma trata 3 situaciones diferentes:

- i. Pago de una deuda impuesta a un heredero (Art. 1526 N° 4 inc. 1º CC): Las deudas del causante se reparten entre los herederos a prorrata de su interés en la herencia. Lo dispuesto por el causante, o acordado por los herederos, o determinado en la partición, en el sentido de hacer una división diferente, no obliga a los acreedores, los que pueden, a su elección, dirigirse por el total en contra del heredero al que se le impuso la deuda, o bien en contra de cada heredero por su cuota.
- ii. Indivisibilidad estipulada con el causante (Art. 1526 N° 4 inc. 2º CC): en este caso, cada heredero puede ser obligado a entenderse con sus coherederos para pagar el total de la deuda, o a pagarla él mismo.
- iii. No cabe la indivisibilidad de pago activa (Art. 1526 N° 4 inc. 3º CC): si los herederos del acreedor no entablan conjuntamente su acción, sólo pueden exigir el pago de su cuota.

Problema: los créditos (y sus cuotas) no pertenecen a ningún heredero mientras no se haga la partición, por lo que esta disposición se contradice con el Art. 1344 CC. Existen 2 posiciones:

- a) No es posible que el heredero demande su cuota antes de la partición, fundándose en el efecto declarativo de la partición.
- b) Los herederos pueden demandar su cuota desde la delación de la herencia, pues la división de los créditos se produce de pleno derecho, sin esperar partición. Ambas disposiciones tienen campos de aplicación distintos:
 - el Art. 1526 CC rige las relaciones entre el heredero y el deudor;
 - el Art. 1344 CC rige las relaciones entre los coherederos. Si el heredero cobra su cuota y posteriormente no se adjudica el crédito, debe reembolsar lo percibido al adjudicatario.

5. Art. 1526 N° 5. Pago de una cosa indeterminada.

Se refiere a una cosa indeterminada cuya división ocasiona grave perjuicio al acreedor. En este caso, cada uno de los deudores puede ser obligado a entenderse con los demás para el pago de la cosa entera, o a pagarla él mismo.

Se reitera el principio de que no hay indivisibilidad de pago activa.

6. Art. 1526 N° 6. Obligaciones alternativas.

Si la elección es de los acreedores, deben hacerla de consuno, lo que es aplicable también si la elección es de los deudores.

Se produce una cuestión interesante respecto del Art. 1489 CC: algunos dicen que en

ese caso hay obligación alternativa, por lo tanto si los acreedores son varios, deben ponerse de acuerdo para pedir el cumplimiento o la resolución.

PARALELO ENTRE SOLIDARIDAD O INDIVISIBILIDAD.

Semejanzas:

1. Son excepciones al principio de la división de las deudas frente a la pluralidad de sujetos.
2. Cada acreedor puede pedir el total, y cada deudor está obligado por el total.
3. El pago hecho por un deudor extingue la obligación respecto de todos.

Diferencias:

	Solidaridad	Indivisibilidad
Transmisibilidad	No se transmite	Se transmite
¿De dónde emana?	No emana de la naturaleza del objeto debido. Es requisito de la solidaridad que la cosa sea divisible.	La indivisibilidad emana de la naturaleza del objeto debido.
Renunciabilidad	Es renunciable	No es renunciable
Exigencia al deudor	El acreedor puede exigirle el pago total a cualquier deudor.	El deudor puede pedir un plazo para entenderse con sus codeudores.

El ser solidaria una obligación no le da el carácter de indivisible.

Así lo dice el Art. 1525 CC.

3.10. OBLIGACIONES PRINCIPALES Y ACCESORIAS.

1. Concepto.

Obligaciones principales: pueden subsistir por sí solas, sin necesidad de otras.

Obligaciones accesorias: las que tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no parecen subsistir sin ella.

2. Importancia de la distinción.

Lo accesorio sigue la suerte de lo principal:

- Si se extingue la obligación principal, se extingue la accesorio por vía consecuencial.
- La obligación accesorio prescribe junto con la obligación principal.

3.11. OBLIGACIONES PURAS Y SIMPLES O SUJETAS A MODALIDAD.

1. Introducción. Concepto de modalidad.

Modalidad: elementos que alteran los efectos normales de los actos jurídicos.⁸

La regla es que las obligaciones sean puras y simples; que produzcan sus efectos normalmente desde su nacimiento hasta su extinción.

Sin embargo, en virtud del (1) testamento, (2) de la voluntad de las partes o (3) de la ley, se puede agregar a la obligación una modalidad, con el objeto de alterar sus efectos normales, sea en cuanto:

- a su nacimiento,
- a su ejercicio o
- a su extinción.

2. Efectos normales de una obligación y ejemplos de modalidades que los alteran:

1) El derecho y la obligación nacen coetáneamente con el acto mismo que los crea.

Excepción: Condición suspensiva.

2) Generada la obligación, el acreedor puede ejercer sus derechos de inmediato.

Excepción: Plazo suspensivo.

3) La obligación subsiste en el tiempo hasta su extinción normal.

Excepción: Condición resolutoria.

4) El deudor debe cumplir su obligación, sin que se impongan cargas al acreedor.

Excepción: Modo.

3. La condición, el plazo y el modo son las principales modalidades, pero no las únicas.

También son modalidades:

- la solidaridad,
- las obligaciones alternativas o facultativas,
- y la representación.

4. Caracteres de las modalidades.

1) Por regla general son elementos accidentales de los actos jurídicos (Art. 1444 CC). Pero excepcionalmente:

- Son elementos de la naturaleza (Ej. Condición resolutoria tácita)
- O incluso pueden ser de la esencia (Ej. Condición o plazo en el contrato de promesa).

2) Son excepcionales; la regla general es que los actos sean puros y simples. Por

⁸ Si bien por regla general los asociamos a los elementos accidentales de los actos jurídicos, existen casos en que son elementos de la naturaleza, como ocurre con la condición resolutoria tácita en los contratos bilaterales, y otros casos en que incluso son elementos de la esencia de los actos jurídicos como ocurre en el contrato de promesa, art. 1554 n°3 CC

eso, quien las alegue debe probarlas, son de interpretación restringida y no se presumen. Excepcionalmente se presume la condición resolutoria tácita.

3) Requieren de una fuente que las cree, que puede ser el testamento, la convención o la ley. La sentencia judicial no es fuente, salvo que la ley lo autorice. Ej. Art. 904 CC.

4) Por regla general, cualquier acto jurídico puede ser objeto de modalidades. Excepcionalmente la ley no lo permite respecto de ciertos actos. La regla general es contraria en el derecho de familia: no se aceptan las modalidades, no opera el principio de autonomía de la voluntad, pues sus normas son de orden público.

3.11.1 DE LAS OBLIGACIONES CONDICIONALES

1. Concepto.

Art. 1473 CC. "Es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro que puede suceder o no."

Concepto doctrinario: hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho y su correlativa obligación.

2. Lugar en que están reguladas las condiciones en el Código Civil.

- 1) A propósito de las disposiciones testamentarias condicionales (Arts. 1070 y ss. CC).
- 2) En las obligaciones condicionales (Arts. 1473 y ss. CC).
- 3) A propósito del fideicomiso (Arts. 733 y ss. CC).

En el primer tema, el CC se remite al segundo (Art. 1070 CC), y en el segundo, se remite al primero (Art. 1493 CC). Por tanto, existe un concepto unitario de condición.

3. Elementos de la condición.

- 1) Hecho futuro: el hecho que la constituye debe ocurrir con posterioridad a la celebración del acto (Art. 1071 inc. 2º CC). Si se fija como condición:
 - Un hecho presente o pasado, no se suspende el cumplimiento de la obligación:
 - Si existe o ha existido el hecho, se mira como no escrita la condición;
 - Si no existe o no ha existido, no vale la obligación (Art. 1071 CC).Esto es independiente de si las partes sabían o ignoraban la existencia del hecho.
- 2) Hecho incierto: puede acontecer o no (Art. 1081 inc. 3º CC). La incertidumbre debe ser objetiva, no la determinan las partes.

3. Clasificación de las condiciones.

1) Condiciones expresas y tácitas.

Expresa: se establece en términos formales y explícitos.

Tácita: la ley la da por establecida. Ej. Condición resolutoria tácita (Art. 1489 CC).

2) Condiciones suspensivas y resolutorias.

Art. 1479 CC. "La condición se llama *suspensiva* si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho; y *resolutoria*, cuando por su cumplimiento se extingue un derecho."

En consecuencia, si es suspensiva, el derecho no nace; si es resolutoria, el derecho nace, pero está expuesto a extinguirse.

3) Condición positiva y negativa.

Art. 1474 CC. "La condición es positiva o negativa.
La *positiva* consiste en acontecer una cosa; la *negativa*, en que una cosa no acontezca."

Importancia de la distinción: determinar cuándo debe considerarse cumplida o fallida.

Art. 1482 CC. "Se reputa haber fallado la condición positiva o haberse cumplido la negativa, cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el acontecimiento contemplado en ella, o cuando ha expirado el tiempo dentro del cual el acontecimiento ha debido verificarse, y no se ha verificado."

También es importante para la imposibilidad de las condiciones:

Art. 1475 inc. 1º CC. "La condición positiva debe ser física y moralmente posible."
Art. 1476 CC. "Si la condición es negativa de una cosa físicamente imposible, la obligación es pura y simple; si consiste en que el acreedor se abstenga de un hecho inmorale o prohibido, vicia la disposición."

4) Condiciones posibles e imposibles, lícitas e ilícitas.

Físicamente imposible: la contraria a las leyes de la naturaleza física.

Moralmente imposible: el hecho que la constituye es prohibido por ley, o es opuesto a las buenas costumbres o al orden público (Art. 1475 inc. 2º CC).

Se mira como imposible la condición concebida en términos ininteligibles (Art. 1475 inc. final CC).

Efectos:

a) Condición positiva imposible o ilícita:

1. Suspensiva: la condición se tiene por fallida, y el derecho no llega a nacer (Art. 1480 inc. 1º CC).

2. Resolutoria: la condición se tiene por no escrita, y el derecho nace puro y simple (Art. 1080 inc. final CC).

b) Condición negativa de un hecho físicamente imposible: la obligación es pura y simple (Art. 1476 CC).

c) Condición negativa de un hecho ilícito: vicia la disposición, es decir, el acreedor condicional no puede exigir el pago (Art. 1476 CC).

5) Condiciones determinadas o indeterminadas.

Determinada: el hecho que la constituye debe ocurrir en una época prefijada.

Indeterminada: no se fija una época para la ocurrencia del hecho.

Límite en el tiempo de la condición indeterminada.

La pregunta es cuánto tiempo hay que esperar para que la condición indeterminada se cumpla. Las opciones son 2:

a. Aplicar el Art. 739 CC relativo al fideicomiso: serían 5 años.

b. Aplicar la norma de la prescripción extraordinaria (Art. 2511 CC): serían 10 años.

No cabe duda de que la segunda es la correcta, pues 10 años es el tiempo máximo establecido por el CC para dar estabilidad a todas las situaciones jurídicas. La regla del Art. 739 CC es excepcional.

6) Condiciones potestativas, casuales y mixtas.

Art. 1477 CC. "Se llama:

- condición *potestativa* la que depende de la voluntad del acreedor o del deudor;
- *casual* la que depende de la voluntad de un tercero o de un acaso;
- *mixta* la que en parte depende de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso."

La disposición omite dentro de las mixtas la que en parte depende de la voluntad del deudor y en parte de la voluntad de un tercero o del acaso.

Subclasificación de las condiciones potestativas.

i. Simplemente potestativas: consisten en un hecho voluntario del acreedor o del deudor.

Art. 1478 CC. "Son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga. Si la condición consiste en un hecho voluntario de cualquiera de las partes, valdrá."

ii. Meramente potestativas: consisten en el mero arbitrio de las partes.

1. Lo que se anula es la obligación, no la condición.

2. Las únicas condiciones que anulan la obligación son las meramente

potestativas de la voluntad del deudor, porque en ellas no hay voluntad seria de obligarse.

3. Las únicas que producirían la nulidad de la obligación serían las meramente potestativas de la voluntad del deudor suspensivas. Las resolutorias serían válidas.

a) En las resolutorias, la obligación se ha formado y producido todos sus efectos.

b) El CC las acepta, como ocurre en las donaciones revocables (Art. 1136 CC) y en el pacto de retroventa (Art. 1881 CC).

Pero hay autores que sostienen que no vale ninguna:

a) El Art. 1478 CC no distingue.

b) Además, está ubicado antes del Art. 1479 CC que distingue entre condiciones suspensivas y resolutorias.

c) El fundamento de la nulidad es el mismo en ambas condiciones.

d) En los casos citados, las condiciones dependen de la sola voluntad del acreedor.

4. Reglas comunes a las condiciones.

1) Estados en que puede encontrarse la condición.

i. Pendiente: el hecho que la constituye aún no ocurre, pero puede ocurrir.

ii. Fallida:

1. Si es positiva: cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el hecho, o ha expirado el plazo sin que suceda.

2. Si es negativa: cuando sucede el hecho.

iii. Cumplida:

a) Si es positiva: cuando sucede el hecho.

b) Si es negativa:

i) Determinada: cuando expira el plazo dentro del cual no debía realizarse, sin que suceda.

ii) Indeterminada: cuando transcurran los 10 años sin que suceda.

2) Forma como deben cumplirse las condiciones.

Se aplica primero la regla del Art. 1483 CC:

Art. 1483 inc. 1º CC. "La condición debe ser cumplida del modo que las partes han probablemente entendido que lo fuese, y se presumirá que el modo más racional de cumplirla es el que han entendido las partes."

Esto concuerda con el Art. 1560 CC sobre la interpretación de los

contratos. Luego, entra a operar la regla del Art. 1484 CC:

Art. 1484 CC. "Las condiciones deben cumplirse literalmente, en la forma convenida."

Es decir, determinada la forma como las partes querían que se cumplieran, tienen que cumplirse de esa manera y no de otra. No pueden cumplirse por equivalencia.

❖ **Cumplimiento ficto de la condición.**

Art. 1481 inc. 2º CC. "Con todo, si la persona que debe prestar la asignación se vale de medios ilícitos para que la condición no pueda cumplirse, o para que la otra persona de cuya voluntad depende en parte su cumplimiento, no coopere a él, se tendrá por cumplida."

Esto es aplicación del principio de que nadie se puede favorecer con su propio dolo.

1. Algunos opinan que no cabe el cumplimiento ficto si la obligación es simplemente potestativa de la voluntad del deudor, pues en tal caso es "dueño" de la condición y puede impedir su cumplimiento.
2. Otros opinan que la norma debe aplicarse aun en ese caso, si el deudor impidió el cumplimiento de la condición para sustraerse del cumplimiento de la obligación, porque al ser ilícito el fin, el medio también lo es.

❖ **Problemas en relación con el cumplimiento ficto de la condición:**

- 1) Los términos en que está consagrado son propios de las asignaciones condicionales, pese a estar ubicado en la parte de las obligaciones condicionales.

Algunos dudan que se aplique a las obligaciones condicionales:

- a) Por el texto del Art. 1481 CC.
- b) Es una sanción, y además es una excepción pues la regla general es que las condiciones deben cumplirse de manera efectiva. Por eso debe interpretarse restrictivamente.

La generalidad de la doctrina sostiene que es de aplicación general:

- a) Por la historia de la disposición: permite suponer que se incluyó sólo en la parte de las obligaciones para evitar repeticiones inútiles.
- b) La norma se justifica plenamente tanto para las asignaciones como para las obligaciones condicionales.

- 2) Fundamento de la institución: dos opciones:

- a) Sancionar la mala fe del deudor.
- b) Es una forma especial de indemnizar a la víctima de un hecho ilícito.

Esto es importante frente al caso en que la condición de todas formas habría fallado. Si optamos por la primera opción, hay que tenerla por cumplida de todos modos; si optamos por la segunda, la conclusión es la contraria.

- 3) Qué se entiende por "medios ilícitos".

a) Se refiere a una ilicitud general.

b) Se refiere a cualquier hecho que en abstracto puede no ser reprobable, pero se estima ilícito por la finalidad con que se realiza. Esta es la adecuada, pues de lo contrario se estaría permitiendo el fraude.

4) Para que se aplique el Art. 1481 CC, ¿tiene que existir dolo, o basta la culpa?
Lo que la ley pretende es evitar el fraude, por lo tanto es necesario el dolo.

5) En el supuesto de que la condición establecida por las partes constituya al mismo tiempo un requisito establecido por la ley para que se pueda cumplir la obligación o ejecutar el negocio, ¿cabe también el cumplimiento ficto? Ej. Contrato de promesa.

a) No, porque una parte no puede llevar a la otra a una contravención de la ley.

b) Hay que distinguir dos etapas: la contratación, que da nacimiento a la obligación, y el cumplimiento efectivo de ésta. Si se cumplen las exigencias para la aplicación de la regla, ella debe aplicarse, provocándose el cumplimiento ficto de la condición y naciendo la obligación. Otra cosa es que después, por imposibilidad legal o administrativa, no pueda exigirse el cumplimiento de la obligación en especie.

6) ¿Cabe el cumplimiento ficto cuando el deudor condicional ha adoptado una actitud pasiva?

a) No, porque el Art. 1481 CC al hablar de medios ilícitos, parece exigir un actuar.

b) Si la inactividad tiene por objeto justamente que la condición no se cumpla, debe aplicarse la institución.

7) ¿Qué ocurre cuando el acreedor despliega medios para que la condición se cumpla, con el objeto de que nazca el derecho y demandarlo? Aplicar la regla implica tenerla por fallida.

Hay quien opina que aplica la regla, no por el Art. 1481 CC, sino porque se trata de un vacío legal, que se integra con la misma solución aplicable al deudor.

❖ Principio de la indivisibilidad de la condición.

Art. 1485 inc. 1º CC. "No puede exigirse el cumplimiento de la obligación condicional, sino verificada la condición totalmente."

3) Caducidad de las condiciones.

Ya hemos dicho cuándo las condiciones se entienden fallidas.

El efecto de la caducidad es el siguiente:

a) Si es suspensiva y falla: el acreedor condicional no va a llegar a adquirir el derecho.

b) Si es resolutoria y falla: se consolida el derecho en poder del deudor condicional.

4) Retroactividad de la condición cumplida.

Una vez cumplida, los efectos del acto o contrato se retrotraen al momento en que dicho acto se celebró:

a) Si es suspensiva: se considera que el acto ha tenido siempre el carácter de puro y simple, y se reputa que el acreedor adquirió el derecho desde el momento de la celebración del acto, entendiéndose que el deudor quedó obligado desde la misma fecha.

b) Si es resolutoria: las partes quedan como si jamás hubieran estado vinculadas entre sí, el deudor condicional debe restituir lo que recibió al momento de celebrarse el acto.

La retroactividad es una ficción destinada a proteger al acreedor condicional de los actos o gravámenes que pudiera haber realizado el deudor condicional mientras la condición estaba pendiente.

❖ **La retroactividad de la condición en Chile.**

En Chile no hay una norma que la establezca. Esto genera un problema porque hay casos en que se acepta y casos en que se rechaza.

- **Casos en que se acepta el efecto retroactivo (arts. 1486, 2413, 1487, 1490 y 1491).**

1. Art. 1486 inc. 2º CC: el acreedor tiene derecho a los aumentos y mejoras de la cosa ocurridos cuando estaba pendiente la condición.

2. Art. 2413 inc. 2º CC: vale la hipoteca desde la fecha de su inscripción una vez cumplida la condición suspensiva bajo la cual se otorgó.

3. Art. 1487 CC: cuando se cumple la condición resolutoria, el deudor debe restituir todo lo recibido.

4. Arts. 1490 y 1491 CC: privan de valor a las enajenaciones hechas por el deudor en el tiempo intermedio, a menos que se cumplan ciertos requisitos.

- **Casos en que se rechaza el efecto retroactivo.**

1. Art. 1488 CC: cumplida la condición resolutoria, no se deben restituir los frutos producidos por la cosa mientras estuvo pendiente la condición.

2. Art. 1078 inc. 3º CC: misma idea en asignaciones testamentarias.

3. Art. 758 CC: el fiduciario puede mudar la forma del fideicomiso. Además, se acepta que cumplida la condición y operada la restitución, subsisten los arrendamientos hechos por el fiduciario.

4. Arts. 1490 y 1491 CC: las enajenaciones hechas por el deudor estando pendiente la condición generalmente valen.

❖ **En los casos no reglamentados en la ley ¿opera el efecto retroactivo?**

- a. Algunos piensan que el CC acoge en general la retroactividad.
- b. Otros señalan que la retroactividad es la excepción, pues como ficción que es, no puede extenderse a otros casos que los previstos expresamente.

5) Riesgos de la cosa debida bajo condición.

Art. 1486 inc. 1º primera parte CC. "Si antes del cumplimiento de la condición la cosa prometida perece sin culpa del deudor, se extingue la obligación;..."

Es falso que se extinga, porque no ha existido nunca. Lo que ocurre es que deja sin objeto una obligación que posteriormente puede nacer, dejando sin causa a la obligación correlativa. En consecuencia, lo que se extingue es el contrato.

El riesgo, entonces, es del deudor condicional, pues no va a poder exigir el cumplimiento de la obligación correlativa.

En esta materia no se sigue la regla general del Art. 1550 CC, según la cual el riesgo es del acreedor. Es justo que así sea, porque las cosas se pierden para su dueño, que es el deudor mientras pende la condición.

Art. 1486 inc. 1º segunda parte CC. "...y por culpa del deudor, el deudor es obligado al precio, y a la indemnización de perjuicios."

Lo hasta aquí señalado rige la destrucción total.

Si la destrucción es parcial y fortuita, el acreedor debe recibir la cosa en el estado en que se encuentra, sin derecho a la rebaja del precio (Art. 1486 inc. 2º primera parte CC).

Si es parcial y culpable, el acreedor tiene un derecho alternativo: que se rescinda (resuelva) el contrato o se le entregue la cosa en el estado en que está, en ambos casos con indemnización (Art. 1486 inc. 2º segunda parte CC).

Art. 1486 inc. final CC. "Todo lo que destruye la aptitud de la cosa para el objeto a que según su naturaleza o según la convención se destina, se entiende destruir la cosa."

5. Efectos de las condiciones.

Hay que distinguir entre condiciones: Suspensivas

- Pendiente
- Fallida

- Cumplida
-
- Resolutorias (Ordinaria, tácita, pacto comisorio)
- Pendiente
- Fallida
- Cumplida

3.11.1.1 EFECTOS DE LA CONDICIÓN SUSPENSIVA

I. CONDICIÓN SUSPENSIVA PENDIENTE.

1. No nace el derecho ni la obligación.

Consecuencias:

- 1) El acreedor no puede exigir su cumplimiento (Art. 1485 inc. 1º CC).
- 2) Si el deudor paga antes del cumplimiento, paga lo no debido y puede pedir restitución (Art. 1485 inc. 2º CC).
- 3) El acreedor no puede ejercer la acción pauliana (Art. 2468 CC), pues todavía no es realmente acreedor.
- 4) No hay obligación actualmente exigible. Por ello la prescripción no está corriendo (Art. 2514 inc. 2º CC), no se puede novar (Art. 1633 CC), no puede operar compensación (Art. 1656 N° 3 CC) y el deudor no está en mora.

2. El vínculo jurídico existe.

El acto o contrato se generó, si bien el derecho y la obligación no han nacido.

Consecuencias:

- 1) Al contratarse la obligación, deben reunirse todos los requisitos de existencia y validez del acto.
- 2) El deudor no puede retractarse; el contrato es ley para los contratantes (Art. 1545 CC).
- 3) La obligación condicional se rige por la ley vigente al momento de otorgarse el contrato (Art. 22 LERL).

3. El acreedor tiene una simple expectativa de derecho.

Algunos dicen que tiene un germen de derecho.

Consecuencias:

- 1) El acreedor condicional puede impetrar providencias conservativas (Arts. 1492 inc. 3º, 1078 inc. 1º y 761 inc. 2º CC).
- 2) Este germen se transmite a los herederos (Art. 1492 inc. 1º CC), lo que no ocurre en 2 casos:
 - a) En las asignaciones testamentarias condicionales (Art. 1078 inc. 2º CC).
 - b) Respecto del donatario condicional.

II. CONDICIÓN SUSPENSIVA FALLIDA.

El derecho y la obligación no van a nacer, desapareciendo la expectativa del

acreedor condicional.

- Quedan sin efecto las medidas conservativas,
- quedan firmes los actos de administración o disposición del deudor condicional.

III. CONDICIÓN SUSPENSIVA CUMPLIDA.

- 1) Nace el derecho y la obligación.
- 2) El acreedor puede exigir su cumplimiento.
- 3) Si el deudor paga, el pago es válido y no puede repetir (Art. 1485 inc. 2º CC).
- 4) Según algunos, se produce el efecto retroactivo.
- 5) El deudor debe entregar la cosa debida en el estado en que se halle, favoreciendo al acreedor los aumentos y soportando las pérdidas (Art. 1486), siempre que éstas sean fortuitas.
- 6) Por regla general no se entregan los frutos que la cosa produjo en el tiempo intermedio (Arts. 1078 inc. 3º y 1488 CC).
- 7) Los actos de administración celebrados por el deudor se mantienen, sin perjuicio de que el cumplimiento de la condición importe una causal de extinción del contrato (Arts. 1950 N° 3 y 758 CC).

3.11.1.2 EFECTOS DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA

Puede tener 3 modalidades: ordinaria, tácita y pacto comisorio.

- **Condición resolutoria ordinaria.** Es el hecho futuro e incierto, que no sea el incumplimiento de una obligación contraída, verificado el cual se extingue un derecho y su correlativa obligación.
- **Condición resolutoria tácita.** Es la que va envuelta en todo contrato bilateral para el caso de no cumplirse por la otra parte lo pactado (Art. 1489 CC).
- **El pacto comisorio.** Es la condición resolutoria tácita expresada.

3.11.1.2.1 CONDICIÓN RESOLUTORIA ORDINARIA

Es el hecho futuro e incierto, que no sea el incumplimiento de una obligación contraída, verificado el cual se extingue un derecho y su correlativa obligación de pleno derecho.

Se deben estudiar en los 3 estados en que puede encontrarse.

CONDICIÓN RESOLUTORIA ORDINARIA PENDIENTE.

- 1) El acto o contrato produce todos sus efectos, como si fuera puro y simple.
- 2) El que tiene el dominio bajo la condición, puede ejercer su derecho como si

fuera dueño puro y simple, realizando actos de administración, enajenación y gravamen, sujeto todo a resolverse.

3) Para el asignatario condicional se produce la inmediata delación de la herencia (Art. 956 CC), e incluso puede pedir la partición.

4) El deudor condicional debe cuidar y conservar la cosa como un buen padre de familia, para restituirla al acreedor si se cumple la condición (Arts. 1486 y 758 inc. 2º CC).

5) El acreedor condicional puede impetrar medidas conservativas (Arts. 1492 inc. final y 761 inc. 2º CC)

CONDICIÓN RESOLUTORIA ORDINARIA FALLIDA.

El derecho del deudor condicional se consolida, y quedan firmes los actos realizados mientras la condición estaba pendiente. Se extinguen las medidas conservativas.

CONDICIÓN RESOLUTORIA ORDINARIA CUMPLIDA.

1) Quien adquirió derechos sujetos a ella se extinguen.

Art. 1487 CC. "Cumplida la condición resolutoria, deberá restituirse lo que se hubiere recibido bajo tal condición,..."

Por regla general, no se aplican a estas restituciones las normas sobre prestaciones mutuas, porque hay reglas propias (Arts. 1486 y ss. CC).

2) Los actos de administración realizados por el deudor se extinguen.

3) Opera de pleno derecho, no requiere declaración judicial (lo que concuerda con el tenor de los Arts. 1487 y 1479 CC).

4) Si las partes van a juicio, el tribunal se limitará a constatar que la condición operó.

Importancia: produce efectos universales, pudiendo oponerse la resolución a cualquier persona, y cualquier tercero puede invocarla.

3.11.1.2.2 CONDICIÓN RESOLUTORIA TÁCITA

El incumplimiento de una obligación en un contrato bilateral da a la otra parte un derecho alternativo para solicitar o el cumplimiento o la resolución, y en ambos casos con indemnización de perjuicios.

❖ Fundamento de la condición resolutoria tácita.

Se dan diversas explicaciones:

1) Equidad.

2) Voluntad presunta de las partes.

- 3) Falta de causa (si una de las partes no cumple su obligación, la obligación de la otra no tiene causa). Se le critica que si faltara la causa, el contrato sería nulo, por lo que no se podría pedir el cumplimiento. La causa se ve al momento de celebrarse el contrato; el incumplimiento posterior no la hace desaparecer.
- 4) Interdependencia de las obligaciones nacidas de un contrato bilateral.
- 5) Es un modo de reparación del perjuicio que causa al acreedor el incumplimiento de la obligación del deudor.

❖ **Características de la condición resolutoria tácita.**

- 1) Es un tipo de condición resolutoria.
- 2) Es tácita: es un elemento de la naturaleza, y es renunciable.
- 3) Es negativa: consiste en que una de las partes no cumpla.
- 4) Es simplemente potestativa: depende de un hecho voluntario del deudor.
- 5) No opera de pleno derecho: requiere declaración judicial.

❖ **Requisitos de la condición resolutoria tácita.**

1) Que se trate de un contrato bilateral.

Claro Solar cree que opera incluso en los unilaterales:

- 1) El Art. 1489 CC no excluye la posibilidad de que se dé en los unilaterales.
- 2) Varias disposiciones demuestran que no se restringe a los bilaterales:
 - En el comodato, se da al comodante la facultad de pedir la restitución de la cosa si el comodatario no la destina al uso convenido (Art. 2177 CC).
 - En la renta vitalicia, la ley ha tenido que decir expresamente que el acreedor no puede pedir la resolución aun si no se le paga la pensión (Art. 2271 CC).
 - En la prenda, el deudor puede pedir restitución inmediata si el acreedor abusa de la cosa (Art. 2396 CC).

La mayoría de la doctrina estima que sólo cabe en los bilaterales:

- 1) El tenor literal del Art. 1489 CC así lo muestra.
 - 2) En los unilaterales, el CC ha resuelto cada caso particular de incumplimiento, pero nada ha dicho del mutuo.
 - 3) El fundamento de la condición resolutoria tácita es, según algunos, la interdependencia de las prestaciones, que sólo puede ocurrir en los bilaterales.
- La jurisprudencia se ha inclinado por esta tesis.

• **La resolución en los contratos de tracto sucesivo.**

Pasa a llamarse terminación, porque sus efectos no operan retroactivamente, sino sólo para el futuro, debido a que las prestaciones de una de las partes no se pueden devolver.

• **La resolución no tiene lugar en la partición.**

Esto es unánime en la doctrina nacional. Razones:

- 1) No es un contrato bilateral.
- 2) Se opone a ello el efecto declarativo de la partición.
- 3) El Art. 1489 CC es doblemente excepcional, porque da al acto el carácter de condicional, y presume la condición. Por eso, es de interpretación restringida sólo al caso regulado.
- 4) El Art. 1348 CC hace aplicables a la partición acciones de los contratos, como nulidad y rescisión, pero nada dice de la resolución.
- 5) La hipoteca legal del Art. 662 CPC está establecida justamente porque los comuneros no tienen acción resolutoria frente al comunero que no paga la diferencia.

2) Incumplimiento imputable a una de las partes.

La mayoría de la doctrina y la jurisprudencia tradicionales⁹ han estimado que el incumplimiento debe ser imputable a dolo o culpa del deudor. Esto se desprende del Art. 1489 CC, pues uno de los requisitos para que opere la indemnización de perjuicios es que el deudor esté en mora (Art. 1557 CC), y uno de los requisitos de la mora es el dolo o culpa. Esto concuerda con el cumplimiento de buena fe de los contratos.

La jurisprudencia actual, siguiendo las tendencias doctrinarias más modernas, ha cambiado su posición en este aspecto, y ya no se estima que la imputabilidad del incumplimiento sea un requisito de la resolución por incumplimiento. La mora del deudor no se exige como un requisito de la resolución, sino de la indemnización de perjuicios. De esta manera, si el acreedor insatisfecho demanda solo la resolución, y no la indemnización de perjuicios, no sería necesario que acreditase la imputabilidad del incumplimiento para que se le concediera la resolución.¹⁰

Esta evolución en la jurisprudencia resulta especialmente relevante en casos de incumplimiento recíproco.

• ¿Procede la resolución por incumplimientos de poca monta?¹¹

- a) Tradicionalmente se sostuvo que, al no distinguir la ley, cualquier incumplimiento es suficiente.
- b) Pero muchos sostienen que el incumplimiento de una obligación secundaria no es suficiente para pedir la resolución, fundándose en la equidad.

⁹ El profesor Enrique Barros ha sostenido una opinión diversa, al señalar que no es posible confundir la mora con el incumplimiento imputable. La primera es la situación jurídica de incumplimiento, que puede o no ser imputable al deudor, de modo que, aunque se acepte que la resolución requiere mora, de ello no se sigue que el incumplimiento deba ser imputable. Barros, Enrique: "*Finalidad y alcance de las acciones y remedios contractuales*", en Guzmán Brito, Alejandro (editor científico), Estudios de Derecho Civil III (Santiago, Legal Publishing, 2008) p.422

¹⁰ Para quien desee profundizar, recomendamos revisar el fallo dictado por la Corte Suprema en el mes de mayo de 2019, conociendo de un recurso de casación en el fondo, en la causa Rol N° C-2992-2014.

¹¹ Ver anexo III al final

- **¿Procede la resolución si el incumplimiento es parcial?**

No hay duda que sí, y el Art. 1875 inc. 2º CC lo permite expresamente.

3) Quien demanda la resolución debe hacer cumplido su propia obligación o allanarse a cumplirla.

La posición de la jurisprudencia tradicional fue exigirle a quien demandaba la resolución que este, a su vez, hubiera cumplido o estuviera llano a cumplirla. La razón para pedir este requisito es que, frente a la acción resolutoria, el deudor hubiese interpuesto la excepción de contrato no cumplido, contenida en el art. 1552 CC.

Actualmente, la jurisprudencia se ha inclinado por no exigir que el deudor haya cumplido, como corolario de su decisión de estimar que la mora del deudor no es un requisito para la acción resolutoria, sino para la acción de indemnización de perjuicios. Así, en casos de incumplimiento recíproco, la posición actual de la jurisprudencia es conceder la resolución, pero sin la indemnización de perjuicios.

4) Que una sentencia judicial declare la resolución del contrato.

Esto la diferencia de la condición resolutoria ordinaria.

Si operara de pleno derecho, el acreedor no podría usar la opción que le da el Art. 1489 CC de pedir el cumplimiento. Aunque se critica que de todos modos el acreedor puede renunciar a la resolución.

En todo caso, el acreedor tiene que ejercer su opción, para lo cual debe entablar la acción correspondiente, que será resuelta en una sentencia judicial.

- **Consecuencia de que la resolución requiera de sentencia judicial.**

El deudor puede enervar la acción de resolución, pagando hasta antes de la citación a oír sentencia en primera instancia, o hasta la vista de la causa en segunda.

- **¿Es cierto que demandada la resolución el deudor puede enervar la acción, pagando?**

1. Así se ha sostenido casi invariablemente por la doctrina, lo que se funda en el Art. 310 CPC, que permite oponer la excepción de pago en cualquier estado de la causa hasta la citación para oír sentencia o la vista de la causa (primera/segunda instancia).

2. Pero hay quienes no comparten esta opinión:

1) Se vulnera el Art. 1489 CC, que otorga la opción exclusivamente al contratante cumplidor. Si se le da al deudor la opción de pagar durante el juicio, se le estaría dando a él la elección.

2) Una cosa es poder oponer la excepción de pago, y otra muy distinta es poder pagar.

3) Todo contrato es ley para los contratantes, por lo que las partes

debe cumplir sus obligaciones en la forma y oportunidad convenidas.

Lo único que atenta contra esta tesis es el Art. 1879 CC, relativo al pacto comisorio calificado, que permite al comprador enervar la acción de resolución pagando dentro de 24 horas desde la notificación de la demanda. Si en este caso el legislador lo permite, por lógica debería permitirse en el caso de la simple condición resolutoria tácita. Pero esta disposición es especial, y no permite sacar conclusiones generales.

❖ **Derechos que confiere la condición resolutoria tácita.**

Confiere al contratante diligente una opción para demandar el cumplimiento del contrato o su resolución, en ambos casos con indemnización de perjuicios.

- Si demanda el cumplimiento, puede hacerlo por la vía ordinaria o por la vía ejecutiva, según la naturaleza del título.
- Si demanda la resolución, la vía tiene que ser necesariamente la ordinaria, ya que del sólo título no consta el incumplimiento del contrato.

❖ **Las acciones de cumplimiento y de resolución son incompatibles, pero pueden interponerse sucesivamente.**

No pueden demandarse conjuntamente, a menos que lo sea en forma subsidiaria (art. 17 CPC). Pero nada obsta a que ejercida una se pueda ejercer posteriormente la otra si no se obtuvo: si el contratante diligente demanda el cumplimiento y no lo obtiene, mantiene su opción para demandar la resolución.

❖ **Diferencias entre la condición resolutoria ordinaria y la condición resolutoria tácita.**

	Ordinaria	Tácita
1. Forma como opera	De pleno derecho	Requiere resolución judicial
2. Acción resolutoria	Como opera de pleno derecho, no requiere el ejercicio de la acción resolutoria.	Requiere el ejercicio de la acción resolutoria.
3. Naturaleza del hecho futuro e incierto	Puede ser cualquiera, menos el incumplimiento de una obligación en un contrato bilateral	Sólo puede ser el incumplimiento de una obligación emanada de un contrato bilateral
4. Actos jurídicos sobre los cuales es aplicable	Cualquier acto jurídico	Sólo en los contratos bilaterales
5. Forma de expresarse	Requiere de manifestación expresa de voluntad	Es tácita, la ley la subentiende en los contratos bilaterales
6. Derecho de opción	El incumplimiento solo produce resolución	El incumplimiento da al contratante diligente el derecho de optar entre la resolución o el cumplimiento

7. Indemnización de perjuicios	El acreedor no tiene derecho a la indemnización de perjuicios	El acreedor sí tiene derecho a la indemnización de perjuicios
8. Posibilidad de enervar la acción	El deudor no puede interopner la excepción de pago, ya que opera de pleno derecho	El deudor puede enervar la acción pagando durante el transcurso del juicio
9. Legitimación activa	Puede hacerla efectiva todo a quien le interese la resolución ya que al operar por el sólo ministerio de la ley, aprovecha a cualquier interesado	Solo puede demandarla el acreedor, ya que sus efectos son relativos, en conformidad con el art. 3 del CC.

3.11.1.2.3 PACTO COMISORIO

El CC lo regula en el contrato de compraventa, para el incumplimiento de la obligación de pagar el precio.

Art. 1877 inc. 1º CC. "Por el *pacto comisorio* se estipula expresamente que, no pagándose el precio al tiempo convenido, se resolverá el contrato de venta."

En consecuencia, el pacto comisorio es la estipulación de la condición resolutoria tácita, por el no pago del precio. Pero si nada dicen las partes y el comprador no paga el precio, el efecto es el mismo.

El pacto comisorio procede en cualquier contrato y por el incumplimiento de cualquiera obligación.

Surge la duda por la ubicación de la disposición, pero hoy está claro que su alcance es general, pudiendo establecerse en cualquier contrato (incluso unilaterales) y por el incumplimiento de cualquier obligación. Razones:

- 1) El pacto comisorio no es otra cosa que la condición resolutoria tácita expresada.
- 2) Por el principio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden acordarlo.
- 3) El pacto comisorio se ha ubicado dentro de los pactos accesorios a la compraventa sólo por una razón histórica.

El problema es determinar qué normas se aplican al pacto comisorio establecido en los demás contratos.

Pacto comisorio simple y pacto comisorio calificado.

Esta clasificación se desprende del Art. 1879 CC.

Simple: condición resolutoria tácita expresada.

Calificado o con cláusula de ipso facto: acuerdo de las partes en orden a dejar sin efecto el contrato, de inmediato, ipso facto, si el deudor incumple sus obligaciones.

Efectos del pacto comisorio.

Hay que distinguir entre pacto comisorio:

1. Efecto del pacto comisorio simple en el contrato de compraventa por no pago del precio.

Art. 1878 CC. "Por el pacto comisorio no se priva al vendedor de la elección de acciones que le concede el artículo 1873."

La elección es entre exigir el precio o la resolución de la venta, más indemnización. Son efectos idénticos a los de la condición resolutoria tácita. Para que opere, requiere declaración judicial.

2. Efecto del pacto comisorio simple en el contrato de compraventa por el incumplimiento de una obligación distinta a la de pagar el precio o en los demás contratos por incumplimiento de cualquiera obligación.

Sus efectos son los mismos que la condición resolutoria tácita: otorga al contratante cumplidor la opción para pedir el cumplimiento o la resolución, más indemnización. Se requiere sentencia judicial.

3. Efectos del pacto comisorio calificado en el contrato de compraventa por no pago del precio.

Art. 1879 CC. "Si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido, se resuelva ipso facto el contrato de venta, el comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir, pagando el precio, lo más tarde, en las veinticuatro horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda."

Queda claro que la resolución no opera de pleno derecho, sino que requiere declaración judicial. Esto se debe a que hay interés social en las transferencias de dominio que sigue a los títulos traslativos. La resolución no sólo afecta a las partes, sino que puede alcanzar a terceros poseedores.

Si el vendedor no quiere aceptar el pago, se puede pagar por consignación.

El plazo para pagar es de horas: se empieza a contar desde el momento mismo de la notificación de la demanda. Es un plazo fatal.

La resolución requiere sentencia judicial. Razones:

- a) Argumento histórico.
- b) Art. 1878 CC, aplicable a ambos pactos: no priva al vendedor de la elección de acciones. Si se resolviera ipso facto, no se podría ejercer la elección.
- c) Art. 1879 CC, "hacerlo subsistir": significa que el contrato no se extinguió.
- d) Si se puede enervar la acción, es porque el contrato no se ha resuelto.
- e) Art. 1879 CC: exige demanda judicial, lo que implica juicio y sentencia.

¿En qué momento se produce la resolución?

- a) Algunos dicen que al momento en que se acoge la demanda.

b) Otros dicen que en el momento en que se extingue el plazo de 24 horas para enervar la acción.

Importancia de la discusión: si se sigue la primera tesis, el vendedor puede recibir el pago después de las 24 horas, pues no se ha resuelto el contrato, lo que no podría ocurrir en la segunda tesis.

Condiciones que debe reunir el pago para enervar la acción.

- 1) Debe pagarse dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la demanda.
- 2) Debe ser íntegro.
- 3) Debe cumplir con los requisitos generales del pago.

4. Efectos del pacto comisorio calificado en el contrato de compraventa por el incumplimiento de una obligación distinta a la de pagar el precio, o en los demás contratos por incumplimiento de cualquiera obligación¹².

La cuestión es determinar si la resolución opera de pleno derecho o si requiere sentencia judicial.

Parece claro que opera de pleno derecho, porque eso es lo que las partes pretendieron al estipularlo. No se trata del pacto comisorio del Art. 1879 CC, por lo que no hay razón para aplicar sus reglas. Esa disposición es excepcional y su aplicación debe ser restrictiva. Como no hay reglas especiales, hay que recurrir a las reglas de interpretación de los contratos, en que resulta relevante el Art. 1560 CC, según el cual hay que atender a la intención de las partes.

Prescripción del pacto comisorio.

Art. 1880 CC. "El pacto comisorio prescribe al plazo prefijado por las partes, si no pasare de cuatro años, contados desde la fecha del contrato. Transcurridos estos cuatro años, prescribe necesariamente, sea que se haya estipulado un plazo más largo o ninguno."

1) El plazo rige únicamente para el pacto comisorio reglamentado en el CC. Para los demás, el plazo es de 5 años, de acuerdo a las reglas generales (Art. 2514 inc. 2º y 2515 CC).

2) Puede prescribir en un plazo menor a 4 años.

3) El plazo no empieza a correr desde que la obligación se hace exigible (como es la regla general), sino desde la fecha del contrato.

Prescrita la acción del pacto comisorio, ¿podría demandarse la resolución fundada en el artículo 1489?

1. La acción resolutoria se extingue irremediabilmente. El Art. 1880 CC se refiere a la

¹² Ver anexo IV al final

acción comisoraria del Art. 1878 CC, que a su vez se remite a la resolutoria del Art. 1873 CC. Si se estipuló pacto comisorio es porque las partes quisieron someterse a estas reglas, y no a las de la condición resolutoria tácita; su renuncia a la acción de esta condición se presume.

2. Pero la CS admitió la tesis contraria.

3.11.1.3 LA ACCIÓN RESOLUTORIA Y LA RESOLUCIÓN

Es relevante distinguir la resolución de la acción resolutoria.

RESOLUCIÓN: evento de cumplirse una condición resolutoria. (Art. 1567 n° 9 CC)

ACCIÓN RESOLUTORIA: es la que emana de la condición resolutoria en los casos en que ella requiere sentencia judicial, y en cuya virtud el contratante diligente solicita que se deje sin efecto el contrato por no haber cumplido la contraparte alguna de las obligaciones emanadas de él.

¿Cuándo requiere sentencia judicial?

1. En la condición resolutoria tácita.
2. En el pacto comisorio simple.
3. En el pacto comisorio calificado en el contrato de compraventa por no pago del precio.

Características de la acción resolutoria.

1) Personal. Es personal porque deriva del contrato. Sólo se puede entablar en contra de quien celebró el contrato, no en contra de terceros, sin perjuicio de que existan otras acciones contra ellos. Si se trata de deudores obligados solidariamente, se puede entablar contra cualquiera de ellos.

2) Patrimonial. Su objetivo es dejar sin efecto un contrato patrimonial. Consecuencias:

1. Es renunciable (Art. 1487 CC)
2. Es transferible y transmisible.
 - Algunos autores consideran que si se cede un crédito, esta cesión no importa la transferencia de la acción resolutoria, pues la resolución es una excepción personal.
 - También hay discusión en cuanto a si el tercero que pagó el precio por el deudor, con su consentimiento, al subrogarse en los derechos del acreedor, puede demandar la resolución.
3. Puede ejercer la acción resolutoria pues se subroga en los derechos y acciones del acreedor.
4. Sólo se subroga en el crédito, no adquiere la calidad de contratante, por lo que no tiene la acción resolutoria.
5. Es prescriptible: el plazo es normalmente de 5 años desde que la obligación se hace exigible (Arts. 2514 y 2515 CC). Pero en el caso de la acción comisoraria del Art. 1878 CC, rige la regla del Art. 1880 CC que ya vimos, que tiene la particularidad de que el plazo no se suspende.

3) Es mueble o inmueble, según la cosa sobre que recaiga. Es aplicación del Art. 580 CC.

4) Es indivisible.

- Subjetivamente: si son varios los acreedores, deben ejercitar la acción conjuntamente, y si hay pluralidad de deudores, debe demandarse a todos (Art. 1526 N° 6 CC).
- Objetivamente: no se puede demandar en parte el cumplimiento y en parte la resolución.

3.11.1.4 EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN

Hay que distinguir efectos entre las partes y efectos respecto de terceros.

1. Efectos de la resolución entre las partes.

1. Vuelven al estado anterior a la celebración del contrato, como si nunca hubieran contratado.
2. En virtud del efecto retroactivo, el deudor condicional debe restituir lo que había adquirido bajo condición (Art. 1487 CC).
3. El deudor, por regla general, no restituye los frutos percibidos en el tiempo intermedio (Art. 1488 CC).
4. El deudor debe entregar la cosa en el estado en que se encuentre, con sus aumentos y mejoras, y sufriendo el acreedor los deterioros fortuitos.
5. Los actos de administración realizados por el deudor quedan firmes, sin perjuicio de que la resolución produzca la extinción de algunos contratos.
6. Si el deudor había cumplido en parte sus obligaciones, debe restituírsele lo que había pagado (Art. 1875 CC).

2. Efectos de la resolución respecto de terceros.

La resolución va a afectar a los terceros cuando el deudor condicional, pendiente la condición resolutoria, haya enajenado o gravado la cosa poseída bajo esa condición.

Por el efecto retroactivo de la condición, se entiende que el deudor condicional nunca ha sido dueño, por lo que esos actos son inoponibles al verdadero dueño.

Pero para conciliar los intereses de los terceros con los del acreedor, se llega a una regla muy general: la resolución no afecta a los terceros de buena fe (Arts. 1490 y 1491 CC).

Estudio del artículo 1490.

Art. 1490 CC. "Si el que debe una cosa mueble a plazo, o bajo condición suspensiva o resolutoria, la enajena, no habrá derecho de reivindicarla contra terceros poseedores de buena fe."

Cosa mueble se refiere tanto a cosas corporales como incorporales. La

disposición incurre en impropiedades:

- I. Pendiente la condición no se puede decir que se deba la cosa, por lo tanto se refiere al que posee la cosa.
- II. La disposición se pone en 3 supuestos:
 - Que se tenga una cosa debida a plazo: nada tiene que ver con la resolución, porque quien debe la cosa a plazo no es propietario, por lo tanto si enajena la cosa, se aplican las reglas generales sobre enajenación de una cosa ajena, que es inoponible al verdadero dueño, sea que el tercero esté de buena o mala fe.
 - Se tenga una cosa debida bajo condición suspensiva: es imposible. Si tiene la cosa, y la tiene bajo condición, esa condición es resolutoria, no suspensiva.
 - Que se tenga una cosa debida bajo condición resolutoria: es el único caso en que opera la norma.

Requisitos para que la enajenación o gravamen de una cosa mueble debida bajo condición resolutoria afecte a terceros.

1. Que el deudor condicional la haya enajenado o gravado.
2. Que el tercero esté de mala fe: que al momento de contratar con el deudor condicional supiera que el derecho de éste estaba sujeto a condición resolutoria.

Estudio del artículo 1491.

Art. 1491 CC. "Si el que debe un inmueble bajo condición lo enajena, o lo grava con hipoteca, censo o servidumbre, no podrá resolverse la enajenación o gravamen, sino cuando la condición constaba en el título respectivo, inscrito u otorgado por escritura pública."

Cosa inmueble se refiere tanto a cosas corporales como incorporales. No comprende inmuebles por adherencia, pues son considerados muebles por anticipación para su enajenación.

- Requisitos para que los terceros se vean afectados por la condición.

Es un solo requisito: que la condición conste en el título respectivo, inscrito u otorgado por escritura pública.

- ¿Cuándo consta la condición en el título respectivo?

En el caso de la condición resolutoria ordinaria o del pacto comisorio, es indudable que constan en el título. La duda se genera en la tática, que justamente no puede constar:

- Se ha entendido que "constar" no significa que deba estar expresada. Por ello, consta también la condición si del título aparece que existe una obligación incumplida, pues en ese caso se sabe que se puede resolver. Por eso, cuando se examinan los títulos, debe estudiarse si existen obligaciones pendientes.
- Sin embargo, para algunos sólo consta la condición resolutoria expresa.
- ¿Cuál es el título respectivo?

Es aquel en cuya virtud adquirió la cosa la persona que ahora pretende enajenar o gravar.

- ¿Por qué la ley dice que la condición debe constar en el respectivo título inscrito u otorgado por escritura pública?

En primer lugar, se refiere al título porque es éste el que se inscribe, no la condición.

Hay ciertos títulos que no requieren inscripción (Ej. Servidumbres). Por ello la disposición habla también del título "otorgado por escritura pública". En el caso de los actos que deben inscribirse, tiene que encontrarse el título inscrito para que opere la disposición.

- Si la condición consta en el título inscrito u otorgado por escritura pública, ¿transforma al tercero adquirente en poseedor de mala fe?

Se concluye que aunque la condición conste en el título inscrito u otorgado por escritura pública, ese hecho no lo transforma en poseedor de mala fe, y no tendrá esa calidad si tiene la conciencia de haber adquirido la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio (Art. 706 inc. 1º CC).

Importancia: si es poseedor de buena fe y cumple los demás requisitos de la posesión regular, puede llegar a adquirir la cosa por prescripción ordinaria.

- Gravámenes que caducan.

El Art. 1491 CC genera la duda de qué pasa con los gravámenes que no señala.

- Algunos piensan que la disposición no es taxativa, sino ejemplificativa, por lo que rige para los demás gravámenes.
- Otros piensan que el precepto es taxativo, pues por ser excepcional, debe interpretarse en forma restringida. Además, de acuerdo a los Arts. 763, 806, 812, 885 y 2406 CC, los derechos de usufructo, uso y habitación, servidumbre y prenda se extinguen por la resolución del derecho de su autor, sin distinguir si los terceros están de buena o mala fe.
- No se aplica el artículo 1491 a los arrendamientos celebrados por el deudor condicional.

1) Porque no constituyen actos de enajenación o gravamen.

2) Porque el deudor condicional tiene facultades para dar en arrendamiento la cosa debida, aplicando por extensión la regla del Art. 758 CC relativa al propietario fiduciario.

3) Porque el CC ha reglamentado ese caso, estableciendo que termina el arrendamiento (Art. 1950 N° 3 CC), quedando obligado el arrendador a indemnizar al arrendatario (Art. 1958 CC).

- Acción reivindicatoria de los acreedores condicionales.

Si se cumplen los requisitos, el acreedor condicional tiene acción reivindicatoria contra terceros poseedores. La salvedad es que no procede contra terceros de buena fe en el caso de los muebles, ni respecto de los cuales la condición no constaba en el título inscrito u otorgado por escritura pública en el caso de los inmuebles.

El acreedor, puede intentar en la misma demanda la resolutoria contra el contratante incumplidor y la reivindicatoria en contra del tercero poseedor, pues emanan ambas del mismo hecho (Art. 18 CPC).

- Ámbito de aplicación de los artículos 1490 y 1491.

Fuera de los contratos innominados, sólo rigen en los siguientes casos:

1. A la resolución del contrato de compraventa, cuando el deudor no ha cumplido con la obligación de pagar el precio o cualquiera otra.
2. A la resolución del contrato de permuta (Art. 1900 CC).
3. Al pacto de retroventa (Art. 1882 CC).

Respecto de la donación entre vivos, hay una disposición especial que prevé la situación de los terceros en caso de resolución: Art. 1432 CC.

- Efectos de la cláusula de encontrarse pagado el precio.

Art. 1876 CC. "La resolución por no haberse pagado el precio no da derecho al vendedor contra terceros poseedores, sino en conformidad a los artículos 1490 y 1491.

Si en la escritura de venta se expresa haberse pagado el precio, no se admitirá prueba alguna en contrario sino la de nulidad o falsificación de la escritura, y sólo en virtud de esta prueba habrá acción contra terceros poseedores."

Problema: ¿el inc. 2º se aplica sólo en relación con los terceros, o afecta también al vendedor?

- La jurisprudencia ha entendido que se aplica a ambos.
- Parece ser que está dado exclusivamente en beneficio de los terceros adquirentes:
 - Debe interpretarse en armonía con el inc. 1º, referido a los terceros.
 - Si en la escritura se dice que se pagó el precio sin que ello sea cierto, existe simulación, no habiendo razón para impedir que el vendedor la pruebe.
 - De acuerdo al Art. 1700 CC, lo declarado por las partes en escritura pública

sólo es una presunción de verdad, que admite prueba en contrario.

- Los artículos 1490 y 1491 se aplican tanto a las enajenaciones voluntarias como a las forzadas.

La jurisprudencia así lo ha dicho, porque las disposiciones no distinguen.

3.11.1.5 RESOLUCIÓN/NULIDAD/RESCILIACIÓN

1. Origen
 - Hay nulidad cuando existe un vicio originario en el contrato;
 - La resolución deriva del hecho de que en un contrato bilateral, una parte no cumple lo pactado.
2. En cuanto a los efectos,
 - la nulidad borra totalmente el acto o contrato, por lo que da acción reivindicatoria contra terceros;
 - la resolución sólo da acción contra terceros de mala fe.
3. Hay diferencias en las prestaciones mutuas.
4. Sólo cabe resolución respecto de un contrato válido.

	NULIDAD	RESOLUCIÓN	RESCILIACIÓN
Concepto	Es la sanción a la ineficacia que el Ordenamiento Jurídico contempla contra el acto que no cumple requisitos de existencia ni validez. Es una acción personal, que tiene por finalidad acabar los efectos del contrato.	Es la sanción de ineficacia al acto jurídico existente y válidamente formado, ya sea por incumplimiento de una obligación u otro hecho futuro e incierto estipulado por las partes. Es una acción personal, que tiene por finalidad acabar con los efectos del contrato.	Es un modo de extinguir las obligaciones que se produce cuanto las partes, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, y en virtud del principio de autonomía de la voluntad, acuerdan dejar sin efecto el contrato de donde emana la obligación.
Restitución respecto de los frutos	El poseedor de mala fe debe restituir los frutos naturales y civiles percibidos y no sólo los que efectivamente percibió sino que todo aquel fruto que una persona de mediana inteligencia hubiese percibido. El poseedor de	Por regla general no se deben los frutos percibidos en el tiempo intermedio, a menos que la ley, el testador, el donante o los contratantes, hayan dispuesto lo contrario. (Art. 1488).	En principio, carece de efecto retroactivo, a menos que las mismas partes se lo confieran.

	buena fe sólo debe los que perciba después de contestación la demanda (Art. 907).		
Abono respecto de las mejoras y deterioros	<u>MEJORAS</u> A) NECESARIAS Se deben abonar los gastos ordinarios que se ha invertido en producir los frutos. Deben abonarse las expensas o mejoras necesarias (materiales e inmateriales) invertidas en la conservación de la cosa. B) ÚTILES Las mejoras útiles efectuadas antes de la contestación de la demanda también se abonan al poseedor de buena fe. C) VOLUPTUARIAS Los poseedores vencidos sólo tienen derecho a llevarse los materiales. (Art. 907 y 908). <u>DETERIOROS</u> El poseedor de buena fe debe abonarlos sólo cuando le hubieren sido provechosos. El de mala fe sólo si provienen de su hecho o culpa (Art. 906)	Cumplida la condición resolutoria, deberá restituirse lo que se hubiere recibido bajo tal condición (Art. 1487). • <u>Si antes de cumplirse la condición la cosa parece sin culpa del deudor</u> se extingue la obligación, pero si parece <u>por culpa del deudor</u> éste deberá el precio de la cosa más indemnización de perjuicios. • <u>Si la cosa existe al tiempo de cumplirse la condición</u>, se debe en el estado en que se encuentre, aprovechándose el acreedor de los aumentos o mejoras que haya recibido la cosa, sin estar obligado a dar más por ella, y sufriendo su deterioro o disminución, sin derecho a que se le rebaje el precio; salvo que el deterioro o disminución proceda de la culpa del deudor, en cuyo caso el acreedor podrá pedir o que se resuelva el contrato o que se le entregue la cosa, en que se encuentre, en ambos con indemnización de perjuicios (art. 1486)	En principio, no proceden abonos de ningún tipo, salvo lo que las partes puedan pactar libremente de acuerdo a la autonomía de la voluntad.
Acción contra terceros poseedores	Por regla general, la nulidad judicialmente declarada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores, sin que sea relevante	Por regla general, la resolución únicamente de acción reivindicatoria contra terceros poseedores de mala fe (arts. 1490 y 1491 CC).	No proceden acciones contra terceros poseedores, pues el acuerdo de las partes les es inoponible.

	distinguir si están de buena o mala fe, salvo las excepciones que el legislador establece		
Prescripción de la acción	La acción de nulidad absoluta prescribe en 10 años; la rescisoria en 4 años. El cómputo del plazo, por regla general, es desde la celebración del contrato. En caso de incapacidad y fuerza, desde que éstas cesan.	Por regla general la acción resolutoria prescribe en 5 años, y dicho plazo se computa desde que la obligación se hizo exigible. En el caso del pacto comisorio (art. 1880), el plazo es de cuatro años o menos si las partes pactan un plazo menor. Dicho plazo se computa desde la fecha del contrato.	

3.11.2. DE LAS OBLIGACIONES MODALES

1. Ubicación en el Código Civil.

El CC trata las asignaciones modales en los Arts. 1089 y ss. CC (Libro III). De acuerdo al Art. 1493 CC, estas normas se aplican a las convenciones en lo que no pugnen con los artículos anteriores.

Es lógico el CC al tratar esta modalidad en las asignaciones testamentarias, pues es allí donde normalmente suele tener aplicación.

2. Definición del modo.

El Art. 1089 CC no lo define, sino sólo lo diferencia de la condición:

Art. 1089 CC. "Si se asigna algo a una persona para que lo tenga por suyo con la obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas, esta aplicación es un *modo* y no una condición suspensiva. El modo, por consiguiente, no suspende la adquisición de la cosa asignada."

El modo es la carga que se impone a quien se otorga una liberalidad. O, de acuerdo al Art. 1089 CC, es el fin especial al que debe aplicarse el objeto asignado.

3. Modo y condición.

El modo no suspende la adquisición del derecho, lo que concuerda con el Art. 1091 CC, que libera al asignatario de prestar caución de restitución para el caso de que no se cumpla el modo. Pero no siempre es fácil distinguirlos.

4. Forma de cumplir el modo.

Debe cumplirse en la forma que las partes acordaron, y si no lo determinaron, el juez puede hacerlo atendiendo en lo posible a la voluntad de las partes.

5. El modo se puede cumplir por equivalencia.

Si el modo no se puede cumplir en la forma especial prescrita por el testador, imposibilidad que no deriva de hecho o culpa del asignatario, puede cumplirse en otra forma análoga que no altere la substancia de la disposición, y que apruebe el juez (Art. 1093 inc. 2º CC). Esto es una diferencia importante con la condición, que tiene que cumplirse literalmente en la forma convenida (Art. 1484 CC).

6. Incumplimiento o ilicitud del modo.

1. Si el modo es por su naturaleza imposible, o inductivo a un hecho ilegal o inmoral, o está concebido en términos inteligibles, no vale la disposición (Art. 1093 CC). Debe entenderse que la obligación modal es nula.

2. Si la imposibilidad es relativa, se puede cumplir por equivalencia (Art. 1093 inc. 2º CC).

3. Si la imposibilidad es sobreviniente:

A) Si no hay cláusula resolutoria:

a) Si no hay hecho o culpa del deudor: no se cumple el modo.

b) Si hay hecho o culpa del deudor:

1. Si el modo está establecido en beneficio exclusivo del deudor: no se genera para el deudor obligación alguna (Art. 1092 CC).

2. Si el modo está establecido en favor de un tercero, éste puede pedir cumplimiento forzado e indemnización de perjuicios.

B) Si hay cláusula resolutoria:

7. Cláusula resolutoria.

Art. 1090 CC. "En las asignaciones modales se llama *cláusula resolutoria* la que impone la obligación de restituir la cosa y los frutos, si no se cumple el modo. No se entenderá que envuelven cláusula resolutoria cuando el testador no la expresa."

8. Quién puede demandar la resolución.

- El beneficiado con el modo.

- En las asignaciones modales, los herederos, pues lo que resta después de pagar el modo acrece a la herencia, con exclusión del asignatario modal (Art. 1096 CC). En el caso de la obligación modal, puede solicitarla la contraparte.

9. Efectos de la resolución de la obligación modal respecto del tercero beneficiario.

Art. 1096 CC. "Siempre que haya de llevarse a efecto la cláusula resolutoria, se entregará a la persona en cuyo favor se ha constituido el modo una suma proporcionada al objeto, y el resto del valor de la cosa asignada acrecerá a la herencia, si el testador no hubiere ordenado otra cosa.
El asignatario a quien se ha impuesto el modo no gozará del beneficio que pudiera resultarle de la disposición precedente."

10. Plazo de prescripción de la obligación modal.

Se aplican las reglas generales: 5 años desde que se hace exigible (Arts. 2514 inc. 2º y 2515 CC).

11. La obligación modal es transmisible.

Art. 1095 CC. "Si el modo consiste en un hecho tal, que para el fin que el testador se haya propuesto sea indiferente la persona que lo ejecute, es transmisible a los herederos del asignatario."

3.11.3. OBLIGACIONES A PLAZO

1. Toda obligación puede estar sometida a un plazo.

Esa es la regla general en el ámbito patrimonial. Ej. Excepciones: Art. 1192 CC que prohíbe modalidades respecto de la legítima, pactos del Art. 1723 CC.

2. Reglamentación del plazo en el Código Civil.

Está tratado en forma inorgánica:

- Arts. 48 a 50 CC: formas de computar los plazos.
- Arts. 1494 a 1498 CC: obligaciones a plazo.
- Arts. 1080 a 1088 CC: asignaciones testamentarias a día.
- Plazo como modo de extinguir los contratos de tracto sucesivo. Ej. Art. 1950 N° 2 (arrendamiento).

3. Concepto de plazo.

Art. 1494 inc. 1º CC. "El *plazo* es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación,..."

Pero esto comprende sólo el plazo suspensivo.

El **plazo** es un acontecimiento futuro y cierto que suspende la exigibilidad o la extinción de un derecho y que produce sus efectos sin retroactividad.

4. Elementos del plazo.

Es un hecho futuro y cierto. La certeza es lo que lo diferencia de la condición. No

existen plazos fallidos, porque el hecho necesariamente va a ocurrir. Lo que suspende es la exigibilidad, no el nacimiento del derecho.

Respecto de las asignaciones testamentarias, los Arts. 1081 a 1088 CC van señalando los casos en que hay plazos o en que hay condiciones. Hay 2 reglas:

- Todas las asignaciones "desde" son condicionales, salvo las desde día cierto y determinado, que son plazos.
- Todas las asignaciones "hasta" están sujetas a plazo, salvo las hasta día incierto e indeterminado, que son condicionales.

5. Clasificación de los plazos.

1) Plazo determinado e indeterminado.

Determinado: se sabe cuándo va a ocurrir el hecho.

Indeterminado: se sabe que va a ocurrir, pero no se sabe cuándo (Art. 1081 inc. 2º CC).

2) Plazo fatal y plazo no fatal.

Fatal: por su sólo cumplimiento se extingue irrevocablemente un derecho. Se conocen por la expresión "en" o "dentro de" y tienen importancia especial en materia procesal.

No fatal: no obstante estar vencido el plazo, puede ejercerse todavía válida y eficazmente el derecho, hasta que no se acuse la rebeldía correspondiente.

3) Plazo expreso y plazo tácito.

Art. 1494 inc. 1º CC. "El plazo... puede ser expreso o tácito. Es tácito el indispensable para cumplirlo."
--

El expreso es el que estipulan las partes.

Esto tiene importancia para efectos de constituir en mora al deudor (Art. 1551 N° 2 CC).

4) Plazos convencionales, legales y judiciales.

Convencional: lo estipulan las partes. Legal:

lo establece la ley.

Judicial: lo fija el juez.

- La regla general es que los plazos sean convencionales.
- Los legales son excepcionales en materia civil, pero abundan en materia procesal.
- Los plazos judiciales son excepcionales:

Art. 1494 inc. 2º CC. "No podrá el juez, sino en casos especiales que las leyes designen, señalar plazo para el cumplimiento de una obligación: sólo podrá interpretar el concebido en términos vagos u oscuros, sobre cuya inteligencia y aplicación discuerden las partes."

- Arts. 904 (para restituir la cosa en la reivindicatoria),
- 1094 (para cumplir el modo),
- 2201 CC (para que el mutuario pague).

Plazo de gracia.

Art. 1656 inc. final CC. "Las esperas concedidas al deudor impiden la compensación; pero esta disposición no se aplica al plazo de gracia concedido por un acreedor a su deudor."

El plazo de gracia no se refiere al que otorga el juez para que el deudor pueda cumplir más allá del plazo convencional, pues este tipo de plazo atentaría contra la ley del contrato y contra el Art. 1494 inc. 2º CC.

El plazo de gracia a que se refiere el Art. 1656 CC es una espera o prórroga que otorga el acreedor.

5) Plazos continuos y discontinuos.

Continuo o corrido: no se suspende durante los feriados.

Discontinuo o de días hábiles: se suspende durante los feriados.

La regla es que los plazos sean corridos (Art. 50 CC). La excepción más importante es la del Art. 66 CPC respecto de los plazos de días. En general, los plazos procesales son de días útiles.

6) Plazos suspensivos y extintivos.

Suspensivo: marca el momento desde el cual empieza el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una obligación.

Extintivo: por su cumplimiento extingue un derecho y la correlativa obligación.

6. Efectos del plazo.

Hay que distinguir entre plazo suspensivo o extintivo, en sus 2 estados.

I. PLAZO SUSPENSIVO PENDIENTE.

El derecho ha nacido (Art. 1084 CC), pero no es exigible. La obligación no es actualmente exigible. Consecuencias:

- 1) El acreedor no puede demandar el cumplimiento de la obligación. Por eso no corre prescripción contra el acreedor (Art. 2514 inc. 2º CC), y no opera la compensación legal (Art. 1656 N° 3 CC).
- 2) Si el deudor paga antes, paga lo debido, y no puede pedir restitución (Art. 1495 CC). El pago anticipado es una renuncia al plazo. Pero esto no se aplica al caso del Art. 1085 CC, referido a las asignaciones desde día cierto pero indeterminado.
- 3) El acreedor puede impetrar medidas conservativas. La ley no lo dice, pero si puede el acreedor condicional, con mayor razón puede el a plazo, que ya tiene

el derecho.

4) El derecho y la obligación a plazo se transmiten (Art. 1084 CC).

II. EFECTOS DEL PLAZO SUSPENSIVO VENCIDO.

La obligación del deudor pasa a ser actualmente exigible, por lo que:

- empieza a correr la prescripción, y
- puede operar la compensación legal.

Si el plazo es convencional, su solo cumplimiento constituye en mora al deudor (Art. 1551 N° 1 CC).

III PLAZO EXTINTIVO PENDIENTE

El acto produce todos sus efectos, como si fuera puro y simple.

IV. PLAZO EXTINTIVO CUMPLIDO:

Se extingue el derecho por el solo ministerio de la ley, pero sin efecto retroactivo. En los contratos de tracto sucesivo, se extingue el contrato.

7. Extinción del plazo.

3 causales:

1) Extinción del plazo por cumplimiento (vencimiento).

Es la forma normal de extinguirse.

2) Extinción por renuncia.

Puede renunciarlo sólo aquel en cuyo beneficio está establecido (Art. 12 CC). Lo normal es que sea en favor del deudor.

Art. 1497 CC. "El deudor puede renunciar el plazo, a menos que el testador haya dispuesto o las partes estipulado lo contrario, o que la anticipación del pago acarree al acreedor un perjuicio que por medio del plazo se propuso manifiestamente evitar.

En el contrato de mutuo a interés se observará lo dispuesto en el artículo 2204."

De acuerdo al Art. 2204 CC, si el mutuo es con interés, no se puede pagar antes, pues el plazo está establecido en beneficio de ambas partes.

3) Extinción por caducidad del plazo.

- Deudor en procedimiento concursal de liquidación, o que se encuentre en notoria insolvencia y no tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de reorganización. (Art. 1496 N° 1 CC)¹³.
- Deudor cuyas cauciones, por hecho o culpa suya, se han extinguido o han disminuido considerablemente su valor. Pero el deudor puede reclamar el beneficio del plazo, renovando o mejorando las cauciones

¹³ Artículo modificado por ley 20.720.

(Art. 1496 N° 2 CC). Requisitos:

1. Que haya un crédito caucionado.
2. Que las cauciones se hayan extinguido o disminuido de valor.
3. Que ello se deba a un hecho o culpa del deudor. Si se debe a caso fortuito, no caduca el plazo, salvo en el caso de la hipoteca.

Caducidad convencional.

Se produce cuando las partes en forma expresa acuerdan que el acreedor pueda exigir el cumplimiento inmediato y total de la obligación, si el deudor incumple con el pago de alguna de las cuotas. Es lo que se llama hoy día "cláusula de aceleración"¹⁴, que crea problemas en cuanto al momento en que empieza a correr la prescripción. La jurisprudencia ha fallado en dos sentidos.

- Si se ha convenido que la cláusula opere ipso facto, la prescripción comienza a correr desde que se produjo el incumplimiento. Si es facultativa, la prescripción empieza a correr, respecto de cada cuota, desde el respectivo incumplimiento.
- La cláusula está establecida en beneficio del acreedor, así que aunque sea ipso facto, debe existir una manifestación expresa del acreedor para hacer exigible la obligación. Mientras ello no ocurra, cada cuota es exigible desde la respectiva fecha de vencimiento.

	PLAZO SUSPENSIVO	CONDICIÓN SUSPENSIVA
1. En qué consiste	Hecho futuro cierto	Hecho futuro incierto
2. Qué produce	Exigibilidad de un derecho	Nacimiento de un derecho
3. Pago anticipado	Se permite, porque el derecho existe	Implica pago de lo no debido y da derecho a repetir
4. Efecto retroactivo	No tiene efecto retroactivo	Tiene, por regla general, efecto retroactivo (se discute)
5. Estados	Pendiente y cumplido	Pendiente, fallida y cumplida

¹⁴ Respecto a las cláusulas de aceleración, es importante tener en cuenta una modificación legal introducida por la Ley N° 20.715, sobre protección a deudores de créditos de dinero. Dicha ley introduce una modificación en el inciso tercero del artículo 30 de la Ley 18.010, que restringe la posibilidad de ejercer la cláusula de aceleración para cobrar anticipadamente: "En aquellas operaciones de crédito de dinero cuyo capital sea igual o inferior a 200 unidades de fomento no podrá en caso alguno hacerse exigible la obligación en forma anticipada, sino una vez cumplidos sesenta días corridos desde que el deudor incurra en mora o simple retardo en el pago. Esta excepción también se aplicará a las operaciones de crédito de dinero que cuenten con garantía hipotecaria de vivienda cuyo capital sea igual o inferior a 2.000 unidades de fomento. Todo pacto en contravención a esta disposición se tendrá por no escrito."

CAPITULO 4. EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES¹⁵

4.1 EXPLICACIONES PREVIAS.

Concepto tradicional de efectos de las obligaciones: son los derechos que la ley confiere al acreedor, para exigir del deudor el cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de la obligación, cuando éste no la cumpla en todo o en parte o está en mora de cumplirla.

Concepto moderno de efectos de las obligaciones: es el deber de prestación que compete al deudor, al cual corresponde el derecho del acreedor a la prestación. El primer efecto será el pago voluntario, y si no lo hay, la ley confiere derechos al acreedor para obtener el cumplimiento.

Efectos del contrato y efectos de la obligación

La obligación contractual se desenvuelve en dos etapas: la primera expresa el deber del deudor de cumplir lo prometido, y da preguntas de formación, interpretación e integración del contrato; la segunda surge del incumplimiento, y se traduce en el conjunto de remedios y acciones que se le otorgan al acreedor. El CC mezcla ambas. etapas Los Arts. 1545, 1546, 1547, 1552, 1554 y 1558 CC se refieren a los efectos de los contratos; las demás disposiciones de ese título se refieren a los efectos de las obligaciones.

Concepto de incumplimiento

Desde la perspectiva del acreedor la relación de obligación supone un interés cautelado por el derecho. Por consiguiente, el incumplimiento consiste en la insatisfacción del interés que fundamenta la relación obligatoria.

El Código Civil no define al incumplimiento, sino que entrega tres hipótesis que lo configuran en el artículo 1556 a propósito de la mora: el incumplimiento total ("no haberse cumplido la obligación"), el cumplimiento imperfecto ("haberse cumplido imperfectamente") y el cumplimiento tardío ("haberse retardado el cumplimiento").

El concepto jurídico de incumplimiento ha sido objeto de discusión doctrinaria. Los autores tradicionales consideraron que el incumplimiento de una obligación contempla un aspecto subjetivo que conlleva una valoración negativa de la conducta del deudor: se requeriría, entonces, que el incumplimiento sea subjetivamente imputable al deudor, de modo que un incumplimiento que no sea atribuible a título de negligencia al deudor no podría servir de fundamento para los remedios que contempla el Código Civil. La doctrina contemporánea prescinde de este requisito, postulando un concepto objetivo de incumplimiento, definiéndolo como aquella desviación del programa prestacional que conforma la operación económica que

¹⁵ Material complementado en base a: Barros Bourie, Enrique: "*Finalidad y alcance de las acciones y remedios contractuales*", en Guzmán Brito, Alejandro (editor científico), Estudios de Derecho Civil III (Santiago, Legal Publishing, 2008) y Barros Bourie, Enrique: "*la diferencia entre "estar obligado" y "ser responsable" en el Derecho de los Contratos*". En Estudios de Derecho Civil II, Santiago, LexisNexis, 2006.

constituye el objeto del contrato. El propósito práctico del contrato define el interés cuya insatisfacción configura al incumplimiento. Este concepto se encuentra reconocido en los principales instrumentos internacionales de derecho de contratos:

Art. 1:301 de los Principios de Derecho Europeo de los Contratos:

"(4) El término 'incumplimiento' denota cualquier incumplimiento de una obligación derivada del contrato, esté o no justificado, e incluye el incumplimiento tardío o defectuoso, así como a la inobservancia del deber de colaborar para que el contrato surta plenos efectos"

Art. 7.1.1 de los Principios UNIDROIT:

"El incumplimiento consiste en la falta de ejecución por una parte de alguna de sus obligaciones contractuales, incluyendo el incumplimiento defectuoso o el cumplimiento tardío"

Art. 86 de los Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos:

"Concepto de incumplimiento

(1) Incumplimiento es la falta de ejecución del contrato en la forma pactada.

(2) El cumplimiento imperfecto comprende toda disconformidad entre lo acordado y lo ejecutado por el deudor

(3) El incumplimiento del deudor comprende el hecho de las personas que emplee para la ejecución"

En definitiva, el incumplimiento comprende cualquier desviación de los deberes que las partes tengan en razón de un contrato:

- a. Ausencia de prestación
- b. Prestación incompleta
- c. Atraso en el cumplimiento
- d. Prestación defectuosa
- e. Infracción de deberes secundarios y de obligaciones de garantía

Acciones frente al incumplimiento y remedios contractuales

En un sentido general, no resulta inadmisibles la asimilación de los conceptos acciones y remedios. No obstante, si deseamos ser más rigurosos con la terminología, es posible distinguir los términos acción frente al incumplimiento y remedio contractual.

El término 'acción' es un concepto propio del derecho procesal, por medio del cual se designa el derecho que cualquier persona tiene para poner en movimiento el aparato jurisdiccional y, de esa manera, reclamar la protección de sus derechos en juicio en caso de ser necesario.

El término 'remedios contractuales', por su parte, es un concepto de origen doctrinario que designa al conjunto de medidas que el ordenamiento jurídico pone a disposición

del acreedor insatisfecho, para tutelar adecuadamente sus intereses jurídicamente protegidos¹⁶. En la discusión civilística nacional, el empleo de dicho término generalmente va asociado a una vocación crítica en torno al sistema de acciones que establece el Código Civil.

De esta manera, por medio del empleo del término 'remedios contractuales', en lugar del término 'acciones frente al incumplimiento', la doctrina moderna enfatiza los siguientes aspectos:

- i) El concepto remedios contractuales es más amplio: incluye a las acciones judiciales propiamente hablando, y también incluye medidas extrajudiciales.
- ii) El concepto remedios contractuales tiene una vocación de sistematicidad que no encontramos en el sistema de acciones que ofrece el Código Civil.
- iii) El concepto remedios contractuales enfatiza el objetivo primario de satisfacer el interés lesionado del acreedor, mientras que el de acciones judiciales enfatiza la consecuencia jurídica del incumplimiento del acreedor.
- iv) Como consecuencia de lo anterior, la noción remedios contractuales acentúa la libre elección de los remedios a emplear por parte del acreedor, pues éste conoce mejor que nadie cuál es la mejor forma de satisfacer su interés lesionado.

Los efectos de las obligaciones en el Código Civil. Esbozos de la crítica moderna.¹⁷

La doctrina contemporánea es bastante crítica de la regulación del Código Civil en materia de efectos de las obligaciones, tanto en relación con su estructura general como en lo relativo a algunas reglas específicas. Respecto a las críticas estructurales a la regulación del Código Civil, podemos mencionar las siguientes:

1. Dispersión de las acciones y remedios ante el incumplimiento

No existe un sistema claro de remedios ante el incumplimiento en el Código Civil. El legislador regula solo algunas acciones en el Título XII del Libro IV del Código; no regula expresamente qué sucede con las obligaciones de dar; no existe una regulación específica de la acción resolutoria sino en relación a las obligaciones condicionales; no existe un criterio claro para resolver el problema de la concurrencia de distintas acciones ante el mismo incumplimiento; etc.

2. Desajuste entre la contratación actual y el modelo de la codificación

Además de su dispersión, el sistema de acciones ante el incumplimiento se encuentra

¹⁶ Para profundizar en torno a este concepto, recomendamos el texto "Hacia un sistema de remedios al incumplimiento contractual", del profesor Carlos Pizarro Wilson.

¹⁷ Apartado basado en el texto "Hacia un sistema de remedios al incumplimiento contractual" del profesor Carlos Pizarro Wilson

¹⁸ La fungibilidad de las obligaciones que predominan en el tráfico jurídico moderno consiste en la idea de que, dada la forma de los mercados modernos, la mayoría de las prestaciones pactadas puede ser satisfecha por muchos proveedores distintos, a diferencia de lo que ocurría en el Chile de la dictación del Código. Lo que le interesa al contratante moderno, más que obtener la ejecución forzosa del contrato, será la rapidez de la resolución del conflicto jurídico.

obsoleto. El codificador diseñó el Código Civil teniendo en mente la obligación unilateral de dar una especie o cuerpo cierto, pues esa era la obligación más común en el tráfico económico de Chile en el siglo XIX. A más de un siglo y medio de la dictación del Código, en la contratación actual predominan las llamadas obligaciones "genéricas" o "fungibles"¹⁸ y los contratos de prestación de servicios, que generan obligaciones de hacer. Así, la estructura de los efectos de las obligaciones no responde adecuadamente al interés de los acreedores contemporáneos.

3. Ausencia de un sistema basado en la protección del interés del acreedor.

En concordancia con el modelo de obligación sobre el cual se basa, el Código le otorga preeminencia a la pretensión de cumplimiento en naturaleza, remedio que no siempre es el que satisface de mejor manera el interés del acreedor. Además, la doctrina clásica analiza las acciones frente al incumplimiento desde la perspectiva de sancionar al deudor más que de la perspectiva de satisfacer al acreedor, exigiéndose la imputabilidad del incumplimiento como requisito general para todas las acciones, en circunstancias que su pertinencia debiera estar limitada a la acción de indemnización de perjuicios.

4.2 EFECTO DE LAS OBLIGACIONES (PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL DEUDOR).

La doctrina tradicional expone el siguiente panorama de acciones y derechos frente al incumplimiento:

1. Derecho principal: Cumplimiento forzado.

2. Derecho subsidiario: Pago de una suma de dinero que le compense lo que le habría significado el cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de la obligación, cuando éste no es posible.

3. Derechos auxiliares de los acreedores destinados a mantener la integridad patrimonial del deudor. (Derecho de prenda general de los acreedores).

4. En los contratos bilaterales podemos agregar la acción resolutoria del contrato, emanada de la condición resolutoria tácita.

Ahora, en cuanto a la distribución concreta de las acciones frente a cada hipótesis específica de incumplimiento, es importante señalar que el criterio del legislador para la organización de las acciones que dispone el acreedor es la naturaleza de la obligación. En particular, será relevante distinguir si la obligación incumplida es de dar, hacer o no hacer:

- Las obligaciones de hacer se rigen según lo dispuesto en el artículo 1553 CC.
- Las obligaciones de no hacer se rigen según lo dispuesto en el art. 1555 CC.
- Las obligaciones de dar carecen de regla especial. Por esa razón, tradicionalmente se ha entendido que debe estarse a lo dispuesto por el art. 1489 CC, regulado a propósito de los contratos bilaterales.

La argumentación de la doctrina y la jurisprudencia tradicional consistía en sostener

el carácter complementario, concurrente y accesorio de la indemnización de los perjuicios. Sus argumentos principales consistían en cierta interpretación del artículo 1545, que consagra el principio de fuerza obligatoria de los contratos, y del artículo 1489, que consagra la condición resolutoria tácita.

Respecto al artículo 1545, se decía, el hecho de que el contrato sea una ley para las partes implica la preeminencia de la acción de cumplimiento forzoso, pues solo de esa manera se aseguraba efectivamente la obligatoriedad del contrato. Respecto del artículo 1489, a partir de su tenor literal ("con" indemnización de perjuicios), se deducía que la indemnización de perjuicios solo podía solicitarse de manera concurrente a la acción de cumplimiento forzoso o la acción resolutoria.

La doctrina¹⁹ y la jurisprudencia²⁰ actual han superado esta posición, que fue absolutamente mayoritaria hasta bien entrado el siglo XXI. Se ha estimado que no hay razón alguna para entender que la acción de indemnización de perjuicios es un remedio subsidiario o concurrente, sino un remedio autónomo. Al respecto, reproducimos un fragmento de un fallo de fecha 30/01/2020, dictado en causa rol 19614-2014 que, a nuestro juicio, explica bien las razones para sostener la autonomía de la acción indemnizatoria:

"Como ya lo ha resuelto esta Corte en oportunidades anteriores, y siguiendo la moderna tendencia doctrinal, se estima que (...) la demandante puede plantear su acción de responsabilidad civil contractual de manera independiente a la de resolución del contrato, pues esta demanda de daños y perjuicios en los términos que se han descrito, debe ser considerada como parte de lo que el comprador debe en "cumplimiento del contrato", de acuerdo con los términos del artículo 1489 del Código Civil" (considerando décimo)

"Que, en el mismo sentido, no puede soslayarse que respecto de la indemnización de perjuicios pura y simple, conforme a los principios que integran el Código Civil, no se observan las particulares motivaciones que podrían inducir a privar a un acreedor de la posibilidad de dirigir las acciones en la forma y del modo como mejor se ajuste a sus intereses, desde el momento que el derecho civil otorga a las personas el principio de libre disposición de sus bienes y autonomía de la voluntad, todo lo cual lleva a reconocer las mayores prerrogativas al momento de someter las pretensiones al órgano jurisdiccional. Es así como esta Corte Suprema ha reconocido la independencia y autonomía de las acciones indemnizatorias, sean estas moratorias o compensatorias, las que cualquiera sea la naturaleza del objeto de la prestación, pueden impetrarse en forma exclusiva, desde el momento que el legislador ha establecido su procedencia y la forma más usual de interposición, pero no ha prohibido la que en mejor forma repare integralmente el daño derivado del incumplimiento (...)" (considerando undécimo)

¹⁹ Esta materia se ha discutido latamente. Para un buen paneo de la discusión, recomendamos solicitar y leer el anexo titulado "autonomía de la acción de indemnización de perjuicios por incumplimiento contractual", que se compartirá a través de infoexamen.

²⁰ Si bien fue un fallo criticado, y sus razonamientos ya se encuentran superados por la jurisprudencia, el caso Zorín con Huachipato fue un hito importante en la evolución de la posición jurisprudencial en esta materia. Para manejar sus aspectos esenciales, recomendamos leer el anexo VIII.

Así, es posible afirmar que, a partir de nuestra jurisprudencia más reciente, la acción de indemnización de perjuicios no es una acción subsidiaria, y puede ejercerse autónomamente. La Corte Suprema ha mantenido este razonamiento en la sentencia causa Rol N°17.740-2023, dictada en julio de 2024.

CUMPLIMIENTO FORZADO (O ESPECÍFICO) DE LA OBLIGACIÓN.

1. Derecho a la ejecución forzada de la obligación.

El fundamento del derecho a pedir la ejecución forzosa de la obligación se encuentra en el artículo 2465 CC, que consagra el así llamado "derecho de prenda general del acreedor".

Art. 2465 CC. "Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, designados en el artículo 1618."

2. Finalidad de la acción de ejecución forzada:

La pretensión en naturaleza permite al acreedor obtener aquello a lo que tiene derecho en virtud del contrato: el cumplimiento de la obligación. Sin embargo, en el evento de que no pueda perseguir la especie debida, dentro de esta misma acción habrá una suerte de "equivalencia" pues se pagará un equivalente monetario de dicha especie.

3. Nacimiento y extinción de la acción.

El único requisito de esta acción es el incumplimiento del deudor. No se realiza un juicio de reproche de su conducta, y tampoco se requiere la Mora de éste, sino sólo que la obligación sea exigible.

La acción solo puede fracasar si el cumplimiento resulta imposible:

(i) si la obligación es de especie o cuerpo cierto, se extingue si ella perece, se destruye, deja de estar en el comercio, o porque desaparece y se ignora si existe (art. 1670)²¹

(ii) Si la obligación es de género, el Derecho asume que el deudor siempre podrá cumplir, pues las hipótesis de imposibilidad son muy excepcionales

(iii) Si la obligación es de hacer, la prestación solo deviene en imposible si no puede ser ejecutada por el acreedor ni por un tercero (a menos que la prestación sea *intuitu personae*)

²¹ En el juicio ejecutivo, corresponde al deudor probar la pérdida de la cosa debida (al ser ésta una excepción para enervar el cumplimiento en naturaleza). Si no lo logra probar, la ley asume que la cosa subsiste en manos distintas y el acreedor tendrá derecho a continuar con la ejecución sobre bienes suficientes para hacerse de su valor en dinero.

4. Cumplimiento forzado en los distintos tipos de obligación.

El cumplimiento depende del tipo de obligación:

- 1) Obligaciones de dinero: el acreedor se dirigirá directamente sobre el dinero del deudor para pagarse, o sobre los bienes del deudor para realizarlos y pagarse con el producto.
- 2) Obligaciones de dar una especie o cuerpo cierto que está en poder del deudor: se dirige a obtener la entrega de esa especie, o al pago de su valor de mercado si lo primero no es posible.
- 3) Obligaciones de hacer: tendrá por objeto que se realice el hecho personalmente por el obligado, o por un tercero si es posible, o, en caso contrario que se convierta en obligación de dinero²².
- 4) Obligaciones de no hacer: se dirige a deshacer lo hecho, si es posible y necesario, o que se transforme en obligación de dinero.

5. Cumplimiento forzado en las obligaciones de dar.

Los requisitos para obtener el cumplimiento forzado en un juicio ejecutivo son:

- 1) Que la obligación conste en un título ejecutivo.
- 2) Que la obligación sea actualmente exigible.
- 3) Que la obligación sea líquida o que pueda liquidarse mediante simples operaciones aritméticas, con sólo los datos que el mismo título ejecutivo suministre.
- 4) Que la acción ejecutiva no se encuentre prescrita. Por regla general, prescribe en 3 años desde que la obligación se hace actualmente exigible.

Si no se reúnen, se debe demandar en juicio declarativo y obtener sentencia que una vez firme servirá de título ejecutivo.

El Código Civil no tiene un tratamiento sistemático de la acción de cumplimiento de dar ni de las formas que esta adopta dependiendo de las características de la obligación. En regímenes especiales de compraventa encontramos regulación acerca del cumplimiento específico de obligaciones de género (Ley N°19.496 sobre Protección a los Derechos del Consumidor y en la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías), contemplando la posibilidad de solicitar la sustitución o reparación de la cosa ante el cumplimiento defectuoso.

Se ha discutido la posibilidad de hacer encajar estas modalidades en el sistema civil, para lo cual se distingue según si la compraventa es específica o genérica y si el vendedor, aparte de vender la cosa, la ha fabricado. En caso de ser genérica la sustitución es aceptable, no así con las compraventas específicas. La reparación

quedaría reservada para las compraventas en las que el vendedor se ha obligado a fabricar la cosa, puesto que en los demás casos la prestación que constituye la reparación rebasa el objeto del contrato, imponiendo al deudor una obligación diversa a la que originariamente contrajo.

6. Cumplimiento forzado de las obligaciones de hacer²³.

Art. 1553 CC. Si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas tres cosas, a elección suya:

- 1.a Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido;
- 2.a Que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor;
- 3.a Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato.

Para que proceda el procedimiento ejecutivo es necesario:

- 1) Que exista un título ejecutivo
- 2) Que sea actualmente exigible
- 3) Que la obligación esté determinada
- 4) Que la acción no se encuentre prescrita.

El procedimiento será distinto según si el hecho debido consiste en:

- a) La suscripción de un instrumento o en la constitución de una obligación: puede hacerlo el juez si el deudor no lo hace dentro de un plazo.
- b) Si el hecho consiste en la ejecución de una obra material: se le da un plazo al deudor para que empiece el trabajo.

Si el acreedor demanda perjuicios, debe hacerlo en un juicio declarativo, cuya sentencia fije la existencia y monto de estos.

²² Cuanto el cumplimiento forzado recae sobre una cantidad de dinero, no es posible hablar propiamente de una indemnización de perjuicios, sino que comprende únicamente el valor de mercado de la prestación y eventuales intereses, pero no comprende "todo daño sufrido por el acreedor"

²³ Según el artículo 1553 CC, el cumplimiento forzado de una obligación de hacer supone apremiar al deudor para la realización del hecho convenido. Se ha señalado en diversos sistemas legales que las obligaciones de hacer no pueden ser ejecutadas forzosamente pues se impone una carga excesivamente severa a la libertad personal.

7. Cumplimiento forzado en las obligaciones de no hacer.

Art. 1555 CC. "Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios, si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho. Pudiendo destruirse la cosa hecha, y siendo su destrucción necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, será el deudor obligado a ella, o autorizado el acreedor para que la lleve a efecto a expensas del deudor. Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído el deudor que se allane a prestarlo. El acreedor quedará de todos modos indemne."

4.3 INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS.

1. Generalidades

El incumplimiento por parte del deudor da lugar a una pretensión de cumplimiento en naturaleza (derecho para pedir ejecución forzada), y a una pretensión indemnizatoria.

Respecto a la naturaleza de esta obligación indemnizatoria, podemos identificar dos posiciones en doctrina:

a) Para la doctrina tradicional, la obligación de indemnizar los perjuicios es la misma obligación que dejó de cumplirse y que, ante el incumplimiento, cambia de objeto. Así, en lugar de perseguirse el cumplimiento de la obligación en los mismos términos en que se pactó (cumplimiento en naturaleza), se persigue una suma de dinero que represente para el acreedor el mismo beneficio que le habría significado el cumplimiento (cumplimiento por equivalencia)

b) La doctrina moderna critica esta posición pues, a su juicio, esta confundiría la posición jurídica de 'estar obligado' con la de 'ser responsable'²⁴. Así, para la doctrina moderna, la obligación indemnizatoria es una obligación nueva, distinta de la obligación emanada directamente del contrato, cuyo hecho generador es el incumplimiento imputable por parte del deudor.

2. Definición tradicional de la indemnización de perjuicios: derecho del acreedor para obtener del deudor el pago de una cantidad de dinero equivalente al beneficio

²⁴ Para una explicación más detallada acerca de la diferencia entre estar obligado y ser responsable, revisar anexo IX

pecuniario que le habría reportado el cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de la obligación.

3. Extensión de la indemnización. Interés positivo y negativo.

La extensión de la indemnización corresponde a los daños sufridos por el acreedor como consecuencia directa del incumplimiento por parte del deudor, siempre y cuando concurren los demás requisitos legales. Ahora bien, es necesario preguntarse cuáles son los intereses cuya afectación se ve protegida por la indemnización. Para efectos de analizar este problema, la doctrina recurre a una distinción respecto a los intereses del acreedor, en relación con el interés negativo y el interés positivo.

La indemnización de perjuicios derivada del interés negativo tiene por objetivo colocar al acreedor en una posición similar a la que estaba antes de que el contrato se hubiese celebrado. Así, comprende el daño efectivamente sufrido por el acreedor como consecuencia del incumplimiento.

La indemnización de perjuicios derivada del interés positivo tiene por objetivo colocar al acreedor en una posición similar a la que hubiera estado si el deudor hubiese cumplido de manera íntegra y oportuna. Así, comprende las expectativas de beneficios que el contrato le habría reportado si se hubiese ejecutado en el tiempo y la forma debidos.

Esta distinción resulta pertinente para analizar el problema de la concurrencia de la indemnización con otros remedios contractuales, como la resolución, o para analizar el problema de la extensión de una indemnización de perjuicios por responsabilidad pre-contractual. Así, cuando se solicita conjuntamente la resolución con la indemnización de perjuicios, resulta discutible si es que el demandante puede exigir la indemnización de los intereses positivos, o si debe limitarse a pedir los negativos. De la misma forma, cuando se pide la indemnización de perjuicios por rupturas injustificadas de las negociaciones, parece más claro que la indemnización debe limitarse a los intereses negativos.

4. Función.

Tiene una doble función:

- 1) Es una sanción para el deudor que incumple con dolo o culpa.
- 2) Es un medio para que el acreedor pueda obtener el cumplimiento por equivalencia.

5. Según la doctrina tradicional, la indemnización de perjuicios es un derecho subsidiario.

Para la doctrina tradicional, el deudor debe cumplir en la forma convenida; la indemnización sólo puede pedirse:

- Subsidiariamente, respecto de las obligaciones de dar,
- Directamente en las de hacer y no hacer

Recordar que, como hemos dicho más arriba, esta posición se encuentra superada.

6. Clases de indemnización.

1) Compensatoria: es la cantidad de dinero a que tiene derecho el acreedor para repararle el perjuicio que le reportó el incumplimiento total o parcial de la obligación.

2) Moratoria: es aquella que tiene por objeto reparar al acreedor el perjuicio sufrido por el cumplimiento tardío de la obligación.

7. No se pueden acumular el cumplimiento y la indemnización de perjuicios compensatoria, pero sí el cumplimiento y la indemnización moratoria.

- No se puede acumular cumplimiento + indemnización compensatoria: Como la indemnización compensatoria equivale al cumplimiento, no se pueden demandar conjuntamente, porque importaría un doble pago.
- Se puede acumular cumplimiento + indemnización moratoria.
- Se puede acumular indemnización compensatoria + indemnización moratoria.
- Por excepción, en la cláusula penal se puede acumular el cumplimiento y la pena (Art. 1537 CC).

8. Requisitos de la indemnización de perjuicios.

1. Incumplimiento del deudor.
2. Perjuicio del acreedor.
3. Relación de causalidad entre incumplimiento y perjuicios.
4. Imputabilidad del deudor (dolo o culpa).
5. Que no concurra una causal de exención de responsabilidad.
6. Mora del deudor.

4.3.1 INCUMPLIMIENTO DEL DEUDOR.

Debe incumplir una obligación contractual.

- Si no existe un contrato previo entre las partes, no puede existir responsabilidad contractual.
- Es necesario que el contrato sea válido.

• ¿Cuándo hay incumplimiento?

Las hipótesis en que la ley considera que hubo un incumplimiento de la obligación se derivan de lo establecido en el Art. 1556 CC; las hipótesis serían las siguientes:

- a. No haberse cumplido la obligación (incumplimiento absoluto).
- b. Haberse cumplido imperfectamente.
- c. Haberse retardado el incumplimiento.

• Ámbito de aplicación de estas normas.

Son el derecho común en materia de indemnización, aplicándose cualquiera sea el origen de la obligación incumplida.

No se aplican las reglas de responsabilidad contractual:

- Cuando la ley ha dado reglas distintas, como ocurre en la responsabilidad extracontractual.
- Cuando las partes se han dado reglas especiales.

Sin embargo, hay quienes opinan que el derecho común son las reglas de la

responsabilidad extracontractual.

4.3.2. PERJUICIO DEL ACREEDOR.

Este requisito fluye de varias disposiciones: Arts. 1548, 1553 N°3 y 1559 N°2 CC.

Perjuicio o daño: detrimento, menoscabo o lesión que sufre alguien tanto en su persona como en sus bienes.

Si el incumplimiento del contrato no genera perjuicios al acreedor, no hay lugar a la indemnización.

- **Prueba de los perjuicios.**

Corresponde al actor (Art. 1698 CC). Excepcionalmente no es necesario probarlos:

- Cuando existe cláusula penal (Art. 1542 CC).
- Tratándose de la indemnización moratoria en una obligación de dinero (Art. 1559 N° 2 CC).

- **Clases de perjuicios.**

1. Daño moral (extra patrimonial) y daño material (patrimonial).
2. Perjuicio directo (previsto e imprevisto) y perjuicio indirecto.
3. Daño emergente y lucro cesante.

Daño material: menoscabo que experimenta el patrimonio del acreedor.

Daño moral: lesión a un interés jurídico extra patrimonial. El daño produce una perturbación injusta en el espíritu del acreedor, es un perjuicio en la psiquis del individuo.

4.3.3. RELACIÓN DE CAUSALIDAD (NEXO CAUSAL) ENTRE EL INCUMPLIMIENTO Y LOS PERJUICIOS.

Esta exigencia se desprende de los Arts. 1556 y 1558 CC.

Consecuencia de ello es que no se indemnizan los perjuicios indirectos ni aun en el caso de incumplimiento doloso.

El requisito del nexo causal se exige también en la responsabilidad extracontractual.

4.3.4. IMPUTABILIDAD DEL DEUDOR (DOLO O CULPA DEL DEUDOR).

Este requisito supone la realización de un juicio de reproche a la conducta del deudor, quien debe haber actuado con dolo o con culpa para ser responsable²⁵.

- **Dolo contractual:**

Art. 44 inc. final CC. "El *dolo* consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro."

²⁵ Parte de la doctrina ha señalado que se prescinde de este requisito en caso de incumplimiento de obligaciones de dinero (art. 1559), por ser un caso de responsabilidad estricta.

A) Comprende sólo dolo directo: Si nos atenemos al tenor literal, el dolo sólo existe cuando la acción u omisión del deudor se realiza con la intención premeditada de causar ese daño (dolo directo). Así se ha entendido tradicionalmente, descartando la figura del dolo eventual.

B) Comprende dolo directo y dolo eventual: Pero algunos autores opinan que comprende ambas hipótesis de dolo. El dolo consiste en la representación del efecto dañoso en nuestro actuar (acción u omisión), unida a la certeza (dolo directo) o la mera probabilidad (dolo eventual) de que el efecto se produzca.

En la práctica, el deudor no deja de cumplir para perjudicar al acreedor, sino para conseguir una ventaja.

- **Campos en que incide el dolo civil.**

1. En la fase de formación del consentimiento, como vicio.
2. En la fase de cumplimiento de los contratos.
3. En la responsabilidad extracontractual.

- **Teoría unitaria del dolo²⁶.**

El concepto de dolo es en los 3 campos el mismo:

1. Está definido en el título preliminar.
2. Siempre importa una intención de perjudicar a otro.
3. El efecto del dolo es el mismo: tiende a restablecer la situación anterior a él.
4. Las reglas que gobiernan el dolo son las mismas.

- **Prueba del dolo.**

Art. 1459 CC. "El dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por la ley. En los demás debe probarse."

Esta norma es de aplicación general, lo que concuerda con la presunción de buena fe.

Casos en que se presume:

- 1) Art. 1301 CC: albacea que lleva a efecto disposiciones testamentarias contrarias a ley.
- 2) Art. 968 N° 5 CC: ocultación del testamento.
- 3) Art. 2261 CC: en la apuesta, cuando se sabe que se va a verificar o se ha verificado el hecho.
- 4) Art. 94 N° 6 CC: en la muerte presunta (ocultar la muerte o existencia).
- 5) Art. 280 CPC: solicitar medida precautoria prejudicial y no demandar dentro de plazo.

²⁶ Ver Anexo II al final.

- **Efectos del dolo en el incumplimiento de las obligaciones.**

Agrava la responsabilidad del deudor. Lo normal es que el deudor responda de los perjuicios directos previstos, pero si hay dolo, responde además de los directos imprevistos (Art. 1558 CC).

Además, algunos consideran que en caso de ser varios los que cometen dolo, se generaría entre ellos solidaridad. Esta interpretación proviene del Art. 2317 inciso 2 CC, que establece "Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso." Si bien se trata de una disposición legal relativa a la responsabilidad extracontractual, quienes defienden esta postura dicen que si no se entiende dicho artículo de este modo, el inciso segundo no estaría sino repitiendo lo ya establecido en el inciso primero, por lo tanto para darle contenido debe interpretarse como de aplicación general, incluyendo a las relaciones contractuales.

- **El dolo no se puede renunciar anticipadamente.**

Puede renunciarse el dolo pasado, en forma expresa (Art. 1465 CC).

- **El dolo se aprecia en concreto, no en abstracto, como la culpa.**

En cada caso deberá el juez resolver si la conducta del deudor resulta o no dolosa.

- **De la culpa contractual.**

Culpa: omisión de la diligencia que se debe emplear en el cumplimiento de una obligación o en la ejecución de un hecho.

Culpa contractual: falta de cuidado debido en el cumplimiento de un contrato.

Se discute si la culpa contractual y extracontractual son una sola o son diferentes.

- **Diferencias entre la culpa contractual y extracontractual.**

1. Vínculo jurídico. La contractual supone un vínculo jurídico previo; la extracontractual no.
2. Gradación. La contractual admite grados; la extracontractual es una sola.
3. Prueba. La contractual se presume; la extracontractual debe probarse.
4. Mora. Para que la contractual origine indemnización, el deudor debe constituirse en mora; en la extracontractual no es necesaria la mora.

- **Gradación de la culpa.**

Art. 44 incs. 1º a 5º CC. "La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. *Culpa* o *descuido*, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la *diligencia* o *cuidado ordinario* o *mediano*.

El que debe administrar un negocio como un *buen padre de familia* es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o *descuido levísimo* es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la *suma diligencia* o *cuidado*."

La culpa contractual se aprecia en abstracto: la ley compara la conducta del sujeto con un modelo ideal.

- **La culpa grave equivale al dolo²⁷.**

Se ha señalado que esta equiparación tiene el propósito de evitar que el deudor que procede con dolo pretenda excusarse, argumentando que no ha existido de su parte la intención positiva de perjudicar al deudor.

¿Cuál es el alcance de esta afirmación?

- Implica que la culpa grave debe también probarse, al igual que el dolo.
 - ✓ El Art. 44 CC no hace distinciones, equiparando absolutamente ambos conceptos.
 - ✓ La norma viene de Pothier, que le daba alcance amplio.
 - ✓ No es lógico presumir la culpa grave contractual si ni el dolo ni la mala fe se presumen.
- La mayoría de la doctrina estima que la equivalencia no tiene alcances probatorios.
 - ✓ La culpa se presume siempre, aunque sea la grave. El dolo en cambio, supone procedimientos fraudulentos, y estos siempre requieren de prueba.
 - ✓ No pueden llegar a ser dolo y culpa grave una misma cosa, pues por algo el Art. 44 CC da dos definiciones.

- **De qué culpa responde el deudor.**

- 1) De la culpa a que se haya obligado (Art. 1547 inc. final CC).
- 2) De la culpa específica que establezca determinado contrato (Ejemplo: mandato, fianza)
- 3) Si las partes nada han acordado, se sigue la siguiente regla:

²⁷ Ver anexo I al final.

Art. 1547 inc. 1º CC. "El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza sólo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la levísima, en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio."

Lo normal es que se responda hasta de la culpa leve. Así ocurre con el que administra bienes ajenos.

- **Cláusulas para alterar la responsabilidad de las partes.**

- 1) Que el deudor responda de un grado mayor o menor de culpa en relación al Art. 1558 CC.
- 2) Que el deudor responda del caso fortuito.
- 3) Que el deudor responda en todo caso de los perjuicios imprevistos.
- 4) Limitación del monto de la indemnización.
- 5) Limitación de los plazos de prescripción.
- 6) Alteración de las reglas del onus probandi (discutible).

- **Límites de estas cláusulas modificatorias de responsabilidad.**

Las partes no pueden:

- 1) Renunciar al dolo futuro o a la culpa grave (Arts. 1465 y 44 CC).
- 2) Contravenir el orden público o la ley; habría objeto ilícito.

- **La culpa contractual se presume.**

Art. 1547 inc. 3º CC. "La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega."

Excepción: Art. 2158 CC (mandato).

- **Culpa del deudor por el hecho de personas que dependen de él.**

Art. 1679 CC. "En el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las personas por quienes fuere responsable."

Reitera esta misma idea el Art. 1590 incs. 1º y 3º CC.

En el caso de hechos de terceros por quienes no responde el deudor, el acreedor sólo puede exigir que se le ceda la acción que tenga su deudor contra el tercero autor del daño (Arts. 1590 inc. final y 1677 CC).

4.3.5 QUE NO CONCURRA UNA CAUSAL DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD.

1. Fuerza mayor o caso fortuito.
2. Ausencia de culpa.
3. Estado de necesidad.
4. Hecho o culpa del acreedor.
5. Teoría de la imprevisión.

4.3.5.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

Art. 45 CC. "Se llama *fuerza mayor* o *caso fortuito* el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc."

Se dice que a esta definición le falta el requisito de inimputabilidad. Pero esto aparece en el Art. 1547 inc. 2º CC.

El CC, la doctrina y la jurisprudencia hacen sinónimas las expresiones "caso fortuito" o "fuerza mayor". Pero algunos autores hacen la distinción, generalmente diciendo que:

- la fuerza mayor proviene de un hecho de la naturaleza,
- y el caso fortuito, de un hecho del hombre.

• Elementos del caso fortuito.

1. Inimputable. No debe provenir del hecho o culpa del deudor o de las personas por quien responde.
2. Imprevisto. Que dentro de los cálculos ordinarios de un hombre normal, no sea dable esperar su ocurrencia. Que no haya ninguna razón esencial para creer en su realización.
3. Irresistible. Impide al deudor, bajo todo respecto o circunstancia, poder cumplir.

• Efectos del caso fortuito.

Libera de responsabilidad al deudor (Arts. 1547 inc. 2º y 1558 inc. 2º CC). Ahora bien, resulta discutible si el caso fortuito opera como eximente de la responsabilidad en sede de culpabilidad o en sede de causalidad.

Para quienes estiman que opera en sede de culpabilidad, alegar caso fortuito implica alegar que ha ocurrido un hecho imprevisible, irresistible, e inimputable que ha impedido el cumplimiento, y cuya evitación excedía los límites de su diligencia debida. En otras palabras, alegar caso fortuito termina siendo prácticamente equivalente a alegar la ausencia de culpa.

Para quienes estiman que opera en sede de causalidad, alegar caso fortuito implica sostener que, con prescindencia de si el deudor ha operado con culpa o no, es el caso fortuito el que explica causalmente el daño producido por el acreedor.²⁸ De esta forma, quien alega caso fortuito alega que su conducta no ha tenido nada que ver con el daño, incluso si ha incurrido en culpa, aunque siempre con el límite de que el caso fortuito mismo no se haya producido por su culpa.

• Excepciones en las que el caso fortuito no libera de responsabilidad al deudor.

- 1) Cuando el caso fortuito sobreviene por culpa del deudor (Arts. 1547 inc. 2º, 1590

²⁸ Así, por ejemplo, el profesor Carlos Pizarro Wilson. "La fuerza mayor como defensa del deudor. A propósito de la restricción de suministro de gas a Chile" (2005)

- inc. 1º y 1672 inc. 2º CC). No es propiamente caso fortuito, porque es imputable.
- 2) Cuando sobreviene durante la mora del deudor (Arts. 1547 inc. 2º, 1672 inc. 2º y 1590 inc. 1º CC). Esta excepción no rige si el caso fortuito igualmente hubiera sucedido tendiendo el acreedor la cosa debida en su poder.
- 3) Cuando se ha convenido que el deudor responda del caso fortuito (Arts. 1547 inc. final y 1558 inc. final CC).
- 4) Cuando la ley pone el caso fortuito de cargo del deudor (Art. 1547 inc. final CC). Ej. Art. 1676 CC respecto del que ha robado o hurtado una cosa.

- **Prueba del caso fortuito.**

Incumbe la prueba del caso fortuito al que lo alega (Arts. 1547 inc. 3º y 1674 CC), lo que es aplicación de la regla general del onus probandi del Art. 1698 CC. Excepción: Art. 531 de la Ley 20.667 respecto al contrato de seguros: **"El siniestro se presume ocurrido por un evento que hace responsable al asegurador"**

4.3.5.1.1 TEORÍA DE LOS RIESGOS.

Es aquella teoría que (1) Resuelve quién debe soportar en los contratos bilaterales la pérdida de la especie o cuerpo cierto debido, (2) si el deudor no puede cumplir su obligación de entregar esa cosa, (3) por haberse destruido por un caso fortuito o fuerza mayor.

El riesgo es del:

- deudor cuando no puede exigir a la contraparte que cumpla su propia obligación;
- del acreedor si éste debe de todas formas cumplir su propia obligación.

- **Requisitos para que opere la teoría de los riesgos.**

1. Existencia de un contrato bilateral.
2. Que la obligación del deudor sea de entregar una especie.
3. Que cosa debida se pierda o destruya totalmente como consecuencia de un caso fortuito.

- **Principio contenido en el Código en materia de riesgos.**

Art. 1550 CC. "El riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba, es siempre a cargo del acreedor;..."

Esta regla es injusta, porque contradice el principio de que las cosas perecen para su dueño. La explicación es que la disposición se copió del Código Francés, en el cual el sólo contrato transfiere el dominio.

- **Ámbito de aplicación de la norma.**

Se aplica solo a compraventas y permutas no condicionales.

Art. 1820 CC. "La pérdida, deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que se vende, pertenece al comprador, desde el momento de perfeccionarse el contrato, aunque no se haya entregado la cosa; salvo que se venda bajo condición suspensiva, y que se cumpla la condición, pues entonces, pereciendo totalmente la especie mientras pende la condición la pérdida será del vendedor, y la mejora o deterioro pertenecerá al comprador." (En relación al Art. 1900 CC).

- **Casos de excepción en que el riesgo de la especie o cuerpo cierto debido es del deudor.**

- 1) Cuando el deudor se constituye en mora de entregar (Art. 1550 CC).
- 2) Cuando el deudor se ha comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas por obligaciones distintas (Art. 1550 CC).
- 3) Cuando las partes lo convienen (Arts. 1547 inc. final y 1558 inc. final CC).
- 4) Cuando la ley así lo establece:
 - ✓ Art. 1950 N° 1 CC: extinción del contrato de arrendamiento por destrucción de la cosa.
 - ✓ Art. 1486 CC: obligaciones condicionales.
 - ✓ Art. 1820 CC: compraventas condicionales.
 - ✓ Art. 1996 inc. 2° CC: contrato para la confección de una obra material cuando los materiales los pone el artífice (es en realidad una venta condicional).

- **Pérdida parcial.**

El CC no da reglas especiales, por lo que debe aplicarse el Art. 1550 CC.

4.3.5.2. AUSENCIA DE CULPA.

Esta causal de exención no es generalmente aceptada. Su aceptación genérica como causal de exención de la responsabilidad eventualmente podría hacer colapsar la distinción entre obligaciones de medios y de resultados, con el consiguiente impacto en la posición general de los acreedores en la contratación contemporánea. El problema puede plantearse en los siguientes términos: ¿le basta al deudor probar que ha empleado la debida diligencia para liberarse de responsabilidad, o debe probar además el caso fortuito?

En las obligaciones de medio, donde el deudor cumple su obligación desplegando una conducta acorde con la diligencia que resulte exigible según el contrato de que se trate, esta excusa debe considerarse admisible, toda vez que acreditar el empleo de la diligencia debida equivale a acreditar el cumplimiento. En las obligaciones de resultado, en cambio, dicha excusa no sería admisible, pues el deudor se ha obligado precisamente a satisfacer el interés primario de la pretensión del acreedor.

A mayor abundamiento, ciertos sectores de la doctrina contemporánea abogan por una comprensión objetiva de la responsabilidad contractual²⁹ y, por consiguiente, una comprensión objetiva del incumplimiento contractual³⁰. Estos autores consideran que

²⁹ Carlos Pizarro Wilson. "La fuerza mayor como defensa del deudor. A propósito de la restricción de suministro de gas a Chile"

³⁰ Por ejemplo, Barros: "Entendido el incumplimiento objetivamente como insatisfacción del

las obligaciones de resultado son un ejemplo paradigmático de la responsabilidad objetiva contractual. Una comprensión objetiva de la responsabilidad contractual implica entender que el hecho generador de la responsabilidad es la insatisfacción de la pretensión del acreedor, sin tomar en cuenta el factor subjetivo ligado al incumplimiento. Desde este punto de vista, cualquier excusa ligada a la culpabilidad debe ser excluida, y solo serían admisibles las excusas que digan relación con la causalidad, particularmente el caso fortuito.

4.3.5.3. EL ESTADO DE NECESIDAD.

Es el caso en que el deudor, pudiendo cumplir, no lo hace para evitar un mal mayor. La doctrina no es unánime en cuanto a aceptarlo como causal de exención.

A) Varios autores estiman que es necesario que se configure fuerza mayor para liberarse de responsabilidad. El CC toca el punto en un caso, desechando el estado de necesidad (Art. 2178 N° 3 CC).

B) La tendencia moderna es que el estado de necesidad legitima el hecho y libera al deudor de responsabilidad.

4.3.5.4. HECHO O CULPA DEL ACREEDOR.

No está regulado en forma orgánica, pero el CC se refiere a ella en varias disposiciones para exonerar de responsabilidad al deudor. Ej. Arts. 1548, 1680 y 1827 CC (que en general, liberan al deudor de la responsabilidad de conservar la cosa debida cuando el acreedor se constituye en mora de recibir).

4.3.5.5. TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN.

- **Concepto.**

- (1) Es la doctrina jurídica que sostiene que el juez puede intervenir en la ejecución de la obligación
- (2) con el objeto de atenuar sus efectos,
- (3) cuando, a consecuencia de acontecimientos imprevisibles para las partes al momento de contratar, ajenos a su voluntad,
- (4) la ejecución de la obligación se hace más difícil o más onerosa.

- **Elementos de la imprevisión.**

- 1) Que se trate de un contrato de tracto sucesivo, o por lo menos de ejecución diferida.
- 2) Que por circunstancias sobrevinientes, ajenas a las partes y no previstas, se produzca un desequilibrio patrimonial en las prestaciones.

interés del acreedor (...) en el caso de un incumplimiento de una obligación de resultado, el propio incumplimiento puede ser imputado subjetivamente al deudor en la forma de una especie de culpa infraccional, que sólo admite como excusa la prueba del caso fortuito por el deudor [En: Barros Bourie, Enrique: *"Finalidad y alcance de las acciones y remedios contractuales"*, en Guzmán Brito, Alejandro (editor científico), Estudios de Derecho Civil III (Santiago, Legal Publishing, 2008) p.416]

3) Que los hechos que lo producen sean tan extraordinarios y graves, que si las partes los hubieran tenido a la vista al momento de contratar, no habrían contratado, o lo habrían hecho en condiciones diferentes.

- **Posiciones doctrinarias.**

- La primera posición afirma que como el contrato es una ley para las partes, ninguna de ellas puede desconocerlo, aunque hayan variado las condiciones bajo las cuales lo celebraron (*pacta sunt servanda*). Así lo exige la seguridad jurídica.

- La segunda posición sostiene que debe admitirse, por razones de equidad, la revisión de los contratos cuando varían gravemente, y por causas imprevistas, la condiciones bajo las cuales el contrato fue acordado (*rebus sic stantibus*). La voluntad de las partes se manifestó en relación con el medio existente y los riesgos normales.

- **Teoría de la imprevisión en Chile.**

Se estima que no tiene cabida, por el Art. 1545 CC. Pero hay casos puntuales en que la ley la acepta, y otros en que en forma expresa la rechaza.

La acepta en los Arts.:

- 2003 regla 2ª. Contratos para construcción de edificios en que por circunstancias desconocidas se ocasionan costos que no pudieron preverse (empresario puede solicitar autorización al dueño o, en subsidio, solicita al juez que decida)
- 2180 Comodante puede pedir restitución de la cosa si le sobreviene necesidad imprevista y urgente de la cosa.
- 2227 Depositante puede solicitar se le entregue la cosa si pelagra en manos del depositario.

La rechaza en los Arts.:

- 2003 regla 1ª. Contratos para construcción de edificios, el empresario no podrá pedir aumento del precio a pretexto de aumento del precio de los materiales.
- 1983 CC. Colono no tendrá derecho para pedir rebaja del precio, alegando casos fortuitos extraordinarios.

- **Argumentos a favor de la teoría de la imprevisión.**

1) Art. 1560 CC. Cabe presumir que la intención de las partes al momento de contratar fue la mantención del contrato en el entendido de que no varíen substancialmente las condiciones existentes en ese momento.

2) Art. 1546 CC. Sería contrario a la buena fe que una de las partes pretenda que la otra cumpla en condiciones excesivamente onerosas.

3) Toda persona al contratar contrae un determinado deber de cuidado. Si cambian las condiciones, pasaría a asumir un riesgo que va más allá del que el deudor aceptó.

4) Por regla general, el deudor responde únicamente de los daños previstos (Art. 1558 CC).

4.3.6 MORA DEL DEUDOR.

Art. 1557 CC. "Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora,...".

Esta idea es reiterada por el Art. 1538 CC, en materia de cláusula penal. Esta exigencia rige tanto para la indemnización compensatoria como para la moratoria. Pero hay autores que opinan que rige sólo para la moratoria.

Se afirma que no se requiere en las obligaciones de hacer, pues la indemnización se debe desde la contravención (Art. 1557 CC). Pero en este caso lo que ocurre es que la mora se produce por el sólo hecho de la contravención.

- **Concepto de mora.**

- (1) es el retardo imputable en el cumplimiento de la obligación
- (2) unido al requerimiento o interpelación por parte del acreedor.

- **Requisitos de la mora.**

1) Que el deudor retarde el cumplimiento de la obligación.

Se debe distinguir entre exigibilidad, retardo y mora.

- La obligación es exigible cuando no está sujeta a modalidades suspensivas.
- Se retarda cuando no se cumple en la oportunidad debida.
- La mora supone el retardo imputable del deudor más allá de la interpelación hecha por el acreedor (Arts. 1551 y 1558 CC).

2) Que el retardo le sea imputable al deudor.

El retraso en el cumplir tiene que deberse a dolo o culpa del deudor (Art. 1558 CC)

3) Interpelación del acreedor.

Interpelación: Acto por el cual el acreedor hace saber al deudor que su retardo le causa perjuicios. Hay 3 formas:

Art. 1551 CC. "El deudor está en mora,
1. Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley en casos especiales exija que se requiera al deudor para constituirle en mora; (contractual expresa)
2. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto espacio de tiempo, y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla; (contractual tácita)
3. En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor." (Judicial, regla general)

1. Interpelación contractual expresa (art. 1551 N° 1).

Las partes han establecido un plazo en el contrato para que el deudor cumpla su obligación. Por el solo hecho de cumplirse el plazo, el deudor queda constituido en mora, salvo que la ley exija que se le requiera para constituirlo en mora. Ej. Art. 1949 CC.

2. Interpelación contractual tácita (art. 1551 N° 2).

La obligación, por su propia naturaleza y por la forma como fue convenida, tiene un plazo tácito para cumplirse.

3. Interpelación judicial (o extracontractual) (art. 1551 N°3).

La regla general es que para que el deudor quede constituido en mora, se le debe demandar. Se ha entendido que cualquier gestión judicial destinada a que el acreedor haga efectivos sus derechos es suficiente requerimiento. Queda el deudor constituido en mora cuando se le notifica válidamente la demanda.

4) Que el acreedor, si el contrato es bilateral, haya cumplido su propia obligación o se allane a cumplirla en la forma y tiempo debidos.

Tratada en el Art. 1552 CC, corresponde a la excepción de contrato no cumplido que "es la que corresponde al deudor en un contrato bilateral para negarse a cumplir su obligación mientras la otra parte no cumpla o se allane a cumplir la suya."³¹

Se puede ejercer sin importar la forma en que se está haciendo valer la obligación, tanto judicial como extrajudicialmente. Si bien el legislador la trata sólo a propósito de la indemnización de perjuicios, también podría hacerse valer si es que se está exigiendo el cumplimiento forzado o la resolución del contrato.

Requisitos de la excepción de contrato no cumplido:

1. Se aplica a los contratos bilaterales, (se trata de una excepción netamente patrimonial).
2. Es necesario que contra quien se opone la excepción no haya cumplido ni esté llano a cumplir. No basta que señale que está llano a hacerlo sino que de principio a la ejecución.
3. Es necesario que la obligación del acreedor sea exigible.
4. Buena Fe de quien opone la excepción. Este requisito busca evitar que se transforme en una herramienta que permita al deudor evadir el

³¹ Si bien la doctrina tradicional considera que el artículo 1552 contiene la excepción de contrato no cumplido, cierta doctrina más moderna distingue la excepción de contrato no cumplido y la compensación en mora, siendo esta última la que estaría consagrada en el art. 1552. Según la profesora Claudia Mejías Alonzo: "La excepción de contrato no cumplido suspende temporalmente la pretensión de cumplimiento y su forma pura de operar es mediante una excepción en el juicio respectivo. La compensación en mora, por su parte, impide que uno de los contratantes pueda ser considerado en mora mientras no cumpla o se allane a hacerlo y opera de pleno derecho; constitución que se nos presenta vinculada a un mecanismo concreto de tutela del acreedor lesionado: la indemnización de perjuicios.

cumplimiento de su propia obligación, aplicación de lo mismo permite no acoger la excepción si es que se trata de incumplimientos insignificantes.

Prueba: En cuanto a quién le corresponde probar que concurre la hipótesis de la excepción, si bien se ha discutido, existe tendencia en favor de considerar que corresponde al deudor probar que concurren los requisitos de la excepción de contrato no cumplido, por aplicación del principio general consagrado en el Art. 1698 CC.

Efectos: Tiene un efecto meramente paralizador. Impide que se fuerce al deudor a cumplir mientras su contraparte no lo haga a su vez. Pero no le sirve para obtener el cumplimiento recíproco.

El problema se presenta cuando ninguna de las partes cumple con su obligación ya que la aplicación de la excepción conduce a un punto muerto. El contrato queda en suspenso, y no existe una solución contemplada para este caso en el Código Civil. La Corte Suprema, en estos casos, ha aceptado la resolución del contrato sin indemnización de perjuicios.

- **Efectos de la mora del deudor.**

1) El acreedor puede demandar indemnización de perjuicios (Art. 1557 CC).

¿Desde cuándo se deben pagar los perjuicios?

- ✓ Algunos estiman que deben pagarse desde el retardo (incumplimiento).
- ✓ Otros sostienen que los perjuicios compensatorios se producen por el solo incumplimiento, pero los moratorios sólo se van a general con la constitución en mora.

2) El deudor se hace responsable del caso fortuito (Art. 1547 inc. 2º CC).

Excepción: si el caso fortuito hubiese sobrevenido a pesar de haberse cumplido oportunamente la obligación, hecho que debe probar el deudor (Arts. 1547 inc. 2º, 1672 inc. 2º y 1590 CC).

3) El riesgo de la especie o cuerpo cierto debido pasa al deudor (Art. 1550 CC).

- **Mora del acreedor.**

Se refieren a ella los Arts. 1548, 1552, 1599, 1680 y 1827 CC.

- **¿Desde cuándo está en mora el acreedor?**

1. Según algunos, desde que el deudor haya debido recurrir al pago por consignación.

2. Según otros, desde que es reconvenido judicialmente (analogía Art. 1551 N° 3 CC).

3. Doctrina más aceptada: basta cualquier ofrecimiento del deudor, incluso extrajudicial (Art. 1680 CC).

- **Efectos de la mora del acreedor.**

1. Disminuye la responsabilidad del deudor: sólo responderá de dolo o culpa grave en la conservación de la cosa (Art. 1680 y 1827 CC), y queda liberado de perjuicios moratorios.
2. El acreedor debe indemnizar los perjuicios que se sigan de no recibir la cosa (Art. 1827 CC).
3. Si el deudor tuvo que pagar por consignación, el acreedor debe pagar las expensas (Art. 1604 CC).

4.7 DE LA AVALUACIÓN DE LOS PERJUICIOS.

Hay 3 formas de evaluación:

1. Judicial: es lo normal.
2. Legal: sólo procede respecto de las obligaciones de dinero.
3. Convencional: cláusula penal.

4.7.1 AVALUACIÓN JUDICIAL DE LOS PERJUICIOS.

Es la que hace el juez. Debe pronunciarse sobre 3 cuestiones:

- 1) Determinar si procede el pago de la indemnización** (requisitos generales).
- 2) Determinar los perjuicios que deben indemnizarse.**
- 3) Fijar el monto.**

Perjuicios que deben indemnizarse.

4.7.1.1 DAÑO MORAL.³²

En un principio se aceptaba su indemnización sólo en materia extracontractual, basada en la regla del Art. 2329 CC ("todo daño")³³. Hasta 1950, la jurisprudencia era hostil a la indemnización de perjuicios en sede contractual, pero a partir de esta década se inició un período de vacilaciones, que condujo a la jurisprudencia a aceptar esta indemnización en algunos tipos de contratos³⁴.

Razones para no indemnizar el daño moral en materia contractual:

³² Material complementado en base a: JANA, Andrés y TAPIA, Mauricio: "*Daño moral en a responsabilidad contractual a propósito de un fallo de la corte suprema de 5 de noviembre de 2001*"

³³ El Código Civil no regula la reparación del daño moral. De hecho, la única norma que se pronuncia sobre este daño excluye su reparación (art. 2331). La inclusión de la indemnización del daño moral en sede extracontractual fue un desarrollo jurisprudencial en base a la norma del art. 2329 CC.

³⁴ Por ejemplo, en los contratos de transporte, la jurisprudencia se percató de la injusticia que significaba negar la indemnización del daño moral a la víctima pasajera y concedérsela a un tercero transeúnte, en caso de un accidente.

1. Falta una norma como la del Art. 2329 CC.
2. El Art. 1556 CC establece que la indemnización comprende el daño emergente y el lucro cesante, conceptos de contenido patrimonial.
3. Es difícil su prueba y evaluación.

Ninguno de los argumentos es categórico:

1. Si falta la norma, hay una laguna legal que el juez debe llenar de acuerdo a los principios generales del derecho y la equidad natural (Art. 24 CC).
2. El Art. 1556 CC no lo prohíbe: de hecho, al momento de la redacción del Código Civil la doctrina conocía únicamente el daño patrimonial, por ello, no puede sostenerse que la intención del legislador haya sido excluir la reparación de los perjuicios morales.
3. En materia extracontractual existe la misma dificultad.

Frente al Art. 19 N° 1 y 4 CPR, no es sostenible seguir negando la indemnización del daño moral. Esta utilización de las normas constitucionales se denomina usualmente *efecto horizontal de los derechos fundamentales*. La compensación económica concedida a la víctima de los daños morales es una forma de garantizar la efectiva protección de dichos intereses extrapatrimoniales.

El daño moral debe indemnizarse en la responsabilidad contractual, pero no puede cualquier incumplimiento ser fuente de daño moral. Es necesario que se haya turbado seriamente la moral, el honor, la libertad o los afectos del acreedor.

Parte de la doctrina ha sostenido que el límite de la indemnización del daño moral en materia contractual y, por tanto, el criterio práctico de la jurisprudencia para determinar si procede o no conceder la indemnización, es la previsibilidad del perjuicio (Art. 1558 CC). Para saber si el daño moral era o no previsible, habrá que determinar si en el contrato particular de que se trata el deudor aparece encargado del riesgo por el cual se produce el daño. Es decir, si dicho perjuicio forma parte o no de las expectativas que razonablemente cabía que se formasen las partes al momento de celebrar el contrato.³⁵

4.7.1.2. DAÑO PATRIMONIAL:

1. Daño emergente y lucro cesante.

Art. 1556 CC. "La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento. Exceptúanse los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente."

Daño emergente: empobrecimiento real y efectivo que sufre el patrimonio del acreedor.

³⁵ Se han señalado como ejemplos de contratos e los que se puede prever la ocurrencia de perjuicios morales, e contrato de trabajo, de transporte de personas y el contrato medico.

Lucro cesante: utilidad que deja de percibir el acreedor por el incumplimiento o cumplimiento tardío de la obligación.

Ejemplos de casos en que la ley limita la indemnización al daño emergente: Arts. 1930 inc. final, 1932, 1933 CC y Arts. 209 y 210 CCom.

2. Perjuicios previstos e imprevistos³⁶.

Previstos: los que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato.

Imprevistos: no cumplen con estos requisitos.

Se indemnizan sólo los previstos, salvo en los casos de dolo, culpa grave o acuerdo expreso de las partes (Art. 1558 CC).

Parte de la doctrina ha señalado que la previsibilidad es un criterio que se valora en abstracto, comparando la conducta efectiva del deudor con el modelo del contratante diligente.

Lo previsible debe ser la causa y no el monto de los perjuicios.

Las partes pueden alterar las reglas sobre los perjuicios a indemnizar.

Art. 1558 inc. final CC. "Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas."

4.7.2. AVALUACIÓN LEGAL DE LOS PERJUICIOS.

Art. 1559 CC. "Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:..."

¿Por qué solo la moratoria? Porque la compensatoria viene a ser el cumplimiento en especie, por tratarse de una obligación de dinero.

Características de la liquidación legal.

1. El Art. 1559 CC es una disposición supletoria y excepcional.
2. Cuando sólo se cobran intereses, los perjuicios se presumen.
3. Esto se explica porque los intereses representan el perjuicio que el acreedor experimenta si no se le paga con oportunidad el dinero.
4. El acreedor puede probar otros perjuicios, pero debe probarlos.

³⁶ Pothier introduce en Francia la regla de la previsibilidad basado en razones de justicia y eficiencia. En este sentido, no es razonable pretender que el deudor haya tenido el propósito de responder sino de aquellos perjuicios que pudo suponer como consecuencias probables de su incumplimiento, pues nadie se obliga, salvo acuerdo expreso, a lo que no pudo prever.

- **Regla primera del artículo 1559.**

"1.a Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos."

- Si las partes pactaron intereses convencionales superiores al interés legal: se siguen debiendo los convencionales.
- Si las partes no han pactado intereses, o han pactado intereses inferiores al legal: se empiezan a generar los intereses legales.
- Si hay una disposición que autorice el cobro de intereses corrientes: no rigen las reglas anteriores.

- **Regla segunda del artículo 1559.**

"2.a El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando sólo cobra intereses; basta el hecho del retardo."

- **Regla tercera del artículo 1559.**

"3.a Los intereses atrasados no producen interés." No acepta el anatocismo.

- **Regla cuarta del artículo 1559.**

"4.a La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas."

4.7.3 AVALUACIÓN CONVENCIONAL (CLÁUSULA PENAL).

2 formas de tratar la cláusula penal:

- A) Como una clase especial de obligaciones (obligaciones con cláusula penal).
- B) Como una manera de avaluar los perjuicios.

- **Concepto.**

Art. 1535 CC. "La *cláusula penal* es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena, que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o de retardar la obligación principal."

Críticas que se le han hecho a la definición:

- 1) La denominación "cláusula" es correcta sólo si se pacta conjuntamente con el contrato principal, no si se pacta después.
- 2) No asegura ni garantiza nada. Sólo produce ventajas para el acreedor en caso de incumplimiento.

- 3) Omite obligaciones de no hacer.
- 4) "Pena" tiene una connotación ajena al derecho civil.

- **Funciones que cumple la cláusula penal.**

1. La cláusula penal constituye una forma de avaluar perjuicios.

Como tal, presenta 2 características:

- 1) Convencional: proviene del acuerdo de las partes. No es cláusula penal si la pena se establece unilateralmente. No puede establecerla la ley o el juez.
- 2) Anticipada: el monto de los perjuicios queda irrevocablemente fijado antes del incumplimiento. Producido éste, el deudor no puede discutir ni la existencia ni el monto de estos perjuicios (Art. 1542 CC).

- **La cláusula penal puede ser compensatoria o moratoria.**

Se desprende de la definición: "en caso de no ejecutar (compensatoria) o de retardar (moratoria) la obligación principal".

- **Diferencias de la cláusula penal con la indemnización de perjuicios ordinaria.**

1. Oportunidad en que se fija (antes/después del incumplimiento).

2. Reparación en dinero. En la cláusula penal, los perjuicios no se reparan necesariamente en dinero, como ocurre en la ordinaria.

3. Prueba de los perjuicios. En la cláusula penal, no es necesario probar los perjuicios.

2. Constituye una caución.

Tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal (Art. 1535 CC en relación al Art. 46 CC, y Art. 1472 CC).

Pero debe considerarse que por sí sola no asegura el cumplimiento de la obligación; sólo sirve de estímulo para que el deudor cumpla.

Su condición de caución se robustece cuando se constituye para garantizar una obligación ajena.

Es una caución personal.

3. La cláusula penal constituye una pena civil.

Así está dicho en la definición, y con ese carácter nació.

- **Paralelo de la cláusula penal con otras instituciones.**

1. Con la fianza:

a) A qué se obliga:

- El fiador sólo se obliga a pagar una suma de dinero;
- la cláusula penal puede consistir en dar, hacer o no hacer.

b) Obligación en términos más gravosos:

- El fiador no puede obligarse en términos más gravosos que el deudor principal (Art. 2344 CC),
- Limitación que no existe en la cláusula penal.

2. Con las arras:

- Qué garantizan:
 - Las arras garantizan la celebración de un contrato:
 - la cláusula penal, el cumplimiento de una obligación.
- Cuándo hay entrega:
 - En las arras hay una entrega actual de dinero u otra cosa;
 - en la cláusula penal, la entrega sólo va a ocurrir cuando se produzca el incumplimiento.

• **Características.**

1. Consensual.

No se exige ninguna formalidad especial. La voluntad puede ser expresa o tácita.

2. Condicional.

El derecho del acreedor a cobrarla está sujeto al hecho futuro e incierto de que se produzca el incumplimiento del deudor, y que éste se encuentre en mora.

3. Accesorio.

1. Extinguida la obligación principal, por cualquier medio, se extingue la cláusula penal.
2. La acción para exigir el pago de la pena prescribe conjuntamente con la obligación principal (Art. 2516 CC).
3. La nulidad de la obligación principal trae la nulidad de la pena (Art. 1536 inc. 1º CC).

• **Cláusula penal en la promesa de hecho ajeno.**

Art. 1536 inc. 2º CC. "Con todo, cuando uno promete por otra persona, imponiéndose una pena para el caso de no cumplirse por ésta lo prometido, valdrá la pena, aunque la obligación principal no tenga efecto por falta del consentimiento de dicha persona."

Esto no es una excepción al inc. 1º, porque lo que garantiza la cláusula penal es la obligación que asumió el promitente de que el tercero acepte la obligación que se contrajo para él.

• **Cláusula penal en la estipulación en favor de otro.**

Art. 1536 inc. final CC. "Lo mismo sucederá cuando uno estipula con otro a favor de un tercero, y la persona con quien se estipula se sujeta a una pena para el caso de no cumplir lo prometido."

Tampoco es una excepción. Como el estipulante no puede exigir al promitente el cumplimiento, sino sólo el beneficiario, la cláusula es la forma que tiene para compelerlo a cumplir. No hay nulidad de la obligación principal, sino que el promitente contrae 2 obligaciones: una con el beneficiario y otra con el otro estipulante.

4. La cláusula penal puede garantizar una obligación civil o natural.

Así lo permite el Art. 1472 CC.

- **Extinción de la cláusula penal.**

1. Por vía principal: cuando se extingue no obstante mantenerse vigente la obligación principal.

2. Por vía accesoria: cuando desaparece como consecuencia de haberse extinguido la obligación principal.

- **Efectos de la cláusula penal.**

El efecto propio es dar al acreedor el derecho de cobrarla cuando no se cumple la obligación principal.

- **Requisitos para que el acreedor pueda cobrar la pena.**

1. Incumplimiento de la obligación principal.
2. Incumplimiento imputable al deudor.
3. Mora del deudor.

- **La pena y el caso fortuito.**

Si hay caso fortuito, la obligación principal se extingue por el modo de extinguir pérdida de la cosa debida o imposibilidad de la ejecución. Extinguida la obligación principal, se extingue la cláusula penal por vía de consecuencia.

- **La pena y la interpelación voluntaria.**

Para hacer efectiva la cláusula penal, el deudor debe estar constituido en mora:

- Algunos dicen que existiendo cláusula penal, no operaría respecto de la obligación principal, la interpelación voluntaria expresa del Art. 1551 N° 1 CC, en base a la frase inicial del Art. 1538 CC ("háysese o no estipulado un término"). Siempre sería necesaria la interpelación judicial.
- La mayoría de la doctrina estima que el deudor puede quedar constituido en mora por cualquiera de las formas del Art. 1551 CC.

- **Efectos de la cláusula penal cuando el incumplimiento es parcial.**

Art. 1539 CC. "Si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esa parte, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por la falta de cumplimiento de la obligación principal."

- **Cobro de la obligación principal, de la indemnización ordinaria y de la pena.**

1. Antes de constituirse el deudor en mora: el acreedor puede demandar la obligación principal (Art. 1537 CC).

2. Constituido el deudor en mora: el acreedor puede optar entre pedir el cumplimiento de la obligación principal o la pena, no ambas (Art. 1537 CC).

3. Se pueden acumular cumplimiento y pena cuando aparezca haberse convenido la pena por el simple retardo, o cuando se hubiere estipulado que por el pago de la pena no se entiende extinguida la obligación principal (Art. 1537 CC).

4. De acuerdo al Art. 1543 CC, puede optarse por la pena o la indemnización de perjuicios ordinaria, pero no ambas, a menos que así se haya convenido expresamente.

- **Cobro de la cláusula penal cuando la obligación principal es de cosa divisible y hay pluralidad de acreedores o de deudores.**

Art. 1540 inc. 1º CC. "Cuando la obligación contraída con cláusula penal es de cosa divisible, la pena, del mismo modo que la obligación principal, se divide entre los herederos del deudor a prorrata de sus cuotas hereditarias. El heredero que contraviene a la obligación, incurre pues en aquella parte de la pena que corresponde a su cuota hereditaria; y el acreedor no tendrá acción alguna contra los coherederos que no han contravenido a la obligación."

- **Cobro de la cláusula penal cuando la obligación principal es de cosa indivisible o cuando se ha puesto la cláusula penal con la intención expresa de que el pago no pueda fraccionarse.**

Art. 1540 incs. 2º y final CC. "Exceptúase el caso en que habiéndose puesto la cláusula penal con la intención expresa de que no pudiera ejecutarse parcialmente el pago, uno de los herederos ha impedido el pago total: podrá entonces exigirse a este heredero toda la pena, o a cada uno su respectiva cuota, quedándole a salvo su recurso contra el heredero infractor.

Lo mismo se observará cuando la obligación contraída con cláusula penal es de cosa indivisible."

- **Situación en el caso de que la pena sea indivisible.**

Se puede reclamar a cualquiera de los deudores, sin importar quien sea el infractor.

- **Situación en el caso de que la obligación principal sea solidaria.**

Se entiende que la pena también puede cobrarse solidariamente, por su carácter accesorio. Se critica a esta tesis porque la indemnización es conjunta aun entre deudores solidarios. Además, la solidaridad requiere texto expreso.

- **Cláusula penal garantizada con hipoteca.**

Art. 1541 CC. "Si a la pena estuviere afecto hipotecariamente un inmueble, podrá perseguirse toda la pena en él, salvo el recurso de indemnización contra quien hubiere lugar."

- **Cobro de la cláusula penal cuando hay pluralidad de acreedores.**

De acuerdo a las reglas generales, cada acreedor sólo puede demandar su cuota en la pena, salvo que la pena sea de cosa indivisible o haya solidaridad activa.

Cláusula penal enorme.

1. Cláusula penal en los contratos conmutativos:

Art. 1544 inc. 1º CC. "Cuando por el pacto principal una de las partes se obligó a pagar una cantidad determinada, como equivalente a lo que por la otra parte debe prestarse, y la pena consiste asimismo en el pago de una cantidad determinada, podrá pedirse que se rebaje de la segunda todo lo que exceda al duplo de la primera, incluyéndose ésta en él."

La parte de la norma que hemos subrayado, que contiene el elemento clave de la determinación de la cláusula penal enorme, resulta confusa. Al respecto, se han propuesto dos interpretaciones doctrinarias:

i) La cláusula penal será enorme si es que excede del doble de la obligación principal. Ejemplo: si la obligación principal es de 100, la pena no puede ser más de 200 (el doble de la obligación principal).

ii) La cláusula penal será enorme si es que excede del triple de la obligación principal, pues la norma hace alusión a la cantidad en que la cláusula exceda al doble de la obligación principal, incluyendo la obligación principal en dicho monto.

Ejemplo: si la obligación principal es de 100, la pena no puede ser más de 300 (el doble de la obligación principal, incluyendo a la obligación principal).

2. Cláusula penal en el mutuo:

Art. 1544 incs. 2º y 3º CC. "La disposición anterior no se aplica al mutuo ni a las obligaciones de valor inapreciable o indeterminado. En el primero se podrá rebajar la pena en lo que exceda al máximo del interés que es permitido estipular."

Esto se referiría sólo al mutuo que no sea de dinero, porque en el de dinero, de acuerdo con el Art. 8º Ley 18.010, los intereses se rebajan al interés corriente.

3. Cláusula penal en las obligaciones de valor inapreciable o indeterminado:

Art. 1544 inc. final CC. "En las segundas se deja a la prudencia del juez moderarla, cuando atendidas las circunstancias pareciere enorme."

4.8 EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO

La excepción de contrato no cumplido es un mecanismo de tutela que el derecho civil le otorga a las partes obligadas en el contexto de un contrato bilateral, entregando al contratante diligente una excepción a la demanda de resolución, de cumplimiento o indemnización de perjuicios.

La doctrina contemporánea no comprende a esta institución únicamente como una excepción en su sentido procesal estricto, sino también como un remedio extrajudicial toda vez que permite al contratante diligente suspender la ejecución de la prestación a la que está obligado mientras su cocontratante no cumpla con su obligación. Este carácter de remedio se observa claramente en los instrumentos de derecho uniforme:

Art. 71 CISG:

"1) Cualquiera de las partes podrá diferir el cumplimiento de sus obligaciones si, después de la celebración del contrato, resulta manifiesto que la otra parte no cumplirá una parte sustancial de sus obligaciones a causa de:
a) un grave menoscabo de su capacidad para cumplirlas o de su solvencia, o
b) su comportamiento al disponerse a cumplir o al cumplir el contrato."

Art. 7.1.3 Principios UNIDROIT:

"(1) Cuando las partes han de cumplir simultáneamente, cada parte puede suspender el cumplimiento de su prestación hasta que la otra ofrezca su prestación.
(2) Cuando las partes han de cumplir de modo sucesivo, la parte que ha de cumplir después puede suspender su cumplimiento hasta que la parte que ha de hacerlo primero haya cumplido."

Art. 102 Principios Latinoamericanos del Derecho de Contratos:

"Suspensión del cumplimiento
Cada parte puede negarse a ejecutar el contrato si la otra no lo ejecuta, a menos que por su naturaleza o por acuerdo de las partes el cumplimiento de una deba anteceder al de la otra."

4.9 DERECHOS AUXILIARES DEL ACREEDOR

1. Concepto.

Son ciertas acciones o medios concedidos por la ley al acreedor destinados a mantener la integridad del patrimonio del deudor.

2. Enumeración.

1. Medidas conservativas.
2. El derecho legal de retención.
3. La acción oblicua, indirecta o subrogatoria.
4. La acción pauliana o revocatoria.
5. El beneficio de separación.

3. Objetivos.

- Impedir que el patrimonio del deudor disminuya de modo que se torne insuficiente para responder de las obligaciones contraídas.
- Que el patrimonio del deudor se incremente, para asegurar el pago de sus créditos; ya sea por ingreso de nuevos bienes, ya por el reintegro de los que el deudor hizo salir en fraude y con perjuicios de sus acreedores.

4.9.1 DE LAS MEDIDAS CONSERVATIVAS.

1. Concepto.

Son aquellas que tienen por objeto mantener intacto el patrimonio del deudor, evitando que los bienes que lo forman se pierdan, deterioren o enajenen, a fin de hacer posible el cumplimiento de la obligación.

2. Ejemplos.

- Medidas precautorias del Art. 290 y ss. CPC,
- la guarda y aposición de sellos (Art. 1222 y ss. CC),
- la confección de inventario solemne.

4.9.2 EL DERECHO LEGAL DE RETENCIÓN

1. Concepto.

Es la facultad que tienen ciertas personas para retener cosas que legalmente están

obligados a restituir, mientras el acreedor restitutorio les adeude indemnizaciones o pagos establecidos por ley. Así, una persona que en estricto rigor carece de derechos sobre ciertos bienes puede mantener la tenencia de ellos, por el tiempo que una determinada obligación a su favor no haya sido satisfecha.

2. Efectos.

Su efecto está regulado en el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil: *“los bienes retenidos por resolución ejecutoriada serán considerados, según su naturaleza, como hipotecados o constituidos en prenda para los efectos de la realización y de la preferencia a favor de los créditos que garantizan”*. El ejercicio del derecho se asemeja a la prenda o hipoteca según sea la naturaleza de la cosa, con la salvedad que no se otorga derecho de persecución.

El derecho legal de retención siempre requiere de declaración judicial y sólo se otorga en los casos establecidos expresamente por la ley

Faculta a quien está obligado a entregar una cosa, para retenerla, con el fin de asegurarle un derecho que según la ley le corresponde.

3. Ejemplos.

- Art. 1937 (arrendatario),
- Art 2162 (mandatario),
- Art 2193 (comodatario) y
- Art 2234 CC (depositario).

Constituye una verdadera medida precautoria, que debe ser declarada judicialmente (Art. 545 CPC).

4.9.3. ACCIÓN OBLICUA O SUBROGATORIA.

1. Concepto.

Consiste el ejercicio de los derechos y acciones del deudor por parte de sus acreedores, cuando el primero es negligente en hacerlo.

2. Objetivo.

El objeto es que estas acciones o derechos ingresen al patrimonio del deudor, mejorando el derecho de prenda general.

3. Consagración.

Estas acciones no son acciones directas que emanen del contrato, sino que las otorga la ley. Pero en Chile no existe una disposición que en forma general las conceda.

4. Requisitos de la acción oblicua.

1) En relación al acreedor. Sólo debe tener interés, lo que ocurrirá cuando la negligencia del deudor en ejercitar el derecho o acción comprometa su solvencia.

2) En relación al crédito. Tiene que ser cierto y actualmente exigible.

3) En relación al deudor. Debe ser negligente en el ejercicio de sus derechos y acciones. El acreedor es quien debe probar esto, pero no necesariamente debe constituirlo en mora.

4) En relación a los derechos y acciones. Tienen que ser patrimoniales, referirse a bienes embargables, y en ningún caso opera respecto de derechos personalísimos.

5. Efectos de la subrogación.

Son consecuencia de que el acreedor actúa por cuenta y a nombre del deudor:

1) El tercero demandado puede oponer al acreedor las mismas excepciones que podía oponer a su acreedor (el deudor).

2) La sentencia que se pronuncie en este juicio produce cosa juzgada respecto del deudor.

3) No se requiere de una resolución previa que autorice la subrogación. Esta calificación se hace en el mismo juicio en que se hace efectiva la acción.

4) Los bienes ingresan al patrimonio del deudor, beneficiándose con ello no sólo el subrogante, sino todos los acreedores.

6. Procedencia de la acción oblicua en Chile.

1. Para algunos, solo cabe para los casos en que la ley expresamente lo autoriza (se requiere texto legal expreso que la permita).

2. Para otros, opera en forma general, en base a los Arts. 2465 y 2466 CC.

7. Casos en que se autorizaría expresamente la acción oblicua.

1. Los acreedores pueden subrogarse en los derechos reales de usufructo, prenda y de retención, pertenecientes al deudor.

Art. 2466 inc. 1º CC. "Sobre las especies identificables que pertenezcan a otras personas por razón de dominio, y existan en poder del deudor insolvente, conservarán sus derechos los respectivos dueños, sin perjuicio de los derechos reales que sobre ellos competan al deudor, como usufructuario o prendario, o del derecho de retención que le concedan las leyes; en todos los cuales podrán subrogarse los acreedores."

2. Los acreedores pueden subrogarse en los derechos del deudor como arrendador o arrendatario.

Art. 2466 inc. 2º CC. "Podrán asimismo subrogarse en los derechos del deudor como arrendador o arrendatario, según lo dispuesto en los artículos 1965 y 1968."

3. Los acreedores, en caso de extinción de la obligación por pérdida de la cosa debida, podrán exigir que se les cedan los derechos y acciones que el deudor tenga en contra de terceros por cuyo hecho o culpa hayan perecido la cosa.

Art. 1677 CC. "Aunque por haber perecido la cosa se extinga la obligación del deudor, podrá exigir el acreedor que se le cedan los derechos o acciones que tenga el deudor contra aquellos por cuyo hecho o culpa haya perecido la cosa."

4. Los acreedores del que repudia una asignación en perjuicio de sus derechos, podrán hacerse autorizar por el juez, para aceptar por el deudor.

Art. 1238 CC. "Los acreedores del que repudia en perjuicio de los derechos de ellos, podrán hacerse autorizar por el juez para aceptar por el deudor. En este caso la repudiación no se rescinde sino en favor de los acreedores y hasta concurrencia de sus créditos; y en el sobrante subsiste."

No obstante, en este último caso, parece discutible que efectivamente sea una acción subrogatoria.

4.9.4 ACCIÓN PAULIANA.

1. Concepto.

Es la que la ley otorga a los acreedores para dejar sin efecto los actos del deudor ejecutados fraudulentamente y en perjuicio de sus derechos y siempre que concurren los demás requisitos legales.

2. Requisitos de la acción pauliana.

1) El acto ejecutado de mala fe. Puede intentarse para dejar sin efecto cualquier acto o contrato voluntario del deudor. Los términos del Art. 2468 CC son bastante amplios. No obstante proceder respecto de actos gratuitos y onerosos, los requisitos que se exigen en uno y otro caso son distintos:

- 1) Oneroso: es necesario probar la mala fe del deudor y la mala fe del adquirente, esto es, que ambos conocían el mal estado de los negocios del deudor.
- 2) Gratuito: basta probar la mala fe del deudor.

Sobre este punto, es necesario enfatizar que la mala fe pauliana no consiste en un ánimo fraudulento en términos subjetivos, ni en una intención de causarle daño a los acreedores. La mala fe pauliana consiste única y exclusivamente en el conocimiento, por parte de una o ambas partes según el

carácter del acto, del mal estado de los negocios del deudor.

El punto anterior, además, resulta ilustrativo respecto al fundamento de la acción pauliana. Dado que la acción pauliana no está establecida exclusivamente para los acreedores de obligaciones que emanen de relaciones contractuales, no es correcto decir que su fundamento radica en los deberes recíprocos que la buena fe objetiva les impone a los contratantes. Más bien, su fundamento es la protección general del crédito que el legislador le ofrece a los acreedores.

2) El deudor. No es necesario que el deudor esté en situación de procedimiento concursal de reorganización o renegociación. Lo que exige el Art. 2468 CC es que esté de mala fe. Esta "mala fe pauliana" consiste en que realice el acto conociendo el mal estado de sus negocios.

3) El acreedor. Debe tener interés, que ocurrirá cuando se reúnan los siguientes requisitos:

- i. que el deudor sea insolvente o que con el acto haga aumentar su insolvencia.
- ii. que su crédito sea anterior al acto que produce la insolvencia.

4) El tercero adquirente.

- Si el acto es gratuito, no se requiere nada (Art. 2468 N° 2 CC);
- si es oneroso, se requiere la mala fe del tercero adquirente (Art. 2468 N° 1 CC).

3. Situación del subadquirente.

- 1) Algunos estiman que debe aplicarse las mismas reglas que a los adquirentes.
- 2) Otros estiman que es una acción de nulidad relativa, por lo que produce efectos respecto de terceros in importar su buena o mala fe.

4. Características de la acción pauliana.

1. Es una acción directa del acreedor, que ejerce a su propio nombre y no por cuenta del deudor.
2. Es una acción personal.
3. Es una acción patrimonial: renunciable, transferible, transmisible y prescriptible. El plazo de prescripción es de 1 año, contado desde la fecha del acto (Art. 2468 N° 3 CC).

5. Efectos de la acción pauliana.

El efecto propio es dejar sin efecto el acto o contrato impugnado, hasta el monto del crédito del acreedor que intenta la acción. El deudor puede enervar la acción pagando al acreedor.

La revocación sólo afecta a las partes que litigaron, por el efecto relativo de la sentencia, consagrado en el art. 3 CC. Por esa razón, si uno de varios co-acreedores intenta la acción pauliana para revocar un acto fraudulento, solo él se aprovechará del resultado de la acción.

6. Naturaleza jurídica de la acción pauliana.

Se ha discutido. La legislación no es del todo clara en cuanto a sus efectos ni en cuanto a su naturaleza jurídica. Al respecto, podemos identificar las siguientes posiciones doctrinales:

- 1) Es una acción de nulidad relativa, porque el Art. 2468 CC dice "rescindibles". Se le critica que el acto que se pretende dejar sin efecto es un acto válido.
- 2) Es una típica acción de inoponibilidad por fraude. Un argumento en favor de esta posición es que los créditos se revocan hasta el monto del crédito del acreedor, lo cual solo se explica si le asignamos a esta acción la naturaleza de acción de inoponibilidad.
- 3) Es una acción indemnizatoria por un hecho ilícito. La reparación tomaría la forma especial de dejar sin efecto el acto impugnado.

7. Consagración legal de la acción pauliana.

Art. 2468 CC. En cuanto a los actos ejecutados antes de la cesión de bienes o la apertura del concurso, se observarán las disposiciones siguientes:

- 1 Los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos onerosos, y las hipotecas, prendas y anticresis que el deudor haya otorgado en perjuicio de ellos, estando de mala fe el otorgante y el adquirente, esto es, conociendo ambos el mal estado de los negocios del primero.
2. Los actos y contratos no comprendidos bajo el número precedente, incluso las remisiones y pactos de liberación a título gratuito, serán rescindibles, probándose la mala fe del deudor y el perjuicio de los acreedores.
3. Las acciones concedidas en este artículo a los acreedores expiran en un año contado desde la fecha del acto o contrato.

4.9.5 BENEFICIO DE SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS.

Concepto.

Tiene por objeto evitar que se confundan los bienes del causante con los bienes del heredero, para que, de esa forma, puedan pagarse en los primeros, los acreedores hereditarios y testamentarios, con preferencia a los acreedores propios del heredero.

CAPÍTULO 5. DE LOS MODOS DE EXTINGUIR LAS OBLIGACIONES.

5.1 CONCEPTO.

Modos de extinguir las obligaciones: todo hecho o acto al que la ley atribuye el valor de hacer cesar los efectos de la obligación.

5.2 CAUSALES DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES.

El Art. 1567 CC hace una enumeración. Contiene 10 numerandos, pero en el inciso primero agrega un modo: la resciliación o mutuo disenso.

Art. 1567 CC. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula.

Las obligaciones se extinguen además en todo o parte:

1. Por la solución o pago efectivo;
2. Por la novación;
3. Por la transacción;
4. Por la remisión;
5. Por la compensación;
6. Por la confusión;
7. Por la pérdida de la cosa que se debe;
8. Por la declaración de nulidad o por la rescisión;
9. Por el evento de la condición resolutoria;
10. Por la prescripción.

De la transacción y la prescripción se tratará al fin de este Libro; de la condición resolutoria se ha tratado en el título De las obligaciones condicionales.

La enumeración no es taxativa; no contempla:

- 1) Término extintivo (ciertos contratos: arrendamiento, sociedad, mandato, etc.)
- 2) Dación en pago.
- 3) Imposibilidad absoluta de cumplir la obligación de hacer.
- 4) Voluntad de las partes (desahucio en el arrendamiento, revocación y renuncia en el mandato).
- 5) Muerte del deudor en las obligaciones intransmisibles y contratos intuitu personae.
- 6) Resolución judicial de término del procedimiento de liquidación, salvo que disponga lo contrario (art. 255 ley 20.720, nueva ley de quiebras).
- 7) Etc.

5.3 CLASIFICACIÓN DE LOS MODOS DE EXTINGUIR LAS OBLIGACIONES.

A. En cuanto a su perfección:

- a. Pago (más perfecto)
- b. Demás modos de extinguir las obligaciones

B. En cuanto a la satisfacción que obtiene el acreedor:

- a. Aquellos que satisfacen el crédito
- b. Aquellos que no satisfacen la acreencia
- c. Aquellos que atacan el vínculo obligacional mismo

C. En cuanto a las obligaciones respecto de las que pueden operar:

- a. Modos comunes (respecto de cualquier obligación)
- b. Modos particulares

D. En cuanto a la voluntad del sujeto:

- a. Modos voluntarios
- b. Modos no voluntarios

E. En cuanto a su extensión:

- a. Totales
- b. Parciales

F. En cuanto a su naturaleza jurídica:

- a. Hechos
- b. Actos jurídicos

5.4 LA RESCILIACIÓN O MUTUO DISENDO.

Art. 1567 inc. 1º CC. "Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula."

1. Concepto.

Resciliación: acuerdo de voluntades (convención) en que las partes, dotadas de capacidad de disposición, dejan sin efecto un acto anterior, extinguendo de esa manera las obligaciones pendientes provenientes de ese acto.

Aunque dice "toda obligación", sólo es aplicable a las obligaciones contractuales. Si la fuente es otra, la voluntad juega de otra manera. Ej. Remisión de la deuda, novación, etc.

2. La resciliación es una convención.

Es un acto jurídico bilateral destinado a extinguir una obligación.

3. Requisitos de validez.

Son los propios de todo acto jurídico: consentimiento, capacidad, objeto y causa.

• **Consentimiento en la resciliación.**

Las partes son las mismas que celebraron el acto que se deja sin efecto.

La jurisprudencia ha dicho que debe hacerse y perfeccionarse con las mismas solemnidades que las partes adoptaron al celebrar el contrato, refiriéndose al caso de un contrato consensual que las partes hicieron solemne (en derecho las cosas se deshacen de la misma manera como se hacen). Pero Ramos Pazos no está de acuerdo: las solemnidades son de derecho estricto, y la ley no ha establecido ninguna para la resciliación.

- **Capacidad para resciliar.**

El Art. 1567 CC exige capacidad de disposición. No basta con la simple capacidad general. Se exige porque la resciliación es para ambas partes una renuncia de los derechos provenientes del acto. Es por ello que no se pueden resciliar las obligaciones legales (no se pueden renunciar).

- **Para que haya resciliación tiene que existir una obligación pendiente.**

Si no hay obligaciones que extinguir, la resciliación no tendría objeto.

La pregunta es si las partes, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, podrían dejar sin efecto un contrato ya cumplido:

1) En este caso no debe hablarse de resciliación. Las partes, para dejar sin efecto el contrato, tendrían que celebrar un nuevo contrato igual al primero, pero en sentido contrario.

2) Hay un autor que plantea que lo que se rescilia no son las obligaciones que ya están extinguidas, sino el contrato (su causa eficiente). Al invalidarse el contrato por el consentimiento mutuo, se invalidarían las obligaciones. Por la resciliación, las partes no se obligan a realizar las prestaciones del contrato en sentido contrario, sino a realizar las prestaciones mutuas según las reglas de la nulidad.

4. La resciliación sólo opera en los contratos patrimoniales.

No cabe en el derecho de familia, por cuanto no cabe allí la renuncia de derechos.

5. Efectos de la resciliación.

El Art. 1567 CC incurre en un error al decir que las partes consienten en dar por nula la obligación, pues el acto no nació viciado: no cabe hablar de nulidad. La disposición se refiere a que las partes acuerdan dejar sin efecto el acto.

Se dice que la resciliación no opera retroactivamente, sino hacia el futuro, para proteger a los terceros que pudieran haber celebrado algún contrato sobre la cosa objeto del contrato resciliado. Esto no es tan cierto: entre las partes, la resciliación puede tener los efectos que ellas quieran.

a) Efectos de la resciliación entre las partes.

Produce los efectos que las partes quieran atribuirle (autonomía de la voluntad). Si quieren, pueden darle efecto retroactivo.

b) Efectos de la resciliación respecto de terceros.

- 1) Terceros que adquieren sus derechos sobre la cosa objeto del contrato antes de la resciliación: la resciliación les es inoponible.
- 2) Terceros que adquieren sus derechos sobre la cosa después de la resciliación: deben respetar la resciliación.

5.5 LA SOLUCIÓN O PAGO EFECTIVO.

Art. 1568 CC. "El pago efectivo es la prestación de lo que se debe."

1. Solución o pago efectivo.

Es el modo de extinguir más importante (Art. 1567 N° 1 CC).

- 1) El pago es un modo de extinguir cualquier obligación, no sólo aquellas de pagar una suma de dinero.
- 2) Todo pago supone una obligación preexistente, civil o a lo menos natural. Si por error se paga una obligación inexistente, hay derecho a repetir.

El pago, más que un modo de extinguir una obligación, es la forma natural de cumplirla.

2. El pago es la prestación de lo que se debe.

No hay pago si por acuerdo de las partes la obligación se satisface con una cosa distinta de lo debido (dación en pago).

3. Naturaleza jurídica del pago.

- Es una convención extintiva.
- Debe cumplir los requisitos generales de todo acto jurídico.
- Cuando la obligación es de dar, se paga haciendo la tradición. Por eso se dice que la tradición es un pago.

4. El pago es un acto jurídico intuitu personae.

Si por error se hace a una persona distinta del acreedor, no extingue la obligación. Quien paga mal, paga dos veces, sin perjuicio del derecho a repetir (Art. 2295 CC).

5. Características del pago.

1) El pago debe ser específico.

Art. 1569 CC. "El pago se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en casos especiales dispongan las leyes. El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba ni aun a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida."

2) El pago debe ser completo.

Debe comprender íntegramente lo debido, incluidos los accesorios:

Art. 1591 inc. 2º CC. "El pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban."

Por regla general, los gastos del pago son del deudor (Art. 1571 CC).

3) El pago es indivisible.

Art. 1591 inc. 1º CC. "El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria; y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales."

Se puede dividir el pago:

- 1) Si así lo acuerdan las partes.
- 2) En las obligaciones simplemente conjuntas.
- 3) En las deudas hereditarias.
- 4) Cuando existen varios fiadores (beneficio de división).
- 5) Cuando existe controversia sobre la cantidad de la deuda, o sobre sus accesorios: el juez puede ordenar mientras tanto el pago de la cantidad no disputada (Art. 1592 CC).
- 6) En la compensación.
- 7) Cuando el deudor está en quiebra y sus bienes no alcanzan para cubrir los pasivos: el síndico hará pagos parciales a los acreedores a prorrata de sus créditos.

6. Por quién debe hacerse el pago.

1) Pago hecho por el deudor.

Dentro de este caso están comprendidos:

1. Pago hecho por el representante legal del deudor.
2. Pago hecho por un mandatario del deudor.
3. Pago hecho por un heredero del deudor.

Si el deudor paga, se extingue la obligación sin que se genere ninguna consecuencia posterior.

2) Pago hecho por un tercero interesado.

1. Pago hecho por el **codeudor solidario**: por el hecho de pagar, se extingue la obligación respecto de él, pero se subroga en los derechos del acreedor.

2. Pago hecho por un **fiador**: también se subroga en los derechos del acreedor.

3. Pago hecho por el **tercer poseedor de la finca hipotecada**: es el poseedor del inmueble hipotecado que no está obligado personalmente al pago de la deuda. Se da en 2 casos:

a) Cuando se hipoteca un bien propio para garantizar una obligación ajena.

b) Cuando se adquiere un bien hipotecado.

Si paga, se subroga en los derechos del acreedor.

En estos casos, el pago no produce la extinción de la obligación, pues ésta subsiste entre el que hizo el pago y el deudor.

3) Pago hecho por un tercero extraño.

Art. 1572 CC. "Puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre del deudor, aun sin su conocimiento o contra su voluntad, y aun a pesar del acreedor.

Pero si la obligación es de hacer, y si para la obra de que se trata se ha tomado en consideración la aptitud o talento del deudor, no podrá ejecutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor."

Se acepta el pago por un tercero extraño porque:

a) Al acreedor le interesa que le paguen, sin importar quién lo haga.

b) A la sociedad le interesa que las deudas se paguen.

7. Efectos del pago hecho por un tercero extraño.

1) Pago hecho con el consentimiento expreso o tácito del deudor.

El que paga se subroga en los derechos del acreedor a quien paga. En el fondo es un mandatario del deudor, por lo que tiene dos acciones:

1. Acción subrogatoria del Art. 1610 N° 5 CC.

2. Acción propia del mandato.

2) Pago hecho sin el conocimiento del deudor.

Art. 1573 CC. "El que paga sin el conocimiento del deudor no tendrá acción sino para que éste le reembolse lo pagado; y no se entenderá subrogado por la ley en el lugar y derechos del acreedor, ni podrá compeler al acreedor a que le subrogue."

No hay subrogación legal, sino sólo convencional si el acreedor le subroga voluntariamente en sus derechos (Art. 1611 CC). Si no es así, el tercero sólo tendrá acción de reembolso.

3) Pago hecho contra la voluntad del deudor.

Art. 1574 CC. "El que paga contra la voluntad del deudor, no tiene derecho para que el deudor le reembolse lo pagado; a no ser que el acreedor le ceda voluntariamente su acción."

Este tercero es un agente oficioso, lo que es importante porque el Art. 2291 CC establece una regla que se contradice con el Art. 1574 CC: si el pago fue útil al deudor (extinguió la obligación), hay acción de repetición.

Formas de resolver la contradicción entre los artículos 1574 y 2291.

1. El Art. 1574 CC debe aplicarse cuando el pago no ha sido útil al deudor, y el Art. 2291 CC cuando le fue útil.
 2. El Art. 1574 CC rige para pagos aislados, que no corresponden a la administración de un negocio, y el Art. 2291 CC se debe aplicar a la agencia oficiosa, en que hay administración de un negocio.
 3. El Art. 2291 CC se aplica cuando concurren copulativamente 2 requisitos:
 - Que el pago quede comprendido dentro de la administración de un negocio.
 - Que reporte utilidad al deudor.
- Si falta uno, se aplica el Art. 1574 CC.

8. Pago en el caso de las obligaciones de dar.

La obligación del deudor es hacer la tradición. Reglas especiales:

1) El tradente debe ser titular del derecho que transfiere.

Art. 1575 inc. 1º CC. "El pago en que se debe transferir la propiedad no es válido, sino en cuanto el que paga es dueño de la cosa pagada, o la paga con el consentimiento del dueño."

La expresión "no es válido" significa que el pago es ineficaz para extinguir la obligación (no que es nulo).

2) Capacidad de disposición del que paga.

Art. 1575 inc. 2º CC. "Tampoco es válido el pago en que se debe transferir la propiedad, sino en cuanto el que paga tiene facultad de enajenar."

En este caso, la sanción es la nulidad relativa. Pero si quien pagó era incapaz absoluto, la sanción es la nulidad absoluta.

3) Formalidades legales.

Art. 679 CC. "Si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere el dominio sin ellas."

9. A quién debe hacerse el pago.

Esto es importante pues si se paga mal, el deudor no queda liberado de la obligación.

El Art. 1576 CC indica a quién debe hacerse el pago:

1) Pago hecho al acreedor.

Art. 1576 inc. 1º primera parte CC. "Para que el pago sea válido, debe hacerse o al acreedor mismo (bajo cuyo nombre se entienden todos los que le hayan sucedido en el crédito, aun a título singular),..."

Excepciones en que el acreedor no puede recibir el pago.

Art. 1578 CC. "El pago hecho al acreedor es nulo en los casos siguientes:
1.º Si el acreedor no tiene la administración de sus bienes; salvo en cuanto se probare que la cosa pagada se ha empleado en provecho del acreedor, y en cuanto este provecho se justifique con arreglo al artículo 1688;
2.º Si por el juez se ha embargado la deuda o mandado retener su pago;
3.º Si se paga al deudor insolvente en fraude de los acreedores a cuyo favor se ha abierto concurso."

1º Pago hecho al acreedor que no tiene la libre administración de sus bienes. El pago es una convención que requiere capacidad de ambas partes. La sanción será la nulidad relativa o absoluta, dependiendo del incapaz de que se trate.

Pero el pago va a ser válido si quien lo hizo prueba que fue útil al acreedor, justificándolo de acuerdo al Art. 1688 CC (probando que el acreedor se hizo más rico).

2º Pago hecho al acreedor cuyo crédito se ha embargado u ordenado retener por decreto judicial. Si el deudor paga, el pago adolece de nulidad absoluta por objeto ilícito (Art. 1464 N° 3 CC).

3º Pago hecho al acreedor declarado en quiebra. Es consecuencia de que el "**DEUDOR**" (nuevo estado que reemplaza al de "**fallido**" según la nueva ley de quiebras 20720), pierda la administración de sus bienes, que pasa al síndico, el cual puede recibir válidamente el pago. No basta la insolvencia, es necesaria la declaración judicial de quiebra.

2) Pago hecho a los representantes del acreedor.

Art. 1576 inc. 1º segunda parte CC. "...o a la persona que la ley o el juez autoricen a recibir por él, o a la persona diputada por el acreedor para el cobro."

Los representantes pueden ser:

- 1) Legales.
- 2) Judiciales.
- 3) Convencionales.

1) Pago hecho al representante legal del acreedor. El Art. 1579 CC señala casos de pagos hechos a representantes legales. No es taxativo.

2) Pago hecho al representante judicial. Es la persona designada por el juez para recibirlo. Puede ser el caso de que exista una medida precautoria de secuestro.

3) Pago hecho al diputado para recibir el pago (mandatario). Puede incluso ser un incapaz relativo (Art. 1581 CC). 3 modalidades de mandato (Art. 1580 CC):

- Mandato general de administración.
- Mandato especial para administrar el negocio en que incide el pago.
- Mandato especial para cobrar un determinado crédito.

Art. 1582 CC. "El poder conferido por el acreedor a una persona para demandar en juicio al deudor, no le faculta por sí solo para recibir el pago de la deuda."

Para que el pago hecho a un diputado sea eficaz es necesario que el mandatario actúe dentro de la esfera del mandato (Art. 2160 inc. 1º CC) y que aparezca recibiendo en su carácter de tal para el mandante o ello aparezca del tenor o espíritu del acto.

Extinción de la diputación para recibir el pago.

Art. 1586 CC. "La persona diputada para recibir se hace inhábil por la demencia o la interdicción, por haber hecho cesión de bienes o haberse trabado ejecución en todos ellos; y en general por todas las causas que hacen expirar un mandato."

3) Pago hecho al actual poseedor del crédito.

Art. 1576 inc. 2º CC. "El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito, es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía."

Casos más corrientes:

- pago hecho al heredero a quien se concedió la posesión efectiva,
- o al legatario cuyo legado había sido revocado por un testamento posterior.

Requisitos:

- 1) El que recibe debe encontrarse en posesión del crédito.
- 2) El que paga debe hacerlo de buena fe, entendiendo que está pagando al dueño del crédito.

10. Pago hecho a otras personas no es eficaz, no extingue la obligación.

Pero el pago hecho a una persona inhábil se puede validar en los casos establecidos en el Art. 1577 CC:

1. Si el acreedor lo ratifica.
2. Si el que recibe el pago sucede en el crédito.

11. Época en que debe hacerse el pago.

El pago debe hacerse en el lugar y tiempo convenidos.

- Si nada se ha convenido, y la obligación es pura y simple, el pago debe hacerse de inmediato, una vez celebrado el contrato.
- Si está sujeta a un plazo o condición suspensiva, debe hacerse desde que venza el plazo o se cumpla la condición.
- Si el plazo está establecido en el solo beneficio del deudor, puede pagar antes del vencimiento.

12. Lugar donde debe hacerse el pago.

Art. 1587 CC. "El pago debe hacerse en el lugar designado por la convención."

Art. 1588 CC. "Si no se ha estipulado lugar para el pago y se trata de un cuerpo cierto, se hará el pago en el lugar en que dicho cuerpo existía al tiempo de constituirse la obligación.

Pero si se trata de otra cosa se hará el pago en el domicilio del deudor."

Domicilio del deudor: el que tenía al momento de celebrar el contrato (Art. 1589 CC).

13. Contenido del pago.

La idea central está en los Arts. 1569 y 1591 CC ya vistos. Hay que atender a la naturaleza de la obligación para ver cómo se hace el pago:

1. Género: entregando cualquier individuo del género, de una calidad a lo menos mediana (Art. 1509 CC).
2. Dinero: entregando la suma numérica establecida (sistema nominalista).
3. Hacer o no hacer: realizando la prestación o abstención convenida.
4. Dar o entregar una especie: el acreedor debe recibirla en el estado en que se encuentre:
 - Deberá soportar los deterioros provenientes de caso fortuito o fuerza mayor.
 - Si la cosa se deterioró por hecho o culpa del deudor, o durante su mora, hay que distinguir si los deterioros (Art. 1590 CC):
 - Son importantes: puede pedirse resolución o aceptar la cosa como esté, en ambos casos con indemnización.
 - No son importantes: debe recibirse la cosa como está, pero con indemnización.

Si el deterioro ocurrió antes de la mora, por culpa de un tercero por quien el deudor no responde, es válido el pago de la cosa en el estado en que se encuentre, pero el acreedor puede exigir que se le ceda la acción del deudor contra el tercero.

14. Caso en que concurren varias obligaciones entre las mismas partes.

Art. 1594 CC. "Cuando concurren entre unos mismos acreedor y deudor diferentes deudas, cada una de ellas podrá ser satisfecha separadamente; y por consiguiente el deudor de muchos años de una pensión, renta o canon podrá obligar al acreedor a recibir el pago de un año, aunque no le pague al mismo tiempo los otros."

15. De la imputación del pago.

Supuestos que deben concurrir para que se presente el problema:

1. Que existan varias deudas de una misma naturaleza.
2. Que estas deudas sean entre las mismas partes.
3. Que se haga un pago insuficiente para satisfacerlas a todas.

Reglas:

1) Si se debe capital e intereses, el pago se imputa primero a los intereses (Art. 1595 CC).

2) Si hay diferentes deudas, el deudor puede imputarlo a la que elija.

Limitaciones:

- a) No puede preferir la deuda no devengada a la que lo está (Art. 1596 CC).

b) Debe imputar el pago a la deuda que se alcanza a pagar en su integridad (Art. 1591 CC).

3) Si el deudor no hace la imputación, puede hacerla el acreedor, en la carta de pago o recibo. Si el deudor la acepta, no puede reclamar después (Art. 1596 CC).

4) Si ninguna de las partes hace la imputación, la hace la ley: se prefiere la deuda que al tiempo del pago está devengada a la que no lo está, y si no hay diferencia, a la que el deudor elija (Art. 1597 CC).

16. Prueba del pago.

Corresponde al deudor (Art. 1698 CC). Puede valerse de todos los medios de prueba, con las limitaciones de los Arts. 1708 y 1709 CC para la prueba de testigos.

17. Presunciones legales de pago.

Art. 1570 CC. "En los pagos periódicos la carta de pago de tres períodos determinados y consecutivos hará presumir los pagos de los anteriores períodos, siempre que hayan debido efectuarse entre los mismos acreedor y deudor."

Art. 1595 incº2 CC. "Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen éstos pagados."

18. Gastos del pago.

Art. 1571 CC. "Los gastos que ocasionare el pago serán de cuenta del deudor; sin perjuicio de lo estipulado y de lo que el juez ordenare acerca de las costas judiciales."

Excepciones: pago por consignación (Art. 1604 CC), gastos de transporte para la restitución del depósito (Art. 2232 CC).

19. Efectos del pago.

El efecto propio es extinguir la obligación, lo que no se produce cuando paga un tercero, como lo vimos.

5.5.1. MODALIDADES DEL PAGO.

5.5.1.1. PAGO POR CONSIGNACIÓN.

1. Concepto.

Es una modalidad del pago regulada en los Arts. 1598 a 1607 CC.

El pago es una convención, que requiere acuerdo de voluntades. Pero esto se altera en el pago por consignación, lo que se explica en que el deudor tiene derecho a pagar:

Art. 1598 CC. "Para que el pago sea válido, no es menester que se haga con el consentimiento del acreedor; el pago es válido aun contra la voluntad del acreedor, mediante la consignación."

Art. 1599 CC. "La consignación es el depósito de la cosa que se debe, hecho a virtud de la repugnancia o no comparecencia del acreedor a recibirla, o de la incertidumbre acerca de la persona de éste, y con las formalidades necesarias, en manos de una tercera persona."

2. Casos en que procede el pago por consignación.

- Si existe negativa del acreedor a aceptarlo.
- Si el acreedor no concurre a recibirlo.
- Si existe incertidumbre acerca de la persona del acreedor.

3. Fases del pago por consignación.

- 1) Oferta.
- 2) Consignación propiamente tal.
- 3) Declaración de suficiencia de pago.

Las 2 primeras son extrajudiciales:

Art. 1601 inc. 3º CC. "No será necesario decreto judicial previo para efectuar la oferta ni para hacer la consignación."

1) LA OFERTA.

Art. 1600 CC. "La consignación debe ser precedida de oferta,...".

Requisitos de la oferta.

Son de fondo y de forma, y están en el Art. 1600 CC.

Requisitos de fondo de la oferta.

1. Debe hacerla una persona capaz de pagar (Art. 1600 N° 1 CC).
2. Debe ser hecha al acreedor, si es capaz de recibir el pago, o a su legítimo representante (Art. 1600 N° 2 CC). Si no tiene domicilio en el lugar en que deba efectuarse el pago, o no es habido, o hay incertidumbre acerca de la persona del acreedor, la oferta se hace al tesorero comunal (Art. 1602 CC).
3. Si la obligación es a plazo o bajo condición suspensiva, debe haber expirado el plazo o haberse cumplido la condición (Art. 1600 N° 3 CC). Si es a plazo, puede hacerse en los dos últimos días del plazo, y de acuerdo al Art. 1605 inc. 2º CC, se puede hacer hasta el día siguiente hábil al vencimiento.
4. Se debe ofrecer en el lugar debido (Art. 1600 N° 4 CC).

Requisitos de forma de la oferta.

1. Debe hacerse a través de un notario o receptor competente, sin previa orden del tribunal (Art. 1600 N° 5 CC). En las comunas en que no hay notario, puede hacerlo el oficial del Registro Civil.
2. El deudor debe entregarle al funcionario una minuta de lo que debe. No es necesario presentar la cosa debida (Art. 1600 N° 5 CC).
3. El funcionario debe extender un acta en que se copia la minuta (Art. 1600 N° 6 CC). En esta acta debe expresarse la respuesta del acreedor o su representante, y si la han firmado, se han rehusado firmar o han declarado no saber o no poder firmar (Art. 1600 N° 7 CC).

Características de la oferta.

Es un trámite extrajudicial y formal.

No se requiere oferta.

1. Si existe una demanda judicial: Art. 1600 inc. final CC. "Sin embargo, si el acreedor demanda judicialmente el cumplimiento de la obligación o deduce cualquiera otra acción que pueda enervarse mediante el pago de la deuda, bastará que la cosa debida con los intereses vencidos, si los hay, y demás cargos líquidos, se consigne a la orden del tribunal que conoce del proceso en alguna de las formas que señala el artículo 1601, sin necesidad de oferta previa. En este caso la suficiencia del pago será calificada por dicho tribunal en el mismo juicio."
2. Art. 1601 inc. 5° CC. "Cuando se trate del pago periódico de sumas de dinero provenientes de una misma obligación, las cuotas siguientes a la que se haya consignado se depositarán en la cuenta bancaria del tribunal sin necesidad de nuevas ofertas."

Situaciones especiales.

- Art. 23 Ley 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos: si el arrendador no quiere recibir la renta, el arrendatario puede depositarla en la tesorería, la cual le dará el recibo y comunicará al arrendador la existencia del depósito. Este pago se entiende hecho al arrendador.
- Art. 70 Ley 18.092 sobre letras de cambio: los notarios, antes de estampar el protesto por falta de pago, deben verificar en la tesorería si se ha efectuado algún depósito destinado al pago. En consecuencia, si el día del vencimiento de una letra nadie aparece a cobrarla, se puede consignar sin más trámites su valor en la tesorería, para evitar su protesto.

Resultados de la oferta.

Pueden ocurrir dos cosas:

1. Que el acreedor la acepte: termina el procedimiento.

2. Que el acreedor la rechace, o no sea habido, o subsista la incertidumbre sobre quién es: se pasa a la etapa siguiente.

2) LA CONSIGNACIÓN.

Art. 1601 incs. 1º y 2º CC. "Si el acreedor o su representante se niega a recibir la cosa ofrecida, el deudor podrá consignarla en la cuenta bancaria del tribunal competente, o en la tesorería comunal, o en un banco u oficina de la Caja Nacional de Ahorros, de la Caja de Crédito Agrario, feria, martillo o almacén general de depósito del lugar en que deba hacerse el pago, según sea la naturaleza de la cosa ofrecida.

Podrá también efectuarse la consignación en poder de un depositario nombrado por el juez competente."

Plazo para consignar.

La ley no establece plazo. No importa, porque el pago se va a entender realizado el día en que se efectúe la consignación (Art. 1605 inc. 1º CC).

3) LA DECLARACIÓN DE SUFICIENCIA DE PAGO.

Hecha la consignación, el deudor debe pedir al juez competente que ordene ponerla en conocimiento del acreedor, con intimación de recibir la cosa consignada (Art. 1603 inc. 1º CC). Aquí se inicia una gestión judicial de naturaleza contenciosa.

El acreedor puede adoptar 2 actitudes:

a) Aceptar la consignación: la obligación se extingue por pago.

b) Rechazar el pago o no decir nada: se debe declarar la suficiencia del pago.

Art. 1603 inc. 2º CC. "La suficiencia del pago por consignación será calificada en el juicio que corresponda promovido por el deudor o por el acreedor ante el tribunal que sea competente según las reglas generales."

En consecuencia, tanto el deudor como el acreedor pueden demandar la declaración de suficiencia de pago. Este juicio puede ser cualquiera en que se discuta el incumplimiento. Lo corriente va a ser que demande el acreedor, por lo dispuesto en el Art. 1603 inc. 3º CC.

Tribunal competente. Regla general y excepciones.

Se pide la declaración de suficiencia al juez competente de acuerdo a las reglas generales (Art. 1603 inc. 2º CC), que no tiene por qué ser el mismo que ordenó la notificación de la consignación. Excepciones:

1. Caso del Art. 1603 inc. 3º CC, en que declara la suficiencia el juez que ordenó la notificación.

2. Caso del Art. 1600 inc. final (hay un juicio que se puede enervar mediante el pago).

Efectos del pago por consignación.

Produce los efectos normales de todo pago.

Art. 1605 CC. "El efecto de la consignación suficiente es:

- extinguir la obligación,
- hacer cesar, en consecuencia, los intereses
- y eximir del peligro de la cosa al deudor, todo ello desde el día de la consignación. Sin embargo, si se trata de una obligación a plazo o bajo condición, aceptada la consignación por el acreedor, o declarado suficiente el pago por resolución ejecutoriada, la obligación se considerará cumplida en tiempo oportuno siempre que la oferta se haya efectuado a más tardar el día siguiente hábil al vencimiento de la obligación; pero el deudor quedará obligado en todo caso al pago de los intereses que se deban y al cuidado de la cosa hasta la consignación."

Gastos de la consignación.

Art. 1604 CC. "Las expensas de toda oferta y consignación válidas serán a cargo del acreedor."

Retiro de la consignación.

Art. 1606 CC. "Mientras la consignación no haya sido aceptada por el acreedor, o el pago declarado suficiente por sentencia que tenga la fuerza de cosa juzgada, puede el deudor retirar la consignación; y retirada, se mirará como de ningún valor y efecto respecto del consignante y de sus codeudores y fiadores."

Art. 1607 CC. "Cuando la obligación ha sido irrevocablemente extinguida, podrá todavía retirarse la consignación, si el acreedor consiente en ello. Pero en este caso la obligación se mirará como del todo nueva; los codeudores y fiadores permanecerán exentos de ella; y el acreedor no conservará los privilegios o hipotecas de su crédito primitivo. Si por voluntad de las partes se renovaren las hipotecas precedentes, se inscribirán de nuevo y su fecha será la del día de la nueva inscripción."

Esto se parece a la novación, con la diferencia de que en la novación debe haber una obligación preexistente, que no se da en este caso, pues la obligación se extinguió.

5.5.1.2 PAGO CON SUBROGACIÓN.

Concepto de subrogación.

- **Concepto genérico de subrogación:** En general, implica la idea de reemplazo de una persona o cosa por otra.
- En la subrogación real, una cosa toma el lugar de otra, que se le reputa de su misma naturaleza y cualidades.

- En la subrogación personal, una persona pasa a ocupar el lugar de otra, ocupa su sitio, pudiendo por ello ejercitar sus acciones y derechos.
- **Concepto de pago con subrogación:** el tercero que paga una deuda ajena pasa a ocupar el lugar del acreedor a quien paga. Por ello es que la obligación, pese a estar pagada, no se extingue, pues pasa al tercero que paga con sus derechos, acciones y privilegios.

Paralelo entre la cesión de créditos y el pago con subrogación.

En ambos casos se produce un cambio del titular del crédito. Pero la mayor diferencia es que:

- La cesión de derechos constituye una especulación, El cesionario pretende hacer un negocio, comprando el crédito barato y cobrándolo en su integridad
- La subrogación es simplemente un pago. El tercero que paga sólo cobrará lo que pagó (es una garantía para el que paga).

Definición de subrogación.

Art. 1608 CC. "La *subrogación* es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero, que le paga."

Críticas:

1) "Transmisión" es propia de la sucesión por causa de muerte. Lo que se ha querido significar es que el tercero que paga queda respecto del acreedor en una situación análoga a la del heredero respecto del causante: pasa a ocupar su lugar.

2) No da una idea clara de la institución.

Es mejor definir a la **subrogación** como una (1) ficción jurídica, en virtud de la cual, (2) cuando un tercero paga voluntariamente con dineros propios una obligación ajena, (3) ésta se extingue entre el acreedor y deudor, (4) pero subsiste teniendo por nuevo acreedor al que efectuó el pago (Abeliuk).

*Lo esencial no es que pague un tercero sino que el pago se realice con fondos de un tercero.

En la subrogación el tercero que paga tiene diferentes acciones para recuperar lo que pagó.

1. Va a tener el mismo crédito del acreedor a quien pagó.
2. También podrá hacer uso de las acciones que deriven de la vinculación que él puede tener con el deudor (como fiador, mandatario o agente oficioso).

Clases de subrogación.

Art. 1609 CC. "Se subroga un tercero en los derechos del acreedor, o en virtud de la ley, o en virtud de una convención del acreedor."

5.5.1.2.1 SUBROGACIÓN LEGAL.

Art. 1610 CC. "Se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley y aun contra la voluntad del acreedor, en todos los casos señalados por las leyes, y especialmente a beneficio,..."

La disposición contempla 6 casos, y no es taxativa. Otros casos:

- 1) Tercer poseedor de la finca hipotecada que paga la hipoteca (Art. 2429 CC).
- 2) Legatario que paga la hipoteca con que la cosa legada estaba gravada (Art. 1366 CC).
- 3) El que paga por error una deuda ajena, que para recuperar lo pagado puede intentar contra el deudor las acciones del acreedor (Art. 2295 CC).
- 4) Acreedores del arrendador (Art. 1965 CC).

1.

Art. 1610 N° 1 CC. "Del acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho en razón de un privilegio o hipoteca;"

La utilidad que tiene esta subrogación para el tercero que paga es que evita que el acreedor de mejor derecho haga efectivo su crédito, lo que podría perjudicarlo si rematado el bien, no alcanza para satisfacer ambos créditos.

Requisitos:

- a) Que el pago lo haga otro acreedor.
- b) Que se haga a un acreedor de mejor derecho, en virtud de un privilegio o hipoteca.

Se ha estimado que no es necesario hacer una nueva inscripción de la hipoteca a nombre del acreedor que paga.

2.

Art. 1610 N° 2 CC. "Del que habiendo comprado un inmueble, es obligado a pagar a los acreedores a quienes el inmueble está hipotecado;"

La utilidad se produce respecto del que compra un inmueble gravado con varias hipotecas. Ej. El comprador paga a los 2 primeros acreedores hipotecarios, pero no al tercero. El tercero saca a remate el inmueble, y el resultado alcanza para las 2 primeras. El tercero no se va a pagar, porque reviven las dos primeras hipotecas, ocupando el comprador el lugar de los dos acreedores, y se le paga a él.

Utilidad del artículo 1610 N° 2 en el caso de la purga de la hipoteca:

- En el caso en que se subasta una finca gravada con varias hipotecas,

- y respecto de un acreedor hipotecario no se produce la purga de la hipoteca por no haber sido emplazado,
- se aplica el Art. 1610 N° 2 CC: si éste acreedor saca a remate el inmueble, las hipotecas anteriores reviven en el comprador que adquirió el bien en la primera subasta, pasando a ocupar el lugar de los acreedores pagados en ella. Si lo obtenido en el nuevo remate no alcanza sino para pagar las hipotecas anteriores, el acreedor que sacó a remate el bien no se va a pagar, y ahora sí se produce respecto de él la purga de la hipoteca.

Subrogación del tercer poseedor de la finca hipotecada.

Es tercer poseedor quien cumple dos requisitos:

1. No ser deudor personal de la deuda garantizada con hipoteca.
2. Ser el poseedor (normalmente dueño) de la finca hipotecada.

Ya vimos los casos en que se da.

Si el deudor de la obligación garantizada con la hipoteca no paga, el acreedor hipotecario va a perseguir la finca en poder de quien se encuentre. Para ello debe notificar al tercero poseedor, para que pague la deuda o abandone la finca. Si paga, se va a subrogar en el derecho del acreedor hipotecario a quien paga (Art. 2429 CC).

3.

Art. 1610 N° 3 CC. "Del que paga una deuda a que se halla obligado solidaria o subsidiariamente;"

- El codeudor solidario, sólo puede cobrar a cada uno su cuota.
- El fiador, tiene la misma acción que tenía el acreedor, o puede usar la acción de reembolso que le corresponde como fiador.

4.

Art. 1610 N° 4 CC. "Del heredero beneficiario que paga con su propio dinero las deudas de la herencia;"

Heredero beneficiario es el que goza del beneficio de inventario. Este heredero paga más allá de lo que le corresponde, y se subroga por este exceso en los derechos del acreedor, a quien paga, para cobrarlo a los demás herederos.

5.

Art. 1610 N° 5 CC. "Del que paga una deuda ajena, consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor;"

Ya vimos este caso al estudiar quién puede hacer el pago. Este tercero tiene además la acción propia del mandato.

6.

Art. 1610 N° 6 CC. "Del que ha prestado dinero al deudor para el pago; constando así en escritura pública del préstamo, y constando además en escritura pública del pago haberse satisfecho la deuda con el mismo dinero."

Requisitos para que opere la subrogación del artículo 1610 N° 6.

- 1) Que el tercero preste dineros al deudor para que pague.
- 2) Que el deudor pague la deuda con ese mismo dinero.
- 3) Que el mutuo se otorgue por escritura pública, en que se exprese que el mutuo se otorga para pagar la deuda.
- 4) Que se deje constancia del pago en una escritura pública donde se exprese que éste se hace con dineros que el deudor obtuvo del préstamo.

5.5.1.2.2 SUBROGACIÓN CONVENCIONAL.

Art. 1611 CC. "Se efectúa la subrogación en virtud de una convención del acreedor; cuando éste, recibiendo de un tercero el pago de la deuda, le subroga voluntariamente en todos los derechos y acciones que le corresponden como tal acreedor: la subrogación en este caso está sujeta a la regla de la cesión de derechos, y debe hacerse en la carta de pago."

El deudor no interviene en este acuerdo.

Requisitos de la subrogación convencional.

- 1) Que un tercero no interesado pague una deuda ajena.
- 2) Que pague sin voluntad del deudor.
- 3) Que el acreedor pagado subroque voluntariamente en sus derechos al tercero que paga. No pueden hacer la subrogación aquellos que pueden recibir el pago en virtud de mandato especial o de simple diputación para recibir el pago.
- 4) Que la subrogación se haga en forma expresa, lo que se deriva de la exigencia de hacerla en la carta de pago.
- 5) Que conste en la carta de pago o recibo. Esto significa que se hace en el momento mismo de recibir el pago, no después.
- 6) Que se sujete a las reglas de la cesión de derechos, lo que significa que el acreedor debe entregar el título de la deuda al tercero que paga, y debe notificarse al deudor (o éste aceptar) para le sea oponible a él y a terceros.

Efectos de la subrogación.

Art. 1612 CC. "La subrogación, tanto legal como convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones, privilegios, prendas e hipotecas del antiguo, así contra el deudor principal, como contra cualesquiera terceros, obligados solidaria o subsidiariamente a la deuda.
Si el acreedor ha sido solamente pagado en parte, podrá ejercer sus derechos, relativamente a lo que se le reste debiendo, con preferencia al que sólo ha pagado una parte del crédito."

Por lo tanto:

1. Obligación mercantil. Si la obligación era mercantil, conserva esa naturaleza.
2. Cauciones. Si la obligación estaba caucionada, las cauciones se mantienen.
3. Títulos ejecutivos. Los títulos ejecutivos a favor del acreedor original se mantienen respecto del tercero que paga. Esto es discutible, pues del solo título ejecutivo no aparece que el acreedor sea el que pagó, y el título debe bastarse a sí mismo (no se permite yuxtaposición de títulos).
4. Intereses. Si la obligación generaba intereses, éstos seguirán devengándose.
5. Plazo. Si la obligación estaba sujeta a plazo, el tercero que paga no puede cobrar antes de que se cumpla.
6. Acción resolutoria. El tercero que paga queda en la misma situación jurídica del acreedor primitivo, es decir, en calidad de contratante, lo que le permite deducir acción resolutoria en los contratos bilaterales. Esto es discutible.
7. Derechos y privilegios especiales. Ciertos derechos y privilegios especiales establecidos en consideración a la persona del acreedor no pueden cederse. También es discutible.
8. Plazos de prescripción. La subrogación no altera los plazos de prescripción que estén corriendo.
9. Subrogación parcial. Si la subrogación es parcial, el tercero que paga goza de los derechos, acciones y privilegios en proporción a lo pagado, y tiene preferencia el acreedor primitivo para el pago de la parte que se le adeuda.

5.5.1.3 PAGO CON CESIÓN DE BIENES³⁷.

1. Ideas generales.

Son dos materias diferentes:

1. Pago por cesión de bienes, regulado en los Arts. 1614 a 1624 CC.
2. Pago por acción ejecutiva, que ya lo vimos en la ejecución forzada.

2. Del pago por cesión de bienes.

Cuando el deudor no está en situación de poder cumplir sus obligaciones, puede hacer dos cosas: esperar a que lo ejecuten o adelantarse a la ejecución haciendo cesión de sus bienes a sus acreedores. Esto tenía utilidad antes de que se derogara la prisión por deudas.

3. Concepto de pago por cesión de bienes.

Art. 1614 CC. "La *cesión* de bienes es el abandono voluntario que el deudor hace de todos los suyos a su acreedor o acreedores, cuando, a consecuencia de accidentes inevitables, no se halla en estado de pagar sus deudas."

³⁷ CORRAL, Hernán. "Es preocupante el completo silencio que la reforma mantiene sobre la cesión de bienes regulada en el Código Civil, que no parece ahora tener sentido práctico alguno, dado este nuevo régimen concursal". El nuevo régimen concursal y su impacto en materia civil. Disponible en <<https://corraltalciani.wordpress.com/2014/03/02/el-nuevo-regimen-concursal-y-su-impacto-en-materia-civil/>>

4. Características.

- 1) Es un derecho personalísimo del deudor (Art. 1623 CC): no aprovecha a codeudores solidarios o subsidiarios.
- 2) Es un beneficio irrenunciable (Art. 1615 CC).
- 3) Es universal (Art. 1618 CC): comprende todos los bienes del deudor, salvo los inembargables.

5. Requisitos.

- 1) Que se trate de un deudor no comerciante (Art. 241 LQ).
- 2) Que el deudor no se encuentre en alguno de los casos enumerados en el Art. 43 LQ. Si está en alguno de esos casos, se puede solicitar su quiebra.
- 3) Que el deudor civil se encuentre en insolvencia (pasivo mayor al activo).
- 4) Que este estado de insolvencia no se deba a hecho o culpa del deudor, sino que sea fortuito.

6. Procedimiento.

Se tramita en un procedimiento judicial entre el deudor y sus acreedores, reglamentado en la LQ.

Se tramita judicialmente porque, aunque la regla general es que los acreedores deben aceptar la cesión, pueden oponerse fundados en que el deudor se encuentra en alguno de los casos de excepción del Art. 1617 CC.

7. Efectos del pago por cesión de bienes.

1. La cesión de bienes no importa que el deudor enajene sus bienes a sus acreedores, sino sólo la facultad de disponer de ellos y de sus frutos hasta pagarse de sus créditos (Art. 1619 inc. final CC). Es por ello que el deudor puede arrepentirse de la cesión antes de la venta (Art. 1620 CC).
2. Respecto de la administración de los bienes: si el deudor tiene un solo acreedor, éste puede dejarle la administración a aquel (Art. 244 LQ). Si son varios acreedores, los bienes son administrados por un síndico (Art. 246 N° 1 LQ).
3. Si el deudor, después de la cesión, enajena los bienes, dichas enajenaciones adolecen de nulidad absoluta (Art. 2467 CC y Art. 253 LQ).
4. Los actos anteriores a la cesión son atacables por la acción pauliana (Art. 2468 CC y Art. 253 LQ).
5. Los pagos hechos al deudor que ha hecho cesión son nulos (Art. 1578 N° 3 CC).
6. Se produce la caducidad de los plazos (Art. 1496 N° 1 CC).
7. Cesan los apremios personales (Art. 1619 N° 1 CC). Hoy no tiene aplicación.
8. Las deudas se extinguen hasta la cantidad en que sean satisfechas con los bienes cedidos (Art. 1619 N° 2 CC).
9. Si los bienes cedidos no bastan para pagar completamente las deudas, y el deudor adquiere después otros bienes, es obligado a completar el pago (Art. 1619 N° 3 CC). Esta obligación prescribe en 5 años desde que se acepta la cesión (Art. 254 LQ).

Extinción de la cesión de bienes.

- 1) Si el deudor paga a los acreedores (Art. 1620 CC).
- 2) Por la sentencia de grados que determina el orden en que deben pagarse los acreedores.
- 3) Por el sobreseimiento definitivo o temporal.
- 4) Por convenio.

5.5.1.4. PAGO CON BENEFICIO DE COMPETENCIA.

1. Ideas generales.

Está regulado en los Arts. 1625 a 1627 CC.

Art. 1625 CC. "*Beneficio de competencia* es el que se concede a ciertos deudores para no ser obligados a pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoseles en consecuencia lo indispensable para una modesta subsistencia, según su clase y circunstancias, y con cargo de devolución cuando mejoren de fortuna."

Finalidad: no dejar al deudor en la absoluta indigencia.

2. Personas que pueden demandar este beneficio.

Art. 1626 CC. "El acreedor es obligado a conceder este beneficio:

- 1º A sus descendientes o ascendientes; no habiendo éstos irrogado al acreedor ofensa alguna de las clasificadas entre las causas de desheredación;
- 2º A su cónyuge; no estando divorciado por su culpa;
- 3º A sus hermanos; con tal que no se hayan hecho culpables para con el acreedor de una ofensa igualmente grave que las indicadas como causa de desheredación respecto de los descendientes o ascendientes;
- 4º A sus consocios en el mismo caso; pero sólo en las acciones recíprocas que nazcan del contrato de sociedad;
- 5º Al donante; pero sólo en cuanto se trata de hacerle cumplir la donación prometida;
- 6º Al deudor de buena fe que hizo cesión de bienes y es perseguido en los que después ha adquirido para el pago completo de las deudas anteriores a la cesión; pero sólo le deben este beneficio los acreedores a cuyo favor se hizo."

3. Características.

- 1) Es un beneficio personalísimo concedido por la ley al deudor. No puede renunciarse, transferirse, transmitirse ni perderse por prescripción.
- 2) Puede oponerse en cualquier momento como excepción.
- 3) Tiene carácter alimenticio (Art. 1627 CC).

5.5.1.5 LA DACIÓN EN PAGO.

1. Ideas generales.

Es un modo de extinguir las obligaciones que no está en la enumeración del Art. 1567 CC ni tampoco ha sido reglamentado en la ley. Pero muchas disposiciones se refieren a él.

2. Concepto de dación en pago.

Las partes contratantes, en virtud de la autonomía de la voluntad, pueden convenir que la obligación se extinga pagando el deudor con una cosa distinta de la debida.

Art. 1569 inc. 2º CC. "El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba...". □ Contrario sensu, si el acreedor está de acuerdo, puede recibir en pago otra cosa.

3. Definición doctrinaria.

Dación en pago: convención entre acreedor y deudor en virtud de la cual el primero acepta en pago una cosa distinta de la debida.

- Es un modo de extinguir las obligaciones que se perfecciona por la entrega voluntaria que un deudor hace a título de pago a un acreedor, y con el consentimiento de éste, de una prestación u objeto distinto de lo debido.

4. La dación en pago es una convención.

No es un contrato, sino una convención extintiva.

1. Algunos sostienen que además es un verdadero título traslativo de dominio.
2. Quienes discrepan, se basan en los siguientes argumentos:
 - i. La dación en pago es una convención extintiva, y no un contrato. Los ejemplos de títulos traslativos del Art. 703 CC son todos contratos, porque generan obligaciones.
 - ii. La dación en pago requiere consentimiento de las partes, pero se perfecciona cuando se entrega la cosa. No hay momento para que se genere obligación.
 - iii. La dación en pago derechamente transfiere el dominio, no sirve para transferirlo, como ocurre con los títulos traslativos de acuerdo a la definición del Art. 703 CC.

5. Naturaleza jurídica de la dación en pago.

1) La dación en pago es una compraventa seguida de compensación.

El deudor está vendiendo al acreedor el objeto dado en pago. El precio de la compraventa, que el acreedor debe pagar al deudor, se compensa con la obligación que el deudor tenía.

Críticas a esta teoría:

- 1) Es artificiosa; no está en la mente de las partes celebrar una compraventa.
- 2) Limita la dación en pago a las obligaciones de pagar una suma de dinero.
- 3) Si la dación en pago es compraventa, no podría haberlas entre marido y mujer, lo que es contrario a los Arts. 1763 y 1792-22 CC.

2) La dación en pago sería una novación objetiva, pues se sustituiría a una obligación por otra con un objeto distinto.

Art. 1628 CC. "La *novación* es la substitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida."

Crítica: en la dación en pago no nace una nueva obligación, simplemente se extingue la única obligación existente. La novación requiere animus novandi, que no existe en la dación en pago.

3) La dación en pago es simplemente una modalidad del pago.

Es la tesis acogida por la jurisprudencia. Un buen argumento es el Art. 76 N° 2 LQ, que señala que la dación en pago de efectos de comercio equivale a pago en dinero.

Consecuencias: se le aplican las normas del pago, salvo las del pago por consignación.

4) La dación en pago es una figura autónoma.

Crítica: no soluciona ningún problema.

6. Requisitos de la dación en pago.

- 1) Existencia de una obligación. Puede ser de dar, hacer o no hacer.
- 2) La obligación se va a extinguir con una prestación diferente a la debida.
- 3) Consentimiento y capacidad de las partes.
 - Consentimiento: reglas generales.
 - Capacidad: como es una modalidad de pago, requiere la misma capacidad que el pago, esto es, capacidad de disposición en quien hace el pago y capacidad de administración en quien lo recibe. Pero como la dación en pago es una renuncia a recibir la prestación debida, requiere capacidad de disposición.
 - Si mediante ella se da alguna cosa, el que la da debe ser su dueño (Art. 1575 CC).
- 4) Animus solvendi. Las partes deben tener la intención compartida de extinguir de esta manera la obligación.

5) Solemnidades legales en ciertos casos. Es un acto jurídico consensual, pero si lo que se da en pago es un inmueble, debe hacerse por escritura pública e inscripción.

7. Efectos de la dación en pago.

Produce los mismos efectos del pago: extingue la obligación con sus accesorios. Si es parcial, subsiste en la parte no pagada.

8. Evicción de la cosa recibida en pago.

La mayoría de la doctrina estima que el deudor tiene la obligación de garantía, lo que no implica que se le dé el carácter de compraventa. Esto es confirmado por el Art. 1792-22 CC.

En consecuencia, el acreedor que recibió la cosa evicta puede demandar las indemnizaciones correspondientes. El problema es si mantiene las acciones de la obligación extinguida por la dación en pago. Si la consideramos como una modalidad de pago, el acreedor mantiene las acciones, porque el pago fue ineficaz.

9. Paralelo entre la dación en pago, obligación facultativa y novación.

Ej. Se celebra un contrato de compraventa en que el vendedor se obliga a entregar un automóvil en 30 días más.

1. Obligación facultativa: en el mismo contrato, el deudor queda facultado para cumplir esa obligación con un avión.

2. Dación en pago: al cumplirse los 30 días, el comprador acepta que la obligación se pague con el avión.

3. Novación objetiva por cambio de objeto: antes de cumplirse los 30 días, las partes acuerdan cambiar la cosa debida, obligándose el deudor a entregar un avión en vez de un auto.

5.6 LA NOVACIÓN.

1. Ideas generales y concepto legal.

Está contemplada como modo de extinguir las obligaciones en el Art. 1567 N° 2 CC y regulada en los Arts. 1628 a 1651 CC.

Art. 1628 CC. La novación es la substitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida.

2. La novación es una figura híbrida de contrato y convención.

Produce el doble efecto de generar una obligación nueva (contrato) y extinguir una obligación anterior (convención extintiva).

3. Requisitos de la novación.

1) Una obligación anterior que se extingue.

Puede ser una obligación civil o natural, pero debe cumplir 2 requisitos:

1. Debe ser válida (Art. 1630 CC).
2. No puede ser condicional suspensiva (Art. 1633 CC). Pero las partes pueden convenir que el contrato quede desde luego abolido sin esperar el cumplimiento de la condición.

2) Una obligación nueva que va a reemplazar la anterior.

También puede ser civil o natural, y no puede estar sujeta a condición suspensiva (mismos requisitos que la obligación anterior).

3) Diferencia esencial entre ambas obligaciones.

Esto va a ocurrir en los siguientes casos:

1. Cambio de deudor o acreedor.
2. Cambio del objeto de la prestación.
3. Cambio de causa.

Este requisito está en el Art. 1631 CC, que señala los modos de efectuar la novación.

Art. 1631 CC. La novación puede efectuarse de tres modos:

1. Substituyéndose una nueva obligación a otra, sin que intervenga nuevo acreedor o deudor;
2. Contrayendo el deudor una nueva obligación respecto de un tercero, y declarándole en consecuencia libre de la obligación primitiva el primer acreedor;
3. Substituyéndose un nuevo deudor al antiguo, que en consecuencia queda libre. Esta tercera especie de novación puede efectuarse sin el consentimiento del primer deudor. Cuando se efectúa con su consentimiento, el segundo deudor se llama delegado del primero.

El CC señala una serie de casos en que no hay novación por no haber diferencia esencial, no hay novación si la nueva obligación se limita a:

1. Simplemente en añadir o quitar una especie, género o cantidad a la primera (Art. 1646 CC).
2. Imponer una pena o a establecer otra para el caso de incumplimiento (Art. 1647 CC).
3. Cambiar el lugar del pago (Art. 1648 CC).

4. Ampliar el plazo (Art. 1649 CC).

5. Reducir el plazo (Art. 1650 CC)

4) Capacidad de las partes para novar.

El acreedor requiere tener capacidad de disposición, porque va a extinguir su crédito. Para el deudor, basta la capacidad para obligarse.

La novación puede celebrarse mediante mandatarios. Capacidad del mandatario.

Puede novar el mandatario que:

- tiene poder especial para ello,
- el que administra el negocio en que incide la novación,
- y el mandatario con poder general de administración (Art. 1929 CC).

5) Intención de novar (animus novandi).

Art. 1634 CC. "Para que haya novación, es necesario que lo declaren las partes, o que aparezca indudablemente, que su intención ha sido novar, porque la nueva obligación envuelve la extinción de la antigua.

Si no aparece la intención de novar, se mirarán las dos obligaciones como coexistentes, y valdrá la obligación primitiva en todo aquello en que la posterior no se opusiere a ella, subsistiendo en esa parte los privilegios y cauciones de la primera."

No es necesario que el ánimo se manifieste expresamente. Excepción: novación por cambio de deudor, en que el acreedor debe expresar su voluntad de liberar al deudor primitivo (Art. 1635 CC).

4. Clases de novación.

Del Art. 1631 CC se desprende que la novación puede ser:

1. Objetiva (Art. 1631 N° 1 CC).
2. Subjetiva (Art. 1631 N° 2 y 3 CC).

NOVACIÓN OBJETIVA

2 casos:

- 1) Cambio de la cosa debida.
- 2) Cambio de causa de la obligación.

Utilidad del segundo caso: Ej. Si debe \$1 millón como saldo de precio en compraventa, y se reemplaza por la obligación de pagarlo a título de mutuo. Como se extingue la primera obligación, ya no se puede demandar la resolución del contrato de compraventa.

NOVACIÓN SUBJETIVA

2 tipos:

- 1) Por cambio de acreedor (Art. 1631 N° 2 CC).
- 2) Por cambio de deudor (Art. 1632 N° 3 CC).

1. NOVACIÓN SUBJETIVA POR CAMBIO DE ACREEDOR.

Art. 1631 N° 2 CC. "Contrayendo el deudor una nueva obligación respecto de un tercero, y declarándole en consecuencia libre de la obligación primitiva el primer acreedor;"

Se requiere que las 3 partes presten su consentimiento. No tiene mayor utilidad, porque su objetivo se puede lograr más fácilmente por la cesión de derechos o el pago con subrogación.

2. NOVACIÓN SUBJETIVA POR CAMBIO DE DEUDOR.

Art. 1631 N° 3 CC. "Substituyéndose un nuevo deudor al antiguo, que en consecuencia queda libre."

- Para perfeccionarse requiere el consentimiento del acreedor y del nuevo deudor. Si el acreedor no expresa su voluntad de dejar libre al primer deudor, se entiende que el tercero:
 - es solamente diputado por el deudor para hacer el pago,
 - o que se obliga solidaria o subsidiariamente con él, según sea el tenor del acto (Art. 1635 CC).
- No es necesario el consentimiento del primer deudor, pero si consiente, el nuevo deudor se llama delegado del primero (Art. 1631 inc. 2º CC).

Dos modalidades de novación por cambio de deudor:

- a) **Que el deudor primitivo acepte:** delegación.
 - Si el acreedor consiente en liberar al deudor, se produce novación (delegación perfecta);
 - Si el acreedor no consiente, no se produce novación (delegación imperfecta o acumulativa).
- b) **Que el deudor primitivo no acepte:** expromisión.
 - Si el acreedor consiente, se produce novación;
 - Si el acreedor no acepta, se produce la expromisión acumulativa, que no produce novación.

Efectos de la novación por cambio de deudor, si el nuevo deudor es insolvente.

El acreedor no puede dirigirse en contra del deudor primitivo, porque consintió en dejarlo libre. 3 excepciones (Art. 1637 CC):

1. Si en el contrato de novación el acreedor se ha reservado este derecho. En este caso, se entiende que el acreedor ha dejado libre al deudor en forma condicional.
2. Si la insolvencia del nuevo deudor haya sido anterior y pública.
3. Si la insolvencia del nuevo deudor, aunque no sea pública, haya sido conocida del deudor primitivo.

Se ha entendido que, en estos casos de excepción, la acción del acreedor es la misma que tenía en contra del primer deudor, y no una nueva generada por la novación, lo que es importante cuando la primera goza de privilegios o garantías.

5. Efectos de la novación.

El efecto propio es doble:

1. Extinguir la obligación novada.
2. Generar una nueva obligación.

La extinción de la obligación primitiva incluye sus privilegios, garantías y accesorios:

- 1) Se extinguen los intereses si no se expresa lo contrario (Art. 1640 CC).
- 2) Libera a los codeudores solidarios o subsidiarios, a menos que accedan a la nueva obligación (Art. 1645 CC).
- 3) Si el deudor estaba en mora, cesa la mora y sus consecuencias.
- 4) Los privilegios de la deuda primitiva no pasan a la nueva (Art. 1641 CC). La ley no hace referencia a una posible reserva, pues sólo la ley crea los privilegios, no la voluntad de las partes.
- 5) Las prendas e hipotecas de la deuda primitiva no pasan a la nueva, a menos que deudor y acreedor convengan expresamente la reserva (Art. 1642 inc. 1º CC).

Límites a la reserva de prendas e hipotecas.

1. No puede afectar a las garantías constituidas por terceros, a menos que accedan expresamente a la segunda obligación (Art. 1642 inc. 2º CC).
2. No vale la reserva en lo que la segunda obligación tenga de más que la primera (Art. 1642 inc. final CC).
3. Si la novación es por cambio de deudor, la reserva no puede afectar los bienes del nuevo deudor, aunque éste consienta en ello (Art. 1643 inc. 1º CC).
4. Si la novación opera entre el acreedor y uno de los deudores solidario, la reserva sólo afecta a éste (Art. 1643 inc. 2º CC).

Las partes pueden convenir garantías para la nueva obligación.

Art. 1644 CC. "En los casos y cuantía en que no puede tener efecto la reserva, podrán renovarse las prendas e hipotecas; pero con las mismas formalidades que si se constituyesen por primera vez, y su fecha será la que corresponda a la renovación."

Esto es obvio, en virtud de la autonomía de la voluntad.

5.7 LA COMPENSACIÓN.

1. Ideas generales.

Arts. 1567 N° 5 y 1655 a 1664 CC.

2. Definición.

El CC no la define, sólo señala que se produce (Art. 1655 CC).

Compensación: modo de extinguir las obligaciones que opera por el solo ministerio de la ley, cuando dos personas son personal y recíprocamente deudoras y acreedoras de obligaciones líquidas y actualmente exigibles, en cuya virtud se extinguen ambas hasta el monto de la de menor valor.

3. La compensación importa un doble pago.

Consecuencias:

1) Si el deudor solidario extingue la deuda por compensación, se subroga en la acción del acreedor con sus privilegios y garantías, limitada respecto de cada codeudor a su cuota.

2) Si hay pluralidad de deudas, se aplican las reglas de la imputación al pago (Art. 1663 CC).

4. Clases de compensación.

1. Legal: la establece la ley, y es la recién definida.

2. Convencional: por acuerdo entre las partes; no opera de pleno derecho por faltar alguno de los requisitos de la legal. Produce los mismos efectos que la legal.

3. Judicial: una de las partes demanda a la otra, que reconviene cobrando su crédito. El juez acogerá la compensación si se cumplen los requisitos legales.

5. Funciones e importancia de la compensación.

Es útil porque evita un doble pago. Tiene importancia en materia mercantil.

6. Requisitos de la compensación legal.

1) Que ambas deudas sean de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad (art. 1656 N° 1).

Finalidad: que haya perfecta equivalencia en el objeto de las obligaciones. Las obligaciones de especie o cuerpo cierto no se pueden compensar.

2) Las dos partes deben ser personal y recíprocamente deudoras y acreedoras (art. 1655 y 1657).

Deben ser deudores personales y principales:

- 1) El deudor principal no puede oponer en compensación el crédito de su fiador (Art. 1657 inc. 2º CC).
- 2) El deudor no puede oponer en compensación el crédito de su pupilo (Art. 1657 inc. 3º CC).
- 3) Demandado un codeudor solidario, no puede oponer en compensación el crédito de otro de sus codeudores solidarios, a menos que se lo haya cedido (Art. 1657 inc. final CC).

El Art. 1657 CC no es taxativo. Otro caso: el deudor no puede oponer en compensación el crédito de la sociedad de que forma parte.

Excepciones:

- 1) Art. 1658 CC. "El mandatario puede oponer al acreedor del mandante no sólo los créditos de éste, sino sus propios créditos contra el mismo acreedor, prestando caución de que el mandante dará por firme la compensación. Pero no puede compensar con lo que el mismo mandatario debe a un tercero lo que éste debe al mandante, sino con voluntad del mandante."
- 2) Art. 1659 CC. "El deudor que acepta sin reserva alguna la cesión que el acreedor haya hecho de sus derechos a un tercero, no podrá oponer en compensación al cesionario los créditos que antes de la aceptación hubiera podido oponer al cedente.
Si la cesión no ha sido aceptada, podrá el deudor oponer al cesionario todos los créditos que antes de notificársele la cesión haya adquirido contra el cedente, aun cuando no hubieren llegado a ser exigibles sino después de la notificación."

3) Que las deudas sean líquidas (art. 1656 N° 2).

La deuda es líquida cuando es cierta y determinada.

- No es cierta la deuda que está en litigio.
- Es líquida no sólo la que actualmente tiene esa calidad, sino la que es liquidable mediante simples operaciones (Art. 438 CPC).

4) Que ambas deudas sean actualmente exigibles (art. 1656 N° 3).

No pueden compensarse las obligaciones naturales ni las obligaciones condicionales o a plazos suspensivos.

Las esperas concedidas al deudor impiden la compensación, lo que no se aplica al plazo de gracia concedido por un acreedor a su deudor (prórroga que unilateral y voluntariamente da el acreedor).

5) Ambas deudas deben ser pagaderas en el mismo lugar.

Art. 1664 CC. "Cuando ambas deudas no son pagaderas en un mismo lugar, ninguna de las partes puede oponer la compensación, a menos que una y otra deuda sean de dinero, y que el que opone la compensación tome en cuenta los costos de la remesa."

6) Que ambos créditos sean embargables.

El CC no lo dice en forma general, sino sólo respecto de la obligación de alimentos. Pero es lógico que si uno de los créditos es inembargable, no cabe la compensación.

7) Que la compensación no se haga en perjuicio de terceros.

Art. 1661 CC. "La compensación no puede tener lugar en perjuicio de los derechos de tercero.
Así, embargado un crédito, no podrá el deudor compensarlo, en perjuicio del embargante, por ningún crédito suyo adquirido después del embargo."

Casos de compensación prohibida.

Art. 1662 CC. "No puede oponerse compensación a la demanda de restitución de una cosa de que su dueño ha sido injustamente despojado, ni a la demanda de restitución de un depósito, o de un comodato, aun cuando, perdida la cosa, sólo subsista la obligación de pagarla en dinero. Tampoco podrá oponerse compensación a la demanda de indemnización por un acto de violencia o fraude, ni a la demanda de alimentos no embargables."

7. Efectos de la compensación legal.

- 1) Opera de pleno derecho (Art. 1656 CC).
- 2) Debe ser alegada (Art. 1660 CC). 2 razones:
 - a. El deudor demandado puede renunciarla, lo que ocurre si no la alega.
 - b. Junto con alegarla, el que opone la compensación debe probar que se cumplen los requisitos.

La compensación no nace con la sentencia, que sólo se limita a declarar su existencia.

- 3) Extingue ambos créditos hasta el monto del de menor valor. Es el efecto principal, y lo producen todas las compensaciones.

8. Renuncia a la compensación.

Puede ser expresa o tácita. Es tácita cuando el deudor es demandado, y teniendo conocimiento de su crédito, no alega la compensación. Si no sabía que tenía el crédito, lo conserva con sus garantías y privilegios (Art. 1660 CC). Contrario sensu, si sabía y lo renuncia, se extinguen las garantías.

9. Compensación en el caso de pluralidad de obligaciones.

Art. 1663 CC. "Cuando hay muchas deudas compensables, deben seguirse para la compensación las mismas reglas que para la imputación del pago."

5.8 LA REMISIÓN

1. Ideas generales.

Art. 1567 N° 4 y 1652 a 1654 CC.

2. Definición.

El CC no la define.

Remisión: modo de extinguir las obligaciones, que consiste en el perdón que de la deuda le hace el acreedor al deudor.

3. Clases de remisión.

- 1) Por acto entre vivos y testamentaria.
- 2) Expresa y tácita.
- 3) Total y parcial.

REMISIÓN POR ACTO ENTRE VIVOS Y TESTAMENTARIA.

- Por acto entre vivos: está sujeta a las reglas de las donaciones entre vivos, incluida la insinuación.
- Por testamento: es un legado de condonación al deudor, el cual debe aceptarlo una vez deferida la asignación.

Naturaleza jurídica de la remisión por acto entre vivos.

1. En la doctrina nacional se le considera una convención, por lo que requiere necesariamente de la aceptación del deudor.
2. La remisión es un acto unilateral del acreedor dotado por sí mismo de la eficacia extintiva. Es simplemente un acto de renuncia.

La tesis adecuada es la primera. La ley la asimila a la donación, por lo que el deudor tiene que aceptarla, y mientras no ocurra y no se notifique al acreedor la aceptación, éste puede revocarla.

Capacidad para remitir por acto entre vivos.

Requiere capacidad de disposición (Art. 1652 CC).

REMISIÓN EXPRESA Y REMISIÓN TÁCITA.

- Expresa: la que el acreedor hace en términos formales y explícitos, cumpliendo las solemnidades de las donaciones.
- Tácita: se produce cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el título de la obligación, o lo destruye o cancela, con ánimo de extinguir la deuda (Art. 1654 CC). Estos hechos constituyen una presunción simplemente legal.

Requisitos:

- a) Entrega del título.
- b) Voluntaria.
- c) Hecha por el acreedor.
- d) Hecha al deudor.

4. Toda remisión es gratuita.

Es de la esencia de la remisión su gratuidad, pese a que el Art. 1653 CC da a entender que puede haber remisión onerosa. Si es onerosa, degenera en un acto distinto.

5. Efectos de la remisión.

- Parcial: se extingue la obligación hasta el monto de lo remitido.
- Total: se extingue íntegramente la obligación con todos sus accesorios.

Cuando hay varios codeudores solidarios, la remisión que el acreedor hace a uno de ellos no favorece a los demás (Art. 1518 CC).

6. Remisión de las prendas e hipotecas.

Art. 1654 inc. 2º CC. "La remisión de la prenda o de la hipoteca no basta para que se presuma remisión de la deuda."

5.9 LA CONFUSIÓN.

1. Ideas generales.

Arts. 1567 N° 6 y 1665 a 1669 CC.

2. Concepto.

El Art. 1665 CC no la define, pero señala sus elementos:

Art. 1665 CC. "Cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedor y deudor se verifica de derecho una *confusión* que extingue la deuda y produce iguales efectos que el pago."

Confusión: modo de extinguir las obligaciones que tiene lugar cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una sola persona.

3. Causas que pueden generar la confusión.

- Sucesión por causa de muerte.
- Por acto entre vivos en que el deudor adquiere el crédito en su contra.

4. Confusión parcial.

Art. 1667 CC. "Si el concurso de las dos calidades se verifica solamente en una parte de la deuda, no hay lugar a la confusión, ni se extingue la deuda, sino en esa parte."

5. Obligaciones que pueden extinguirse por este modo.

Cualquier tipo de obligación, de dar, hacer o no hacer, sin que importe su fuente ni las partes. La ley no contempla limitación.

6. Caso de un titular con más de un patrimonio.

Duda: ¿Se produce la confusión cuando un titular de varios patrimonios es acreedor en uno de ellos y deudor en el otro? La doctrina no acepta confusión en este caso. El CC acepta este criterio en el caso del heredero beneficiario (Art. 1669 CC).

7. Situación especial en el caso de existir solidaridad.

Art. 1668 CC. "Si hay confusión entre uno de varios deudores solidarios y el acreedor, podrá el primero repetir contra cada uno de sus codeudores por la parte o cuota que respectivamente les corresponda en la deuda.
Si por el contrario, hay confusión entre uno de varios acreedores solidarios y el deudor, será obligado el primero a cada uno de sus coacreedores por la parte o cuota que respectivamente les corresponda en el crédito."

8. Efectos de la confusión.

Extingue la deuda y produce los mismos efectos que el pago (Art. 1665 CC). Si la obligación estaba garantizada con fianza, ésta se extingue (Art. 1666 CC).

5.10 IMPOSIBILIDAD DE LA EJECUCIÓN Y PÉRDIDA DE LA COSA DEBIDA.

1. Ideas generales.

Arts. 1567 N° 7 y 1670 a 1680 CC.

2. Definición.

Imposibilidad de la ejecución y pérdida de la cosa debida: Es un modo de extinguir las obligaciones provocado por una causa no imputable al deudor, que sucede con posterioridad al nacimiento de la obligación y que hace imposible la prestación.

Fundamento: a lo imposible nadie está obligado. Este principio es general, pese a que el CC lo regula sólo respecto de las obligaciones de dar una especie.

Art. 1670 CC. "Cuando el cuerpo cierto que se debe perece, o porque:

- se destruye,
- deja de estar en el comercio,
- desaparece y se ignora si existe,

Se extingue la obligación; salvo empero las excepciones de los artículos subsiguientes."

Situación análoga en obligaciones de hacer: que el deudor se encuentre en la imposibilidad absoluta y perpetua de ejecutar el hecho debido.

3. Requisitos de este modo de extinguir tratándose de las obligaciones de dar o entregar una especie o cuerpo cierto.

1) Imposibilidad absoluta y definitiva de poder cumplir la obligación.

En las obligaciones de dar o entregar, ello sólo ocurre cuando lo debido es una especie, porque el género no perece (Art. 1510 CC).

Al deudor corresponde la prueba de la cosa debida, si ésta es interpuesta en juicio como una excepción que enerva el cumplimiento en naturaleza de la obligación. Si el deudor no logra probar ese hecho, la ley asume que la cosa subsiste en manos distintas a las del deudor.

2) Imposibilidad fortuita, es decir, no debe ser una imposibilidad o pérdida culpable.

Si la cosa perece por culpa del deudor, la obligación subsiste pero varía de objeto, quedando el deudor obligado al pago del precio de la cosa más indemnización (Art. 1672 CC).

El Art. 1671 CC presume que la pérdida de la cosa es culpable, lo que concuerda con el Art. 1674 CC que carga al deudor con la prueba del caso fortuito.

No se aplican estas reglas si el deudor se ha constituido responsable de todo caso fortuito, o de alguno en particular (Art. 1673 CC).

Quien ha hurtado o robado la cosa no puede alegar pérdida por caso fortuito (Art. 1676 CC).

3) La imposibilidad es posterior al nacimiento de la obligación.

Si es anterior, la obligación carece de objeto o tiene objeto imposible.

4. Cesión de acciones del deudor al acreedor.

Art. 1677 CC. "Aunque por haber perecido la cosa se extinga la obligación del deudor, podrá exigir el acreedor que se le cedan los derechos o acciones que tenga el deudor contra aquellos por cuyo hecho o culpa haya perecido la cosa."

5. En el hecho o culpa del deudor se comprende el de las personas por quienes fuere responsable.

Art. 1679 CC. "En el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las personas por quienes fuere responsable".

6. Responsabilidad del deudor después que ha ofrecido la cosa al acreedor.

Art. 1680 CC. "La destrucción de la cosa en poder del deudor, después que ha sido ofrecida al acreedor, y durante el retardo de éste en recibirla, no hace responsable al deudor sino por culpa grave o dolo."

7. Requisitos de este modo de extinguir las obligaciones de hacer.

No lo trata el CC. Es necesario remitirse a las normas de Código de Procedimiento Civil.

Art. 534 CPC. "A más de las excepciones expresadas en el artículo 464, que sean aplicables al procedimiento de que trata este Título, podrá oponer el deudor la de imposibilidad absoluta para la ejecución actual de la obra debida."

En general, la prestación deviene imposible sólo si no puede ser ejecutada por el acreedor ni por un tercero (a menos que se haya contratado en consideración a la persona misma del deudor)

Existen diversos tipos de imposibilidad³⁸:

- Imposibilidad subjetiva: sólo pesa sobre el deudor mismo. Solo extingue la obligación de hacer cuando el deudor se entiende obligado a efectuar por sí mismo la prestación.
- Imposibilidad objetiva: afecta a cualquier persona y no solo al deudor.
- Imposibilidad transitoria: solo suspende el cumplimiento de la obligación, a menos que el atraso prive al acreedor del beneficio económico perseguido.
- Imposibilidad permanente: extingue la obligación.
- Imposibilidad física: la conducta no se puede realizar por el deudor ni por un tercero.
- Imposibilidad jurídica: por ejemplo, cuando la cosa deviene en ilícita.

³⁸ Sección extraída de Enrique Barros: "La diferencia entre "estar obligado" y "ser responsable" en el Derecho de los Contratos".

- Imposibilidad moral: ocurre cuando el cumplimiento es posible, pero requiere del sacrificio de ciertos bienes del deudor que son irrenunciables, como la salud o la vida.

8. Requisitos de este modo de extinguir en las obligaciones de no hacer.

La excepción del Art. 534 CPC pasa a ser la imposibilidad absoluta de deshacer lo hecho.

5.11 LA PRESCRIPCIÓN.

1. Ideas generales.

Arts. 1567 N° 10 y 2492 a 2524 CC.

2. Clases de prescripción.

- Adquisitiva: modo de adquirir el dominio (Arts. 2498 a 2513 CC).
- Extintiva o liberatoria: modo de extinguir las obligaciones (Arts. 2514 a 2524 CC).

3. Definición.

Prescripción extintiva: modo de extinguir las obligaciones y derechos ajenos, por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante un cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales (Art. 2492 CC).

4. La prescripción sólo extingue la acción, no el derecho ni la obligación correlativa.

Esto es así porque de acuerdo al Art. 1470 N° 2, las obligaciones civiles extinguidas por prescripción pasan a ser naturales.

5. Paralelo entre prescripción adquisitiva y extintiva.

- La adquisitiva es un modo de adquirir el dominio y los demás derechos reales (no los personales); la extintiva es un modo de extinguir las acciones de los derechos ajenos.
- En la adquisitiva, la posesión es requisito sine qua non; en la extintiva no juega ningún rol.

Elementos comunes:

- a) Inactividad de una parte.
- b) Cumplen la función de dar estabilidad a los derechos y relaciones jurídicas.

5.11.1 REGLAS COMUNES A TODA PRESCRIPCIÓN.

1. Toda prescripción debe ser alegada.

2. Toda prescripción puede ser renunciada una vez cumplida.
3. Corre por igual en contra toda clase de personas que tenga la libre administración de lo suyo.

1. Toda prescripción debe ser alegada.

Art. 2493 CC. "El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio."

- Esto es así por el principio de pasividad de los tribunales en materia civil.
- Además, el deudor debe probar en juicio que se encuentran cumplidos los requisitos de la prescripción.
- Finalmente, debe darse al deudor la oportunidad procesal para renunciar a la prescripción.

• Forma de alegar la prescripción.

La adquisitiva sólo puede alegarse como acción mediante la reconvención. La extintiva puede alegarse como acción o excepción.

Como excepción, se puede plantear en cualquier estado de la causa, antes de la citación para oír sentencia (primera instancia) o de la vista de la causa (segunda) (Art. 310 CPC). En el juicio ejecutivo, sólo puede oponerse en el escrito de excepciones.

Se discute si la extintiva puede alegarse como acción, porque no hay ningún derecho del cual pudiera derivar, y porque no tendría utilidad, puesto que el acreedor no está cobrando el crédito. Sin embargo, hoy se estima que basta un interés para que haya acción, y en este caso lo hay: el interés del deudor en ser liberado de la obligación.

• La prescripción debe ser alegada con precisión.

No puede alegarse en términos generales. El deudor debe expresar de un modo preciso el tiempo desde cuándo el plazo de prescripción ha empezado a correr. Así se ha fallado.

• Excepciones a la regla de que toda prescripción debe ser alegada.

En estos casos, el tribunal debe declararla de oficio:

- 1) Prescripción de la acción ejecutiva (Art. 441 CPC). Más que un caso de prescripción, es un caso de caducidad
- 2) Prescripción de la acción penal y de la pena (Art. 102 CP).

2. Toda prescripción puede ser renunciada, pero sólo una vez cumplida.

Así lo establece el Art. 2494 inc. 1º CC. Razones:

- Si se hiciera antes del vencimiento del plazo, la actitud del deudor sería una interrupción natural (Art. 2518 inc. 2º CC).
- Si se aceptara la renuncia anticipada, pasaría a ser cláusula de estilo en todos

los contratos, perdiéndose el efecto estabilizador de derechos.

Renuncia expresa: se hace en términos formales y explícitos.

Renuncia tácita: el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del acreedor (Art. 2494 inc. 2º CC).

- **Capacidad para renunciar la prescripción.**

Art. 2495 CC. "No puede renunciar la prescripción sino el que puede enajenar."
--

- **Efectos de la renuncia.**

Es de efectos relativos; no alcanza a terceros obligados, por lo tanto no afecta al fiador (Art. 2496 CC). El principio es de alcance amplio.

3. La prescripción corre igual contra toda clase de personas.

Así lo establece el Art. 2497 CC, que tiene fundamento constitucional en la igualdad ante la ley.

- **Excepciones a la regla de la igualdad.**

Se refiere a las personas respecto de las cuales la prescripción se suspende (Art. 2509 CC).

5.1.1.2 REQUISITOS DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA.

1. Acción prescriptible.
2. Inactividad de las partes.
3. Tiempo de prescripción.

5.1.1.2.1 ACCIÓN PRESCRIPTIBLE.

Regla general: todas las acciones son prescriptibles.

Excepciones:

- a) Acción de partición (Art. 1317 CC).
- b) Acción para reclamar el estado civil de padre, madre o hijo (Art. 320 CC).
- c) Acción de demarcación y cerramiento (por ser una manifestación del dominio, motivo por el cual se encontraría en el mismo caso la acción de precario).
- d) Acciones por obras que corrompan el aire o lo hagan conocidamente dañoso. (Art. 937 CC)

5.11.2.2 INACTIVIDAD DE LAS PARTES.

Acreedor: no debe haber requerido judicialmente al deudor exigiéndole el cumplimiento de la obligación.

Deudor: actitud pasiva que no interrumpa la prescripción.

Interrupción de la prescripción extintiva.

Es el hecho impeditivo de la prescripción que se produce al cesar la inactividad del acreedor (interrupción civil) o del deudor (interrupción natural). (Art. 2518 CC)

- **Interrupción natural.**

Art. 2518 inc. 2º CC. "Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente."

La norma es amplia: cualquier acto que suponga reconocimiento de la deuda. Debe ser antes de que se cumpla el plazo; si es después, es renuncia tácita. Algunos autores opinan que se requiere capacidad de disposición, al igual que en la renuncia.

- **Interrupción civil.**

Art. 2518 inc. final CC. "Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvo los casos enumerados en el artículo 2503."

Requisitos para que exista interrupción civil.

(1) Debe haber demanda judicial.

El Art. 2518 inc. final CC es claro. Pero ha habido dudas sobre el alcance de la expresión "demanda judicial". La doctrina y jurisprudencia están divididas:

- a) Cualquier gestión judicial es suficiente. Ej. Gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, medidas prejudiciales.
- b) Debe tratarse de la demanda a que se refiere el Art. 254 CPC.

Para que la demanda interrumpa la prescripción, debe haber conexión directa entre la acción ejercida y la acción de cuya prescripción se trata.

(2) Notificación de la demanda.

La notificación debe hacerse antes del vencimiento del plazo de prescripción, para no incurrir en lo dispuesto en el art. 2503 N°1.

Ahora bien, el momento exacto en que se produce la interrupción de la prescripción ha sido objeto de controversia tanto doctrinaria como jurisprudencial, habiendo quienes postulan que la notificación de la demanda es el hito que marca la interrupción, mientras que otro sector señala que basta la mera presentación de la demanda para lograr ese efecto.

Los argumentos de los autores que postulan que la notificación es requisito para la interrupción de la prescripción son:

- La notificación de la demanda determina la existencia de un juicio (art. 1603 inc. final) y desde ahí puede entenderse que el acreedor ha iniciado un procedimiento tendiente a exigir su crédito, toda vez que previo a la notificación solo hay un acto unilateral del acreedor desconocido por el deudor.
- El art. 100 de la Ley N°18.092 que dicta normativa sobre la letra de cambio y pagaré dispone que la prescripción se entenderá interrumpida "sólo respecto del obligado a quien se notifique la demanda judicial de cobro de la letra, o la gestión judicial necesaria o conducente para deducir dicha demanda o preparar la ejecución". Para este sector dicho artículo contendría el principio general en materia de interrupción.
- La consecuencia de una notificación que no reúna los requisitos exigidos por el legislador es la no interrupción de la prescripción (art. 2503 N°1 en relación al art. 2518), de modo que la falta de notificación debería tener la misma consecuencia.
- No hay norma alguna que establezca que los efectos de la demanda deben retrotraerse al momento de su interposición.

La Corte Suprema ha hecho suya esta argumentación en las sentencias causas Rol N°99.477-2020, 6.958-2021, 25.484-2021, 71.667-2021, 75.995-2021, 7.308-2022, 57.418-2022, 251.917-2023, entre otras.

La doctrina que considera que la sola interposición de la demanda interrumpe la prescripción se basa en las siguientes consideraciones:

- El art. 2492 permite entender a la prescripción extintiva como una sanción para el acreedor negligente ("por no haberse ejercido dichas acciones"), de modo que al ejercer la acción (interponer la demanda), el acreedor sale de su estado de pasividad y manifiesta su voluntad de perseguir el cumplimiento de la obligación.
- El art. 2503 alude a intentar la demanda, no estableciendo como exigencia la notificación de la misma para lograr el efecto interruptivo.
- El Código Civil francés (que inspiró la dictación de nuestro Código Civil) exige en términos expresos la notificación de la demanda. En cambio, Bello optó por exigir únicamente una demanda "intentada" por el acreedor.
- Exigir que la notificación deba hacerse dentro del plazo de prescripción implica restar parte del plazo que el legislador otorga al acreedor para que se produzca el efecto interruptivo.
- El deudor puede desplegar maniobras destinadas a eludir la notificación, evitando que esta se produzca antes del vencimiento del plazo de prescripción, lo cual va en claro menoscabo al acreedor.

La Corte Suprema ha adherido a este criterio en menor medida, lo cual puede apreciarse en las sentencias causas Rol N°6.900-2015, 175.332-2023.

(3) Que no se haya producido alguna de las situaciones previstas en el artículo 2503.

- 1.º Si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal;
- 2.º Si el recurrente desistió expresamente de la demanda o se declaró abandonada la instancia;
- 3.º Si el demandado obtuvo sentencia de absolución.

Efectos de la interrupción.

Se pierde todo el tiempo anterior de prescripción. La regla es que los efectos sean relativos (Art. 2519 CC). Excepciones:

- Solidaridad (Art. 2519 parte final CC).
- Obligaciones indivisibles (Art. 1529 CC).

La interrupción de la prescripción de la obligación principal interrumpe la prescripción de la obligación accesoria.

Esto se apoya en el Art. 2516 CC.

Ej. La interrupción de la prescripción de la obligación principal interrumpe la prescripción de la acción hipotecaria.

Pero se ha fallado lo contrario en base al efecto relativo de la interrupción.

5.11.2.3 TIEMPO DE PRESCRIPCIÓN.

En toda prescripción extintiva, el tiempo se cuenta desde que la obligación se hizo exigible (Art. 2514 inc. 2º CC).

5.11.2.3.1 PRESCRIPCIONES DE LARGO TIEMPO.

1. Acciones personales ordinarias: 5 años desde que la obligación se hizo exigible (Art. 2515 inc. 1º CC).

2. Acciones ejecutivas: 3 años desde que la obligación se hizo exigible (Art. 2515 inc. 1º CC). Esta regla tiene algunas excepciones en que la ley ha fijado plazos especiales.

Hay que tener presente:

- Transcurridos 3 años, la acción ejecutiva se transforma en ordinaria por 2 años más (Art. 2515 inc. 2º CC).
- Puede ser declarada de oficio.
- El solo reconocimiento por el deudor de la vigencia de la deuda no importa renuncia de la prescripción de la acción ejecutiva. Así se ha fallado.

Prescripción de las acciones accesorias.

Art. 2516 CC. "La acción hipotecaria, y las demás que proceden de una obligación accesoria, prescriben junto con la obligación a que acceden."

En consecuencia, las acciones provenientes de las cauciones no tienen plazo de prescripción.

3. Prescripciones de acciones reales de dominio y de herencia.

Art. 2517 CC. "Toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho."

Ello explica que:

- La acción reivindicatoria no tenga plazo propio.
- La acción de petición de herencia prescribe en 5 o 10 años, que son los plazos

de prescripción adquisitiva del derecho de herencia.

4. Prescripciones especiales en el caso de las limitaciones del dominio.

- **Usufructo:**

1. La acción para reclamar el derecho poseído por un tercero se puede intentar en cualquier tiempo mientras el tercero no lo haya adquirido por prescripción adquisitiva.

2. Si el usufructuario reclama el derecho al nudo propietario, la cuestión es más compleja, porque el Art. 806 CC señala que el usufructo se extingue por prescripción.

- El derecho se extingue por prescripción extintiva si el usufructuario no reclama su derecho.
- No basta el simple no uso. El usufructuario tiene el dominio sobre su derecho, dominio que no pierde mientras otra persona no lo haya ganado por prescripción adquisitiva.

- **Uso y habitación:** se aplican las reglas del usufructo.

- **Servidumbres:** si el titular las deja de gozar por 3 años, se produce la prescripción extintiva (Art. 885 N° 5 CC).

Suspensión de la prescripción extintiva de largo tiempo Art. 2520 CC).

La prescripción que extingue las obligaciones se suspende en favor de:

1. Los menores, dementes, sordos o sordomudos que no se pueden dar a entender claramente, y todos los que estén bajo potestad paterna, o bajo tutela o curaduría.
 2. Mujer casada en sociedad conyugal mientras dure esta.
- “Transcurridos diez años no se tomarán en cuenta las suspensiones mencionadas en el inciso precedente”.
 - La jurisprudencia ha dicho que la suspensión se aplica a la prescripción extintiva ordinaria, no a la ejecutiva.

5.11.2.3.2 PRESCRIPCIONES DE CORTO TIEMPO.

Son casos especiales que constituyen excepciones a la regla del Art. 2515 CC:

1. PRESCRIPCIONES DE 3 AÑOS.

Art. 2521 inc. 1º CC. “Prescriben en tres años las acciones a favor o en contra del Fisco y de las Municipalidades provenientes de toda clase de impuestos.”

- Se refiere sólo a acciones relativas a impuestos.
- El CT y otras leyes contemplan normas sobre prescripción de ciertas obligaciones tributarias, que deben aplicarse con preferencia al CC por ser especiales.

2. PRESCRIPCIONES DE DOS AÑOS (PRESCRIPCIÓN DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES LIBERALES).

Art. 2521 inc. 2º CC. "Prescriben en dos años los honorarios de jueces, abogados, procuradores; los de médicos y cirujanos; los de directores o profesores de colegios y escuelas; los de ingenieros y agrimensores, y en general, de los que ejercen cualquiera profesión liberal."

2 requisitos:

- a) Que se trate de profesionales liberales.
- b) Que correspondan a honorarios profesionales (no si tienen contrato de trabajo).

Se cuenta desde que la obligación de pagar los honorarios se hizo exigible, y si se trata de servicios prolongados, desde que se terminan de prestar los servicios, a menos que se hayan fijado fechas para su pago.

3. PRESCRIPCIONES DE UN AÑO.

Art. 2522 CC. "Prescribe en un año la acción de los mercaderes, proveedores y artesanos por el precio de los artículos que despachan al menudeo. La de toda clase de personas por el precio de servicios que se prestan periódica o accidentalmente; como posaderos, acarreadores, mensajeros, barberos, etc."

"Mercader": comerciante. "Despachar": vender. "Al menudeo": por menor. El inc. 2º no es taxativo. Lo importante es lo accidental o periódico del servicio.

Las prescripciones de corto tiempo de los artículos 2521 y 2522 no se suspenden.

Así lo establece el Art. 2523 inc. 1º CC.

Intervención de las prescripciones de corto tiempo.

Art. 2523 incs. 2º y final. "Interrúmpense:
 1.º Desde que interviene pagaré u obligación escrita, o concesión de plazo por el acreedor;
 2.º Desde que interviene requerimiento.
 En ambos casos sucede a la prescripción de corto tiempo la del artículo 2515."

El efecto especial del inc. final se denomina interversión de la prescripción. En que no se interrumpe sino que se transforma en una prescripción de largo tiempo.

El requerimiento del N°2 es extrajudicial. Si hay demanda judicial, se aplica el Art. 2518 CC.

5.1.1.2.3.3 PRESCRIPCIONES ESPECIALES.

Art. 2524 CC. "Las prescripciones de corto tiempo a que están sujetas las acciones especiales que nacen de ciertos actos o contratos, se mencionan en los títulos respectivos, y corren también contra toda persona; salvo que expresamente se establezca otra regla."

- Son prescripciones de corto tiempo (menos de 5 años).
- No se suspenden, salvo situaciones excepcionales. Ej. Art. 1692 inc. 2º CC.
- No se les aplican las reglas especiales de interrupción del Art. 2523 CC.

Casos especiales de acciones especiales de corto tiempo, que se suspenden.

- Acción rescisoria.
- Acción de reforma de testamento.

5.1.1.3 OTROS ASPECTOS RELEVANTES de A LA PRESCRIPCIÓN

CLÁUSULAS MODIFICATORIAS DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN

La ley es la que fija el plazo para prescribir. La pregunta es si las partes pueden modificarlos, lo cual, a falta de norma expresa que regule el asunto, resulta discutible.

1. Las partes no pueden ampliar los plazos, porque es contrario al orden público, pero sí acortarlos. Así se contempla expresamente en el pacto comisorio y el pacto de retroventa.

Tal es la opinión del profesor Abeliuk, quien opina que permitir a las partes ampliar los plazos afectaría el interés social subyacente a la estabilización de las relaciones jurídicas, y equivaldría a una renuncia anticipada de la prescripción. Esta argumentación no se aplicaría para el caso contrario, y por esa razón no ve inconvenientes en la reducción de los plazos.

2. Este último argumento es débil, porque el CC permite ampliar o restringir los plazos en un caso: el de la acción redhibitoria.

Los plazos de prescripción son un equilibrio entre dos intereses de orden público:

- Incertidumbre sobre el ejercicio de los derechos
- No coartar ese ejercicio más de lo razonable. Todo acortamiento o prolongación afectaría este equilibrio.

La tendencia de la legislación comparada es no permitir las cláusulas modificatorias de los plazos.

PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD

Semejanza: en ambas se produce la pérdida de un derecho como consecuencia de

la inactividad de su titular durante un determinado plazo.

Diferencia: la caducidad significa que el legislador ha señalado un término final, sin atender a lo que haga el obligado. La existencia del derecho está limitada desde un principio a un plazo prescrito de antemano, que es fatal.

1. Necesidad de alegarla:
 - La prescripción debe ser alegada;
 - la caducidad opera por el solo vencimiento del plazo.
2. Interrupción y suspensión:
 - Los plazos de caducidad son fijos e invariables, y no se le aplica la interrupción ni la suspensión,
 - En la prescripción opera la interrupción y la suspensión.
3. Extinción del derecho:
 - La prescripción no extingue el derecho, sino la acción;
 - la caducidad extingue el derecho.
4. Renuncia:
 - La prescripción es renunciable;
 - La caducidad no.

Caducidad en el Código Civil.

No está especialmente regulada y no está en la enumeración del Art. 1567 CC. Pero hay casos de acciones que caducan. Ej. Plazos para impugnar la paternidad.

CAPÍTULO 6. DE LA PRELACIÓN DE CRÉDITOS.

El deudor responde de sus obligaciones con todo su patrimonio (salvo bienes inembargables): derecho de prenda general de los acreedores (Art. 2465 CC).

Esto se complementa con los Arts. 2469 (derecho a que se rematen los bienes del deudor) y 2468 CC (acción pauliana).

Ahora bien, en el caso de que un mismo sujeto tenga varios acreedores, ¿de qué forma concurren al pago de sus respectivos créditos en el patrimonio del deudor? Este es el objeto de la regulación de la prelación de créditos

6.1 GENERALIDADES.

1. Explicación de por qué se trata esta materia al final

No tiene relación de continuidad con ninguna materia tratada.

2. Concepto e importancia de la prelación de créditos

Prelación de créditos: conjunto de reglas legales que determinan el orden y forma en que deben pagarse los diversos acreedores de un deudor.

Importancia:

- 1) Cuando los bienes del deudor no son suficientes para pagar todas sus obligaciones.
- 2) Rigen cuando, en una ejecución, dos o más acreedores pretenden ser pagados en forma preferente con los bienes embargados, invocando prenda o hipoteca.

3. Concurrencia de los acreedores

Cuando los bienes del deudor no son suficientes, en teoría hay 3 formas de pagar:

- 1.** Principio de la prioridad: según fechas.
- 2.** Principio de igualdad: pagar a todos en proporción.
- 3.** Dando preferencia a ciertos créditos.

4. Principio de la igualdad y causas de preferencia

La regla general en el CC es el principio de igualdad. Pero, por excepción, ciertos créditos tienen preferencia.

Art. 2470 inc. 1º CC. "Las causas de preferencia son solamente el privilegio y la hipoteca."

Privilegio: favor concedido por la ley, en atención a la calidad del crédito, que permite a su titular pagarse antes que los demás acreedores.

Resulta criticable la distinción entre privilegio e hipoteca, pues si la razón es que la hipoteca da un derecho real y el privilegio uno personal, no se justifica que la prenda constituya un privilegio.

5. Fundamento de las preferencias

No hay una razón única, cada caso tiene su explicación. Pueden ser el fomento del crédito, razones de humanidad, razones económicas o razones sociales.

6. Clasificación de las preferencias

1. Privilegios e hipoteca.

2. Preferencias generales y especiales:

Generales: afectan a todos los bienes del deudor, de cualquier naturaleza. No se ejerce sobre determinados bienes. Son los créditos de 1ª y 4ª clase.

Especiales: afectan a determinados bienes del deudor. Son los de 2ª y 3ª clase.

3. Clases:

1ª clase: créditos privilegiados (Art. 2472 CC).

2ª clase: créditos privilegiados (Art. 2474 CC).

3ª clase: créditos hipotecarios (Art. 2477 CC).

4ª clase: créditos privilegiados (Art. 2481 CC).

5ª clase: créditos valistas, que no tiene preferencia (Art. 2489 CC).

7. Características de las preferencias

1. Son inherentes a los créditos para cuya seguridad se han establecido y pasan con ellos a las personas que los adquieren por cesión, subrogación u otra forma (Art. 2470 inc. 2º CC).

2. Constituyen un beneficio especial para determinados acreedores.

3. Son excepcionales. La regla general es la igualdad de los acreedores. No hay más causales de preferencia que el privilegio y la hipoteca. Son de interpretación estricta y no admiten analogías.

4. Siempre son legales. Las partes no pueden crear preferencias.

5. Son renunciables, pues miran al interés del acreedor y no está prohibida su renuncia.

6. Tienen un carácter indivisible: la totalidad y cada una de las partes del(los) objeto(s) afectado(s) responde a la satisfacción total de la preferencia, y el crédito preferente o fracción del mismo se beneficia con la garantía.

Ámbito de la preferencia.

Ampara no sólo el capital, sino también los respectivos intereses (Art. 2491 CC).

6.2 LOS CRÉDITOS QUE GOZAN DE PREFERENCIAS

6.2.1 PRIMERA CLASE DE CRÉDITOS

ENUMERACIÓN

Art. 2472 CC³⁹. La primera clase de créditos comprende los que nacen de las causas que en seguida se enumeran:

1. Las costas judiciales que se causen en interés general de los acreedores; Alcances: acción pauliana (no se incluyen) y acción ejecutiva (preferencia respecto del crédito mismo).
2. Las expensas funerales necesarias del deudor difunto; No incluye gastos funerales de la familia.
3. Los gastos de enfermedad del deudor. Si la enfermedad hubiere durado más de seis meses, fijará el juez, según las circunstancias, la cantidad hasta la cual se extienda la preferencia;
4. Los gastos en que se incurra para poner a disposición de la masa los bienes del deudor, los gastos de administración del procedimiento de liquidación, de realización del activo y los préstamos contratados por el liquidador para los efectos mencionados; Fundamento: facilita la labor del liquidador.
5. Las remuneraciones de los trabajadores, las asignaciones familiares, cotizaciones adeudadas e indemnización sustitutiva de aviso previo en caso de término del contrato de trabajo por sentencia en procedimiento de liquidación; Fundamento: protección del trabajador.
6. Las cotizaciones adeudadas a organismos de Seguridad Social o que se recauden por su intermedio, para ser destinadas a ese fin, como asimismo, los créditos del fisco en contra de las entidades administradoras de fondos de pensiones por los aportes que aquél hubiere efectuado de acuerdo con el inciso tercero del artículo 42 del decreto ley Nº 3.500, de 1980;
7. Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia durante los últimos tres meses; Facilita al deudor la adquisición de artículos necesarios para subsistir.
8. Las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral que les correspondan a los trabajadores, que estén devengadas a la fecha en que se hagan valer y hasta un límite de tres ingresos mínimos mensuales por cada año de servicio y fracción superior a seis meses por cada trabajador con un límite de once años. Por el exceso, si lo hubiere, se considerarán valistas. Asimismo la indemnización establecida en el párrafo segundo del número 4 del artículo 163 bis del Código del Trabajo, con los mismos límites pero calculados de manera independiente;
9. Los créditos del fisco por los impuestos de retención y de recargo. Son aquellos en que el sujeto pasivo no soporta el gravamen en su patrimonio, sino que lo traslada a un tercero.

³⁹ Artículo modificado por la ley 20.720.

CARACTERÍSTICAS:

- 1.** Son créditos privilegiados (Art. 2471 CC).
- 2.** Afectan a todos los bienes del deudor (privilegio general, Art. 2473 inc. 1º CC).
- 3.** No pasa el privilegio contra terceros poseedores, privilegio personal, Art. 2473 inc. 2º CC).
- 4.** Prefieren en el orden de su numeración (Art. 2473 inc. 1º CC).
- 5.** Se pagan con preferencia a los comprendidos en las otras clases.
Pero los acreedores prendarios e hipotecarios se pagan con preferencia sobre los bienes dados en prenda o hipoteca, a menos que los demás bienes no alcancen para cubrir la primera clase (Arts. 2476 y 2477 CC). Este último hecho debe ser probado por quien invoca el crédito de primera clase. El banco tiene preferencia sobre el Fisco respecto del producto del bien hipotecado, salvo que se trate de contribuciones de bienes raíces.
- 6.** Caso del deudor declarado en quiebra: Aplicación de arts. 147 y ss LQ.
- 7.** Ciertas leyes especiales han creado "superpreferencias": créditos que deben ser pagados antes que cualquier otra obligación del deudor. Pero la Ley 19.250 agregó al Art. 148 LQ un inciso final, que establece que los créditos de la primera clase prefieren a todo otro crédito privilegiado establecido por leyes especiales.

6.2.2. SEGUNDA CLASE DE CRÉDITOS

ENUMERACIÓN

Art. 2474 CC. A la segunda clase de créditos pertenecen los de las personas que en seguida se enumeran:

1. El posadero sobre los efectos del deudor (presunción) introducidos por éste en la posada, mientras permanezcan en ella y hasta concurrencia de lo que se deba por alojamiento, expensas y daños.
2. El acarreador o empresario de transportes sobre los efectos acarreados (presunción), que tenga en su poder o en el de sus agentes o dependientes, hasta concurrencia de lo que se deba por acarreo, expensas y daños, con tal que dichos efectos sean de la propiedad del deudor. Se presume que son de la propiedad del deudor los efectos introducidos por él en la posada, o acarreados de su cuenta.
3. El acreedor prendario sobre la prenda: La prenda da al acreedor prendario es un derecho real que le permite perseguir la cosa pignorada en poder de quién se encuentre, para pagarse preferentemente con su producto.

- Debe agregarse otros créditos que gozan de esta preferencia en virtud de leyes especiales. Ej. Derecho legal de retención sobre bienes muebles declarado judicialmente (Art. 546 CPC).

CARACTERÍSTICAS

1. Son privilegios especiales: afectan a bienes determinados, y si el acreedor no se alcanza a pagar con ellos, es valista en el exceso.
2. Se pagan con preferencia a los demás créditos, salvo respecto de los de primera clase.

Nueva realidad creada con las prendas especiales sin desplazamiento.

Abre la posibilidad de dar una misma cosa en prenda a varios acreedores.

1. Prenda industrial: los acreedores prefieren por el orden de sus inscripciones. Si la especie dada en prenda está en un predio arrendado, prefiere el acreedor prendario al arrendador (que tiene derecho de retención), salvo que el arrendamiento conste por escritura pública al momento de constituir la prenda.
2. Prenda agraria: la ley no lo resuelve, pero como se requiere consentimiento del primer acreedor para constituir otra, se concluye que concurren a prorrata. Otros estiman que prefieren en el orden de sus inscripciones. El acreedor prendario prefiere al arrendador.
3. Prenda sin desplazamiento: el deudor no puede gravar ni enajenar lo dado en prenda sin consentimiento del acreedor. Si el acreedor consiente, concurren a prorrata.

6.2.3 TERCERA CLASE DE CRÉDITOS

ENUMERACIÓN

- Créditos Hipotecarios (Art. 2477 CC)
- Inmuebles respecto de los cuales se ha declarado judicialmente el derecho legal de retención, siempre que el decreto esté inscrito;
- Crédito del aviador en el contrato de avío minero.

CARACTERÍSTICAS

1. Constituyen créditos preferentes, pero no privilegiados.
2. Otorgan una preferencia especial, que sólo puede hacerse valer sobre la finca hipotecada. Si ésta no alcanza para la totalidad del crédito, el exceso es valista.
3. Los créditos hipotecarios se pagan con el producto de la finca hipotecada con preferencia a todos los demás créditos del deudor. Pero si hay acreedores de

primera clase y los demás bienes del deudor no son suficientes para cubrir sus créditos, el déficit se hace efectivo en las fincas hipotecadas.

4. Los créditos hipotecarios prefieren en el orden de sus fechas de inscripción.

5. A cada finca gravada puede abrirse, a petición de los acreedores, un concurso particular para que se les pague inmediatamente con ella, sin necesidad de esperar las resultas del concurso general (afianzando el pago de los créditos de primera clase).

CÓMO SE ALEGA LA PREFERENCIA HIPOTECARIA.

1. Tercería de prelación en un juicio ejecutivo iniciado por un tercero que embargue el bien hipotecado
2. Tercería de prelación en un juicio ejecutivo iniciado por otro acreedor hipotecario de grado posterior,
3. En concurso particular de acreedores hipotecarios,
4. si el deudor está en quiebra, los acreedores deben verificar sus créditos en la quiebra.

BIENES SOBRE LOS CUALES RECAE LA PREFERENCIA HIPOTECARIA.

Por ser una preferencia especial, se hace efectiva sobre el precio que resulte de la subasta de la finca. Incluye:

- Inmuebles por destinación o adherencia,
- Frutos,
- Aumentos y mejoras de la cosa hipotecada.

Por comprender bienes que por naturaleza son muebles, puede generarse conflicto si sobre ellos se constituyó prenda sin desplazamiento:

- En la prenda agraria, prefiere el acreedor prendario.
- En la industrial, la ley no resuelve, y se plantean diversas soluciones.

6.2.4 CUARTA CLASE DE CRÉDITOS

ENUMERACIÓN

Art. 2481 CC. La cuarta clase de créditos comprende:

1. Los del Fisco contra los recaudadores y administradores de bienes fiscales; Causa: recaudación.

2. Los de los establecimientos nacionales de caridad o de educación, y los de las municipalidades, iglesias y comunidades religiosas, contra los recaudadores y administradores de sus fondos; (Personas jurídicas de derecho pública distintas del fisco).

3. Los de las mujeres casadas (herederos o cesionarios), por los bienes de su propiedad que administra el marido, sobre los bienes de éste o, en su caso, los que tuvieren los cónyuges por gananciales; (a la disolución de SC o RPG).

Bienes que comprende: se discute si sólo los bienes con cargo a recompensa o si también los bienes propios.

La mujer: debe alegar el privilegio y probar la existencia de bienes del marido.

4. Los de los hijos sujetos a patria potestad, por los bienes de su propiedad que fueron administrados por el padre o la madre, sobre los bienes de éstos.

El hijo debe alegar el privilegio y probar cuáles son los bienes que han sido administrados.

5. Los de las personas que están bajo tutela o curaduría contra sus respectivos tutores o curadores;

Objeto: defender al pupilo de una administración fraudulenta de su guardador. También debe alegarse y probarse. No procede respecto de curadurías de bienes.

6. Los de todo pupilo contra el que se casa con la madre o abuela, tutora o curadora, en el caso del artículo 511 (tácitamente derogado).

7. Privilegio por expensas comunes de una unidad que forme parte de un condominio. Es un crédito de cuarta clase que prefiere a todos los demás de su misma clase (no por la fecha de su causa), y sólo se hace efectivo sobre la unidad del propietario moroso.

CARACTERÍSTICAS

1. Constituyen un privilegio de carácter general.

2. Prefieren entre sí según las fechas de sus respectivas causas.

3. No dan derecho de persecución contra terceros.

4. Sólo se hacen efectivos después de cubiertos los créditos de las tres primeras clases.

5. En general, están destinados a proteger a una persona cuyos bienes son administrados por otra.

DISTINCIÓN ENTRE LOS DIFERENTES CRÉDITOS DE CUARTA CLASE.

1. Los de ciertas personas en contra de quienes administran sus bienes (Nº 1, 2 y 3).

2. Los de los incapaces en contra de sus representantes legales (Nº 4 y 5).

6.2.5 QUINTA CLASE DE CRÉDITOS

ENUMERACIÓN

Art. 2489 CC. La quinta y última clase comprende los créditos que no gozan de preferencia.

CARACTERÍSTICAS

Los créditos de la quinta clase se cubrirán a prorrata sobre el sobrante de la masa concursada, sin consideración a su fecha.

Pactos de subordinación

Como se vio anteriormente, según el artículo 2489 CC entre los créditos valistas o "**quirografarios**" no existen preferencias, por lo que cada acreedor sólo podrá cubrir su crédito a prorrata respecto a los otros acreedores, y sólo sobre el sobrante de la masa concursada, es decir, sólo dentro del remanente del derecho de prenda general del deudor. Sin embargo, tal y cómo lo especifica el mismo precepto legal, los acreedores sin preferencias pueden celebrar pactos para establecer preferencias de cobro entre los mismos. Estos se conocen como "pactos de subordinación".

Art 2489 inciso tercero: *"Sin perjuicio de lo anterior, si entre los créditos de esta clase figuraren algunos subordinados a otros, éstos se pagarán con antelación a aquéllos."*

Define además, en su inciso cuarto, a la subordinación de créditos como: *"(...) un acto o contrato en virtud del cual uno o más acreedores de la quinta clase aceptan postergar, en forma total o parcial, el pago de sus acreencias en favor de otro u otros créditos de dicha clase, presentes o futuros. La subordinación también podrá ser establecida unilateralmente por el deudor en sus emisiones de títulos de crédito. En este último caso, y cuando sea establecida unilateralmente por el acreedor que acepta subordinarse, será irrevocable."*

La subordinación es un acto solemne, pues tanto su establecimiento como su término anticipado deberán constar en escritura pública o **instrumento privado firmado ante notario y agregado al registro público (protocolizado)**.

Para que el pacto se perfeccione con respecto al deudor, será necesario que éste concurra al acto o contrato que lo acepte por escrito con posterioridad. También se entenderá perfecta con una notificación notarial en la que se exhiba el documento celebrado por los acreedores.

El incumplimiento de la subordinación dará al acreedor vulnerado el derecho a demandar la indemnización de perjuicios en contra del deudor, y a éste la acción de reembolso en contra del acreedor que recibió el pago en inobservancia de la subordinación.

Por último, cabe señalar que la subordinación es transferible y transmisible. Así, el mismo art. 2489 en su inciso final reza:

"La subordinación obligará a los cesionarios o herederos del acreedor subordinado y el tiempo durante el cual se encuentre vigente no se considerará para el cómputo de la prescripción de las acciones de cobro del crédito."

CAPÍTULO 7. ANEXOS.

ANEXO I: ALCANCE DE LA ASIMILACIÓN DE LA CULPA GRAVE AL DOLO

Respecto del art. 44 inc. 2ª segunda parte, el alcance de la equivalencia entre la culpa grave al dolo, es discutido en doctrina.

- Respecto del art. 1558, es uno de los casos en que existe unanimidad en la doctrina (ALESSANDRI, Arturo. Teoría de las obligaciones. Editorial Ediar-Conosur. Reimpresión. p. 96).
- Sin embargo existe discusión respecto a si esta mal llamada "equivalencia" tendría otros alcances, como por ejemplo, si se puede o no condonar anticipadamente la culpa grave (el dolo no se puede en virtud del art. 1465), siendo la posición mayoritaria, que no es posible.
- También se discute si se presume o no la culpa grave, o si por el contrario debería probarse al igual que el dolo (art. 1459), siendo la posición mayoritaria que, ésta se presume y no debe probarse, por cuando a pesar de "equivaler", no son una misma cosa.
- Finalmente también se discute si en caso de culpa grave contractual cometida por dos o más personas, se aplicaría la disposición del art. 2317 inc. 2º, siendo mayoritaria la posición afirmativa

Existe abundante literatura sobre el tema. Ver cualquier manual de derecho de obligaciones. En materia contractual: BANFI, Cristián. La asimilación de la culpa grave al dolo en la responsabilidad contractual, Santiago, Ed. LexisNexis, 2003.

ANEXO II: TEORÍA UNITARIA DEL DOLO

Argumentos de la doctrina que sustenta la teoría unitaria del dolo:

1. El dolo está definido en el título preliminar, el que tiene aplicación general.
2. En todas las variantes del dolo siempre es necesaria la intención.
3. Siempre produce efectos, ya sea viciando el acto o haciendo responsable a quien actuó con dolo.
4. En todos los casos existen reglas comunes.
 - a. Por regla general debe probarse.
 - i. Excepto presunciones de dolo.
 1. Albacea que lleva a efecto disposiciones testamentarias contrarias a la ley.
 2. Muerte presunta.
 3. 280 CPC.
 4. Entre otras.
 - b. No se puede condonar anticipadamente: Objeto ilícito 1465.
 - c. Se aprecia en concreto.
 - d. Nadie puede aprovecharse de su propio dolo.

ANEXO III: RESPECTO DEL INCUMPLIMIENTO ESENCIAL:

En la doctrina chilena, las posiciones son más numerosas que la de entender el cumplimiento esencial o no esencial de la obligación como requisito de la acción resolutoria. Podemos clasificar a estas posiciones doctrinarias en aquellas que dicen que

cualquier incumplimiento autoriza el ejercicio de tal acción y otras que exigen un incumplimiento calificado (cuyas doctrinas modernas, ocupan este concepto contemplado en la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías).

La doctrina minoritaria, que establece que cualquier incumplimiento permite resolver un contrato, es sustentada principalmente por Alessandri, Meza Barros y Somarriva. Así, Alessandri nos dice que "como el art. 1489 no distingue de qué naturaleza debe ser el incumplimiento, cualquiera de las obligaciones contraídas, una vez infringida importa el cumplimiento de tal condición. Aplicando el conocido aforismo jurídico de que donde la ley no distingue no le es lícito al hombre distinguir, hay que llegar a la conclusión de que cualquiera que sea la obligación infringida importa la realización de la condición resolutoria" (ALESSANDRI, Arturo. Teoría de las obligaciones. Ed. Ediar-Conosur. 1988. p. 199-198).

Entre aquellas doctrinas que exigen un incumplimiento "calificado", existen varios criterios:

a) Por una parte Abeliuk, considera que el mero incumplimiento no autoriza a resolver el contrato. Afirma que la resolución solo procede por el incumplimiento de obligaciones "principales" y no por las accesorias o secundarias. Esto se confirmaría por cuanto la condición resolutoria tácita (CRT) procede solo en contratos bilaterales, es decir, procedería la acción resolutoria, respecto de aquellas obligaciones en que existe una reciprocidad: ej. precio y entrega; renta y goce de la cosa, etc. (ABELIUK, Rene. Las Obligaciones. Stgo. Editorial Jurídica, 1983, p. 344.). Así opinó inicialmente Fueyo Laneri.

b) Por otra parte, Claro Solar, considera que el incumplimiento debe ser solo de obligaciones principales, y no de aquellas accesorias o secundarias. Pero a diferencia de Abeliuk, esto se determina por la significación de la obligación (que no sea incumplimiento insignificante) y que cause un perjuicio apreciable (Explicaciones de derecho Civil y Comparado. Volumen 10. Stgo. Editorial nacimiento. p. 191 y 193).

c) Otros autores, creen para distinguir cual cumplimiento es el requisito de la acción de resolución se debe atender al concepto de "incumplimiento esencial", según la clasificación del art 1444 del Código Civil, en cuanto a los elementos de los contratos (Rodríguez, Pablo. "Sobre la excepción de contrato no cumplido" en actualidad jurídica Nº 9, 2004, UDD, p. 122; KREBS, Claus "La inejecución de obligaciones esenciales como único fundamento suficiente de la llamada condición resolutoria tácita" en Revista chilena de Derecho. PUC. Stgo. p. 851; entre otros).

d) Daniel Peñailillo, nos dice que el incumplimiento que autorizaría la acción, sería aquel que sea significativo, dejando tal determinación al juez. Los fundamentos para que el incumplimiento sea significativo son varios: 1) Equidad; 2) Falta de interés del Acreedor; 3) Abuso de derecho; 4) La buena fe contractual (1546). Asimismo los criterios para determinar cuando el incumplimiento sea significativo serían por ej. A) Valor del Negocio; B) Función que por naturaleza cumple el contrato; C) Finalidad del negocio (Cfr., en extenso, PEÑAILILLO, Daniel. Obligaciones: Teoría General y clasificación. La Resolución por Incumplimiento, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2003, p. 409-410).

En el mismo sentido: FUEYO, Fernando. Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones. Stgo., Ed. Jurídica, 1991, p. 306); ANGUITA, Augusto. "Resolución de contrato y excepción de pago". Ed. Jurídica, Stgo., 1981, p. 37 y 38.

e) Por ultimo, Álavaro Vidal opina que, en nuestro derecho, puede construirse una solución análoga a la de la Convención de Viena. Los argumentos legales tienen que ver principalmente en aquellos casos en que el legislador reservó la resolución para aquellos casos de incumplimientos graves o importantes. Por ej. el art 1926 sobre el arrendamiento (y otras disposiciones en el mismo contrato). Ellas serían normas de integración del art. 1489 del código, de forma que establecerían el animo del legislador de que el incumplimiento sea esencial. Esto unido a la jurisprudencia hacen que el incumplimiento sea esencial cuando se priva al acreedor de lo que tenía derecho a esperar del contrato, siempre que tal resultado hubiere sido previsible por el deudor al tiempo del contrato; el incumplimiento doloso o culpable y otros casos en que el acreedor ya no tiene razones para confiar en el deudor; y en los casos establecidos por las partes.

En la jurisprudencia existen varios fallos significativos:

C. Talca. 12 de noviembre de 1920: "se procede a negar la acción resolutoria en razón a la poca o ninguna influencia de esas obligaciones en los **finés prácticos del contrato**"

C. Concepción, 4 de octubre de 2004: "la interpretación correcta del art. 1489 en atención al contexto de la norma, induce a pensar que el incumplimiento de obligaciones de escasa entidad, que ninguna o nula influencia tienen en la normalidad del cumplimiento de las obligaciones principales no autoriza la resolución del contrato. Ello constituiría un ejercicio abusivo de un derecho, afectando la equidad natural y la buena fe".

Entro otros fallos.

ANEXO IV: EFECTOS DEL PACTO COMISORIO ATÍPICO.

Este pacto comisorio, llamado atípico por no encontrarse "tipificado" o regulado en la ley, es aquel en que las partes estipulan la cláusula de resolución *ipso facto* que se establece en la compraventa a propósito de la obligación de pagar el precio, para el incumplimiento de otras obligaciones distintas (que no sea la de pagar el precio en la compraventa o cualquiera de otros contratos). Se suele decir que produce su efecto sin necesidad de declaración judicial, sin embargo esto es discutido.

Para Luis Claro Solar, el pacto comisorio atípico podía pactarse pero se aplicaban las reglas de la condición resolutoria tácita, ya que el pacto comisorio tiene por objeto forzar el cumplimiento de la obligación.

Para Arturo Alessandri Rodríguez, se le aplican las normas de los art. 1877 a 1880 del Código Civil, por argumento de analogía, ya que es la regulación legal de la misma.

La mayoría de la doctrina y jurisprudencia actual desestiman estas doctrinas por diversas razones. En primer lugar, no produciría el efecto de la condición resolutoria tácita, ni los

del pacto comisorio calificado típico, ya que las partes no han querido que estos se produzcan. Además, produciría el efecto positivo de evitar un juicio y sus consecuencias jurídicas y económicas.

Para aquellos quienes estiman que el pacto comisorio atípico es excepcional y que no se le aplican las normas de la compraventa ni el pacto comisorio, también existe discusión sobre su efecto.

Para algunos produce efecto resolutorio *ipso facto* y para otros requiere algún tipo de manifestación de voluntad por parte del acreedor. La jurisprudencia y la doctrina mayoritaria (Abeliuk, Peñailillo, Pizarro, etc.) ha reconocido la primera posición, basado en la libertad contractual, es decir lo que quieren las partes. La segunda posición (sustentada entre nosotros por Carlos Peña) se funda en argumentos de diversa índole, siendo el principal, el hecho que la resolución no podría producirse por el mero incumplimiento del deudor ya que de otro manera la resolución estaría entregada a su mera voluntad y cabría en la hipótesis del art. 1478 del Código Civil Chileno. Esta última solución sigue el Código Civil italiano.

ANEXO V: DIVERSAS APRECIACIONES RESPECTO A CLASIFICACIÓN ENTRE OBLIGACIONES DE MEDIO Y RESULTADO.

La distinción entre obligaciones de medio y resultado sigue siendo objeto de constante debate. Se discute en primer lugar el contenido de cada uno de estos conceptos y muy ligado a ello la procedencia de la **excusa de diligencia debida en una u otras**.

Sólo para fines didácticos ordenaremos sucintamente las posturas centrales en torno a esto.

1. En primer lugar hay que hacer mención a la posición defendida en Chile, fundamentalmente por el Profesor Peñailillo, que establece que la real relevancia de la distinción entre obligaciones de medios y de resultados radica en el diverso concepto de incumplimiento entre unas y otras. En las de medio, **el incumplimiento equivale al actuar negligente**, incluyéndose la falta de diligencia dentro del ítem de responsabilidad contractual del incumplimiento. En las de resultado el incumplimiento es la no obtención del resultado querido no teniendo relevancia alguna la culpa como elemento de responsabilidad. Así en ambos tipos de obligaciones la imputabilidad subjetiva no sería un requisito autónomo de responsabilidad contractual.

2. Para otros (en doctrina nacional E. Barros, M. Tapia, entre otros), la distinción entre obligaciones de medio y resultado permitiría clarificar que solo a estas últimas aplicaría la presunción de culpa en virtud del incumplimiento. Así en caso de obligaciones de medio la carga de probar la negligencia sería del acreedor.

3. Para parte de la doctrina en la distinción entre obligaciones de medio y resultado no importaría una alteración de la carga probatoria de la culpa sino que yendo más allá se establecería que en las **obligaciones de resultado la culpa no sería un requisito relevante llegando a constituirse un sistema de responsabilidad estricta** respecto a estas últimas.

Esto se basa en el hecho de que la eximente de responsabilidad "ausencia de culpa" no es aceptada comúnmente por la jurisprudencia para exonerarse de responsabilidad en

el caso del incumplimiento de una obligación de resultado. Así, la eximente que se exige en estos casos es el caso fortuito, el cual de probarse, actúa sobre el elemento causalidad, y no sobre el elemento culpabilidad. Así, se propone a un régimen de responsabilidad estricta en virtud de que el elemento culpabilidad no juega un rol relevante en la determinación de la obligación de reparar.

4. Mención especial requiere la posición del profesor Rodríguez Grez respecto a la materia. La distinción entre obligaciones de resultado y medios sería improcedente puesto que **no existirían obligaciones de resultado**. El cumplimiento de una obligación siempre se trataría de la ejecución de un comportamiento típico no pudiendo responsabilizarse al deudor por la obtención un resultado específico. Así de no obtenerse la "meta esperada" pero desplegando toda la actividad necesaria en miras de obtenerla, existiría cumplimiento. La excusa de diligencia siempre sería procedente en todo tipo de obligaciones.

ANEXO VI: ABUSO DEL DERECHO

Todo derecho subjetivo supone una potestad conferida a su titular para hacer efectiva una pretensión determinada. En el ejercicio del mismo existen tanto límites internos como externos.

a. **Límites a los derechos derivados de su contenido:** El contenido de los derechos subjetivos se define y se limita por sus atributos, esto es, por las facultades que confiere a su titular. Veamos algunos ejemplos:

- *Derecho de propiedad:*

- *Facultades que otorga al titular:* Las de usar, gozar y disponer arbitrariamente de la cosa.
- *Límites a su ejercicio:* Según el artículo 582 del C.C, el ejercicio del derecho de propiedad supone no atentar contra la ley ni contra el derecho ajeno.

▪ Ley:

- Límites constitucionales: expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional calificado por ley, previa indemnización de los perjuicios.
- Limitaciones para fines ambientales, urbanísticos, de salud pública, entre otros.

▪ Derecho ajeno:

- Sobre la misma cosa: limitaciones al dominio, como la constitución de un usufructo.
- Sobre otros bienes: como los impuestos por relaciones de vecindad.

- *Derechos personales*

- *Facultades que otorga al titular:* Están definidas por la prestación misma, cuyo alcance dependerá de la ley o del contrato.
- *Límites a su ejercicio:* su titular podrá exigir únicamente lo debido, y solo lo podrá hacer valer respecto del deudor.

b. **Límites externos:** El ejercicio abusivo de un derecho.

El problema del abuso del derecho se plantea respecto de derechos cuyo ámbito de

facultades y límites internos han sido definidos, y en circunstancias que el titular actúa dentro del ámbito formal que el derecho le confiere.

No toda la doctrina se encuentra conteste respecto a la existencia de estos límites externos. Analicemos las principales posesiones al respecto:

- *Negación de la doctrina del abuso de derecho:* Los autores que niegan la posibilidad de ejercer un derecho de manera abusiva señalan que el contenido propio del derecho es su único límite. Lo característico de tener un derecho es justamente que su titular puede actuar discrecionalmente dentro del ámbito de las facultades reconocidas por la ley o por el contrato.
- *El abuso como el ejercicio contrario a los fines del Derecho Subjetivo:* Esta postura entiende que un derecho subjetivo es un medio para satisfacer la función social que corresponde al derecho objetivo, negando su concepción como un mero poder de actuación. En consecuencia, se incurriría en abuso del derecho subjetivo si los *motivos concretos del titular* no están conformes al fin o a la función que el derecho subjetivo posee según el ordenamiento que lo establece.
- *El abuso del derecho como correctivo del ejercicio excesivo o anormal del Derecho:* Sin perjuicio de que un derecho otorga a su titular cierto poder discrecional, existen casos en que su ejercicio dentro de esos límites puede resultar excesivo o anormal al ser contrario a las exigencias mínimas de sociabilidad y buena fe en las relaciones recíprocas. Esta posición entiende que la doctrina del abuso de derecho tiene una función correctiva excepcional, en atención a los riesgos de un intervencionismo judicial excesivo. Para evitar ese intervencionismo a la hora de definir cuándo un comportamiento atenta contra estándares mínimos de conducta, es necesario hacer referencia a ideas normativas compartidas en la sociedad, expresadas legalmente en la forma de cláusulas generales (como “buenas costumbres”, “orden público” y “buena fe”).

Situaciones típicas de ejercicio abusivo de un derecho:

a. El ejercicio de un derecho con el solo propósito de causar daño a otra persona:

En esta situación, el ejercicio del derecho no reporta al titular utilidad alguna, que no sea satisfacer el interés de dañar a otro.

b. Extrema desproporción entre el interés del titular y el efecto negativo que produce en otra persona el ejercicio de ese derecho⁴⁰:

Es contrario a la buena fe extremar el ejercicio de una facultad hasta el límite de la deslealtad.

⁴⁰ El Código de Aguas, en su artículo 56, recoge esta hipótesis, al señalar que “cualquiera puede cavar en suelo propio un pozo; aunque de ello resulte menoscabarse el agua de que se alimenta otro pozo; pero si de ello no reportara utilidad alguna, o no tanta que pueda compararse con el perjuicio ajeno, será obligado a cegarlo”.

c. Actuación contraria a los actos propios:

Actúa en abuso de un derecho quien lo hace de manera que resulte contradictoria con la *confianza* que había generado en un tercero una conducta anterior del titular del derecho. Para que se configure el abuso de derecho no basta que se haya insatisfecho una expectativa ajena creada por la conducta precedente del titular, sino que se exige además un juicio normativo acerca de la deslealtad de la conducta del titular, por atentar contra los deberes recíprocos de respeto que surgen implícitamente de las relaciones personales.

d. Ejercicio de un derecho adquirido de mala fe:

Se trata de un caso de aplicación de la exceptio doli, en cuya virtud el derecho otorga defensa frente a acciones cuyo origen está contaminado por la mala fe⁴¹.

e. Desviación del fin de un derecho potestativo:

El derecho privado otorga facultades para constituir, modificar o extinguir relaciones jurídicas, que pueden materializarse en actos jurídicos bilaterales y unilaterales. Es posible que una facultad otorgada por la ley o contrato para satisfacer ciertos fines, se ejerza de manera que se desvíe de ese fin para satisfacer un interés no cautelado en la norma⁴².

f. Abuso de formas o instituciones jurídicas:

Se utiliza una institución jurídica con un fin diverso al que se supone que debe servir. Un caso de abuso de formas jurídicas es la realización de actos jurídicos formalmente lícitos, pero que producen un efecto que la ley pretende impedir (fraude a la ley).

Efectos del abuso de derecho

Quien ejerce abusivamente un derecho no puede invocarlo como justificación de su conducta, aunque se cumplan formalmente las condiciones para su ejercicio.

- Si el abuso recae en el ejercicio de una acción civil, el titular queda privado de la pretensión respectiva.
- Si el abuso recae en un derecho potestativo, el efecto será la ineficacia del acto, ya sea nulidad o inoponibilidad.
- Si los efectos del acto abusivo se prolongan en el tiempo, corresponde interponer una acción destinada a evitar o terminar el daño provocado.
- Si la conducta abusiva es además culpable o dolosa, se regirá por las normas de la responsabilidad extracontractual.

⁴¹ Un importante ejemplo de esta figura se regula a propósito de la nulidad. En efecto, el artículo 1683 C.C. priva de la acción de nulidad absoluta al contratante que celebró el acto o contrato "sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba".

⁴² Por ejemplo, la autoridad paterna debe ser ejercida en atención al mejor interés del menor; los directores de las sociedades anónimas deben cuidar el interés de los socios y no el propio.

ANEXO VII: TEORÍA DE LOS ACTOS PROPIOS⁴³

La teoría de los actos propios (*Venire contra factum proprium non valet* "nadie puede ir válidamente contra sus propios actos", o *Venire*), es una doctrina jurídica que permite oponerse al ejercicio de un derecho o pretensión que afecta a un tercero cuando quien lo realiza ha efectuado con anterioridad una conducta o comportamiento que resulta contradictoria con lo que ahora pretende.

Esta doctrina se fundamenta en la confianza que se requiere en el actuar de los sujetos de derecho, que no sólo se espera respecto de las partes de un contrato, sino que también respecto a los terceros.

El *Venire*, se considera una manifestación del principio de buena fe objetiva, que obliga a las partes a adoptar un correcto y leal comportamiento a lo largo de todo el íter contractual. De esta manera esta doctrina sería exigible en virtud de lo dispuesto en el art. 1546.

Es necesario explicitar que esta teoría no busca prohibir los cambios o alteraciones en las conductas de los contratantes, que son consideradas naturales y propias del ser humano, sino que cuando la conducta anterior fue libremente asumida y tiene una relevancia jurídica particular y el nuevo comportamiento contradictorio produce un resultado desproporcionado de perjuicio al tercero que de buena fe ha podido fiarse del estado de hecho provocado por la conducta anterior, surge la doctrina de los actos propios para recomendar la ineficacia del nuevo comportamiento⁴⁴.

En razón de lo anterior, la doctrina de los actos propios tiene un carácter excepcional, ya que, en primer lugar, sólo procede cuando realmente hay una justificación suficiente y proporcionada. En segundo lugar, sólo tiene lugar de manera residual, es decir, para aquellos casos en los que no hay una norma expresa que resuelva de una u otra manera el conflicto provocado por el cambio. En tercer lugar, en que se trata de una doctrina supletoria, es decir, que procede cuando no existen otros instrumentos jurídicos que permiten proteger los intereses del tercero afectado (por ejemplo, no procederá si se aplica el adagio "*nadie puede aprovecharse de su propio dolo*" o la imposibilidad de la retractación emana de la fuerza obligatoria, de la irrevocabilidad de los actos jurídicos o de la confirmación tácita de actos relativamente nulos).

Para que opere la teoría de los actos propios se requiere:

⁴³ Apunte realizado en base a PADILLA, Ricardo. POR UNA CORRECTA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS. *RChDP* [online]. 2013, n.20, pp.135-183. Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071880722013000100004&lng=es&nrm=iso> CORRAL, HERNÁN. La doctrina de los actos propios en el Derecho de Familia chileno, en Hernán Corral Talciani (edit.), *Venire contra factum proprium. Escritos sobre la fundamentación, alcance y límites de la doctrina de los actos propios*, Cuadernos de Extensión (U. de los Andes) 18, 2010, pp. 103-139. Disponible en: <<https://corraltalciani.files.wordpress.com/2010/04/actospropios-familia.pdf>> PARDO, INÉS. La Doctrina de los actos propios, *Revista de Derecho PUCV*, 1991-1992. Disponible en: <<http://www.rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/viewFile/244/225>>, y otros.

⁴⁴ Dicho de otra forma, nadie puede variar de comportamiento injustificadamente cuando ha generado en otros una expectativa de comportamiento futuro.

1. Que la primera conducta sea jurídicamente relevante, válida y voluntaria.
2. Que ella produzca objetivamente un estado de hecho que permita generar confianza o expectativas legítimas.
3. Que la segunda conducta sea contradictoria o incoherente con la primera y con ella se pretenda ejercer un derecho, facultad o pretensión.
4. Que exista identidad entre el sujeto que desarrolló la primera conducta y el que ahora pretende desconocerla con un hecho contrario.

Reunidos estos requisitos la teoría de los actos propios tiene como **efecto** que el juez deberá **rechazar la acción** que se deduzca para ejercer el derecho o la pretensión basada en la contradicción.

La aplicación de esta teoría presupone la existencia de una situación procesal. En ella, el sujeto intenta ejercitar un derecho subjetivo o una facultad que cree que le corresponde, dentro de una situación litigiosa. Sin embargo, su actuación contradice otra conducta suya extraprocesal o pre-procesal anterior que constituye su acto propio, contra el cual no puede venirse. De esta manera, su pretensión en estas circunstancias, siendo incompatible, debe ser desestimada.

Así, el efecto no se trata ni de responsabilidad, ni de nulidad, ni de una causal de extinción del derecho, sino más bien de una forma de ineficacia que puede caracterizarse como inadmisibilidad de la pretensión.

Aún cuando es discutida la sanción, la mayoría de la doctrina y jurisprudencia estima que se trata de una consecuencia básicamente procesal: el sujeto no puede ejercer el derecho y desconocer lo actuado, sin que importe una legitimación o convalidación o regularización de la situación jurídica del tercero, que podrá ser atacada o impugnada por otros legitimados para ello. En general, procederá como excepción o defensa del demandado, pero la doctrina admite que pueda ser aplicada de oficio por el juez.

Así lo ha sostenido nuestra Corte Suprema, que en diversos fallos⁴⁵ ha reconocido la teoría de los actos propios pese a la falta de regulación positiva⁴⁶.

Finalmente, y a modo de ejemplo, expondremos el caso conocido por la CA de Concepción, Rol 1.071-2010, relativo a un proceso indemnizatorio en contra de la dueña del vehículo causante de un accidente de tránsito en que colisionan tres autos, en calidad de tercero civilmente responsable. En dicho proceso, la demandada alega para eximirse de dicha responsabilidad, que su automóvil habría sido tomado por su hijo sin su consentimiento. La CA de Concepción, teniendo a la vista otro proceso judicial iniciado por los mismos hechos, donde la demandada en esos autos llegó a un avenimiento con uno de los otros dos conductores partícipes del accidente, razona:

"la más elemental lógica concuerda en esta parte con lo que en doctrina se denomina teoría de los actos propios, desde que no resulta posible aceptar responsabilidad respecto de los daños causados a uno de los participantes en los

⁴⁵ Una extensa revisión jurisprudencial se encuentra en <<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722013000100004>>

⁴⁶ Parte de la doctrina estima como manifestaciones legales del Venire los artículos 169, 1234, 1237, 1723, 1818, entre otros. Ver PARDO, Inés, ob. Cit. p. 66.

hechos y, al mismo tiempo, negar esa responsabilidad respecto del otro partícipe, en circunstancias que los hechos que originan los resultados dañosos son los mismos ya que, en el caso en estudio, ello equivaldría a sostener que respecto de uno de los afectados por el acto imprudente, negligente y culpable del conductor Asperren Barrera, éste habría actuado conduciendo el móvil con el consentimiento de su dueña (la demandada como tercero civil responsable) , o al menos con el conocimiento de ella y, en cambio, tratándose del otro afectado, no habría existido tal conocimiento ni consentimiento"

Anexo VIII: Caso Zorín con Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. (Octubre 2012)

Este es el primer caso en que la Corte Suprema se pronuncia a favor de la autonomía de la acción indemnizatoria en caso de incumplimiento de una obligación de dar. En el caso, Compañía Siderurgia Huachipato S.A. y Zorin S.A. celebraron un contrato de compraventa en virtud del cual Huachipato se obligaba a entregar 1500 toneladas de rodillos de laminación dados de baja por desuso y Zorin S.A. a pagar la suma de US\$ 267.750 por estos. El elemento determinante para la celebración del contrato fue la composición química de los rodillos, alta en níquel, que permitían a Zorin S.A. venderlos a su vez a una empresa norteamericana interesada en la calidad y composición de los elementos minerales de los rodillos. Enviadas las primeras 58 toneladas de rodillos, la empresa norteamericana les informó que la composición de los metales enviados distaba enormemente de lo que se había requerido.

Atendida la imposibilidad de concretar el negocio con la empresa estadounidense, y el daño que el incumplimiento ocasionó a la imagen y prestigio de Zorín, esta demandó la indemnización de daños por inexecución contractual en contra de Compañía Siderúrgica Huachipato S.A., por concepto de daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la imagen. El tribunal acogió la demanda indemnizatoria, invocando al efecto la infracción al principio de buena fe contractual, desechando la excepción de contrato no cumplido y la teoría de la accesoriedad de la indemnización por infracción de una obligación de dar alegadas por la demandada. Apelada dicha sentencia, luego es confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago. En contra de esta sentencia el demandado deduce recurso de casación en el fondo y recurso de casación en la forma ante la Corte Suprema, los que son rechazados. A su vez, el demandante, deduce recurso de casación en la forma que es acogido y determina la dictación de una sentencia de reemplazo.

En este caso el acreedor optó por la indemnización exclusiva, pues, si bien resultaban procedentes la resolución y la pretensión de cumplimiento específico, ellas no satisfacían su interés. En efecto, los rodillos ya habían sido laminados, de modo que aun cuando intentara la acción resolutoria, no hubieran podido restituírseles. Por otro lado, exigirle a Siderúrgica Huachipato que entregara los rodillos convenidos, suponía solicitar a Triorient Trade Inc. la restitución de aquellos recibidos y el envío de los pactados, debiendo soportar Zorín la nueva adquisición y el costo de esa operación.

La sentencia de la Corte Suprema de 31 de octubre de 2012 resuelve que la entrega de una cosa distinta a la pactada constituye un cumplimiento imperfecto del vendedor, dado que, de conformidad a los artículos 1828, 1568 y 1569 no ha cumplido con su obligación de entregar la cosa convenida. Asimismo, estimó que procede la indemnización autónoma, sin que ello implique una vulneración de los artículos 1489 y 1873 del Código Civil, dado que estos no exigen para acoger tal pretensión que el acreedor demande

conjuntamente la resolución del contrato. Incluso, precisa que como la misma Corte lo ha resuelto en otras oportunidades, siguiendo una moderna tendencia doctrinal, el demandante puede plantear la indemnización sin asociarla a la resolución, pues, la entrega material de los rodillos está cumplida y parte de ellos fueron cortados, debiendo considerarse tal indemnización como parte de lo que el vendedor debe en "cumplimiento del contrato, pues según el artículo 1591 el pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban". En atención a estas consideraciones el tribunal acoge la pretensión indemnizatoria, pero solo condena al demandado a indemnizar la suma de 114.400.000 \$ por concepto de lucro cesante. Los considerandos más importantes establecen:

"NOVENO: Una vez establecido que efectivamente ha existido un incumplimiento del contrato, corresponde determinar si la actora ha podido ejercer la acción indemnizatoria, como lo ha hecho, prescindiendo de lo que disponen los artículos 1489 y 1826 del Código Civil, que parecen indicar que tal acción no es autónoma, sino que debe siempre ir acompañada sea de la petición de resolución contractual o bien de la exigencia de cumplimiento del contrato. Como ya lo ha resuelto esta Corte en otras oportunidades, y siguiendo una moderna tendencia doctrinal (Rol 3341-012), se estima que, en este caso, la demandante ha podido plantear su demanda de responsabilidad civil contractual, sin asociarla a la resolución del contrato, pues, la entrega material de los rodillos está cumplida y parte de ellos fueron cortados.

DÉCIMO: **Que, en todo caso**, una demanda de daños y perjuicios en los términos que se han descrito, debe ser considerada como parte de lo que el vendedor debe en 'cumplimiento del contrato', de acuerdo con los términos del artículo 1489 del Código Civil. En efecto, conforme al artículo 1591 'el pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban'. Dado que en este juicio se pretenden indemnizaciones derivadas de un incumplimiento contractual, asociadas a una entrega imperfecta de la cosa vendida, debe entenderse que el deudor está ejerciendo una acción de cumplimiento contractual, para ser debidamente pagado por el deudor, aunque la acción esté reducida a las indemnizaciones que el actor estima que la sociedad demandada le adeuda por incumplimiento del contrato."

De este modo, la Corte Suprema defiende la autonomía de la acción indemnizatoria recurriendo a las reglas del pago y, en particular, lo que disponen sobre la forma en que debe hacerse el pago, entendiendo que la indemnización corresponde a lo debido por el contrato, en atención al requisito de que el pago debe ser íntegro. Se establece que cuando el acreedor demanda la indemnización de perjuicios por el incumplimiento, lo que hace es reclamar lo debido según la convención, justificando el recurso en el artículo 1591 del CC. En otras palabras, el pago de la indemnización corresponde a lo que hubiese recibido el acreedor de haberse cumplido perfectamente el contrato.

Es necesario mencionar que parte de la doctrina ha criticado el fallo, en el sentido que la comprensión que concibe la indemnización de perjuicios como parte del pago contraviene la idea de una acción de perjuicios autónoma, y no guarda relación con el concepto de responsabilidad contractual que ha venido decantando en los últimos años. Sin perjuicio de ello, ésta sentencia marca un precedente en la materia. La relevancia de esta sentencia es innegable, pues evidencia un vuelco en el razonamiento que nuestro máximo tribunal sostuvo durante décadas, según el cual el artículo 1489 del *Código Civil* consagraba el

carácter accesorio, complementario y concurrente de la indemnización por incumplimiento de las obligaciones de dar.

Anexo IX: Sobre la diferencia entre estar obligado y ser responsable.⁴⁷

¿Es lo mismo estar obligado que ser responsable? Una mirada superficial a este problema podría decir que sí, en la medida en que el concepto de responsabilidad civil puede entenderse en un sentido amplio o restringido, y en la medida en que el tratamiento legal de estas materias es más bien obscuro. No obstante, la situación jurídica de “estar obligado a” y “ser responsable de”, son distintas.

Las obligaciones, en términos generales, emanan de una determinada fuente de las obligaciones. El objeto de las obligaciones consiste en una prestación cuyo contenido es, dar, hacer o no hacer alguna cosa o conducta, según lo que hayan pactado las partes o según la fuente de las obligaciones de que se trate. (En el caso de los cuasicontratos, por ejemplo, las obligaciones restitutorias emanadas de ellos tienen la naturaleza jurídica de obligaciones de dar). De esta manera, estar obligado consiste en encontrarse en la necesidad jurídica de cumplir una determinada prestación a favor del acreedor. Luego, el ordenamiento jurídico le otorga a este acreedor diversos medios para cautelar su crédito en caso de incumplimiento por parte del deudor.

En un sentido amplio, entonces, la responsabilidad civil expresa la potestad que el Derecho le confiere al acreedor para actuar contra el patrimonio del deudor, pues quien se obliga lo hace con todo su patrimonio. Ahora bien, en un sentido más estricto o restringido, la responsabilidad civil consiste en la imputación de una obligación indemnizatoria como consecuencia de un hecho ilícito, respecto del cual se realiza un juicio de imputación al sujeto responsable. Según si este hecho ilícito consiste en el incumplimiento de un contrato o de un deber general de cuidado, la responsabilidad civil se clasifica en responsabilidad contractual y extracontractual.

Estar obligado, por consiguiente, es la consecuencia de la concurrencia de una fuente de las obligaciones, no tiene como requisito esencial un juicio subjetivo de imputación al deudor, y consiste en el deber de cumplir con una determinada prestación. Ser responsable, en cambio, es la consecuencia de un hecho ilícito, y se traduce en un deber indemnizatorio.

Esta diferencia resulta especialmente relevante en materia contractual. En el contrato se expresa la diferencia lógica entre estar obligado y ser responsable. El contrato da lugar a una obligación de dar, hacer o no hacer. La responsabilidad contractual es una obligación de segundo grado, pues no emana directamente del contrato, sino del hecho ilícito consistente en infringir la obligación de primer grado que emana del contrato.

Tener en cuenta la diferencia anterior resulta relevante, pues hay diferencias relevantes en el tratamiento de las acciones que emanan de la situación de “estar obligado a” y de la situación de “ser responsable de”. Así, las cargas probatorias son diferentes para exigir

⁴⁷ Anexo elaborado en base al texto La diferencia entre ‘estar obligado’ y ‘ser responsable’ en el derecho de contratos, en H. Corral y M. S. Rodríguez (editores), Estudios de Derecho Civil II, Santiago, Lexis Nexis, 2007, pp. 721-752, del profesor Enrique Barros.

la pretensión de cumplimiento en naturaleza (basta acreditar la existencia del contrato y alegar el incumplimiento) y para perseguir la responsabilidad civil emanada del incumplimiento (es necesario alegar todos los requisitos de la responsabilidad civil, entre los cuales destaca el requisito de la imputabilidad del hecho ilícito del incumplimiento); las excepciones que puede oponer el deudor en un juicio de cumplimiento forzoso son distintas que las excepciones que puede oponer en un juicio de responsabilidad civil, entre otros aspectos relevantes.